

فصل تمهيدي

يمكن التأكيد أن لكل رؤية منهجها الأهم الخاص بها الذي يكشف عن جوهرها وطبيعتها، وفي الوقت نفسه فالمنهج السليم يلور الظاهرة ويسير أغوارها المختلفة ويكشف عن جوانبها المتعددة ويشكل المدخل الطبيعي لها والفكرة المفتاح لاستجلاء مضمونها وعموميتها .
وعلى ضوء ما تقدم وجدت من المناسب التوطئة لظاهرتنا هذه بالأبحاث الآتية :

- استجلاء الإرادة المشتركة هو موضوع تفسير العقد .
- المقصود من التفسير والتطبيق "مسألة اشتباه واختلاط الظاهرتين" .
- مظاهر التعبير عن الإرادة .
- بعض القواعد العامة في التفسير .
- التفسير المتسرر: *anticipées*، ومسألة نظرية المسخ .

مقدمة عامة

((مسألة أولية))

موضوع بحثنا هو تفسير العقد في كل من القانون المدني والقانون الإداري ، ومن المعلوم أن العقد في إطار القانون الخاص لا يثير أية صعوبة لجهة تحديد ماهيته وطبيعته الذاتية وإن كانت هنالك محاولات مرجوحة ، بـل ومهجورة للتمييز بين العقد والاتفاق قاصدين من الاتفاق بعض صور الخيار الإرادي المشترك الذي يظهر في صيغ متعددة مثل الحوالة وإضافة الأجل أو الشرط إلى الالتزام وغير ذلك ^١ .

وحقيقة الأمر أن الاتفاقات التي تبدو شبيهة على صعيد القانون المدني ، هذه الاتفاقات تتعدد مسورها ومظاهرها عل صعيد القانون الإداري ، الأمر الذي يستدعي وضع ضوابط للعقد ، ومن ثم تمييزه من صور الاتفاقات المتعددة على صعيد القانون الإداري لا سيما أنه كثيراً ما تحدث اتفاقات ((أعمال إدارية اختيارية أو ما يسمونها *actes des volontés*)) تلنقي لها إرادات الإدارات في نقطة واحدة دون أن يعني ذلك أننا حيال عقد ، وهو الأمر الذي يفرض علينا تحديد موقعية : **Topology** العقد الإداري في مجموعة الأعمال القانونية . والواقع أن البحث في الطبيعة القانونية للعقد الإداري يعني البحث عن نوع العمل القانوني الذي ينتمي إليه العقد ، وما إذا كان عملاً عاماً أم عملاً ذاتياً ، أم عملاً شرطياً *acte conditionnel* ^٢ .

^١ ينظر في عدم الخلاف بين الاتفاق والعقد د. السهوري : الوجيز في شرح القانون المدني ، القاهرة ،

دار النهضة العربية ١٩٦٦ ، ص ٢٧

^٢ العمل الشرطي هو العمل الذي يحيل عند تحقيقه إلى النص القانوني كتقيد التطوع في الجيش أو عقد الزواج وغير ذلك

هذا من حيث التقسيم الموضوعي للأعمال القانونية^١، لكن إلى جانب هذا التقسيم يمكن تقسيم الأعمال القانونية تقسيماً يراعي الشكل الذي يتخذه الإفصاح عن الإرادة في هذا العمل . ذلك أن التقسيم الشكلي يراعي شكل العمل القانوني ليس إلا، ومن ثم لنا أن نسأل عن أي تقسيم من التقسيمات الشكلية للأعمال القانونية يدخل العقد الإداري، وبالتالي فهل يعد عملاً اتفاقياً **acte-convention** أم عملاً جماعياً **acte-collectif** .

قبل الإجابة عن هذا السؤال لابد من التنويه بأن إفصاح الإدارة عن إرادتها في العملية التعاقدية غالباً ما يتم في شكل عملية مركبة معقدة متشابكة، وقد تكون على مراحل متعددة وفي فترات متلاحقة .

وعادةً ما يسبق ذات التصرف الذي يتم بمقتضاه إبرام العقد الإداري طائفة من الإجراءات والتدابير التي تمهد ولهي لوليد ذلك التصرف الذي قد تعقبه طائفة أخرى من تدابير وإجراءات التصديق والاعتماد اللازم لإبرام العقد^٢ . ومع كل ذلك فالعقد الإداري يبقى عقداً بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى وما ترتب من نتائج، وأخص ذلك الطبيعة ذاتها التي للعقود المدنية، وفي مقدمة ذلك القاعدة المدنية المعروفة : العقد شريعة المتعاقدين^٣ .

^١ وهو تقسيم يستند إلى مضمون العمل القانوني وأثاره القانونية المتخلفة عنه .

^٢ د. ثروت بدوي : النظرية العامة في العقود الإدارية، القاهرة، دار النهضة العربية، ١٩٧٠، ص ٤٣ .

^٣ د. سليمان محمد الطمائي : الأسس العامة للعقود الإدارية، القاهرة دار الفكر العربي، ط ٣، عام ١٩٦٥، ص ٣١٩ .

^٤ د. ثروت البدوي : النظرية العامة للعقود الإدارية، ص ١٠٩ .

والخلاصة أن العقد الإداري لا يقوم فقط على توافق إرادتين ، بل أكثر من ذلك فنحن حينئذ أطراف متقابلة تمثل مصالح متعارضة ، حيث يعمل كل طرف على تحقيق مصلحته الخاصة ، ويتم التعاقد بتطابق هذه الإرادات في نقطة التقاء المصالح : **parie-parti** ^١ التي هي الغرض من العقد ، بحيث ينشأ هذا العمل التزامات متبادلة : **mutuellement** ، وبالتالي فمن التقاء الإرادتين المتعارضتين في نقطة التقاء المصالح تتكون منظومة العقد وتتحرك آلية التفسير في إطار نسق هذه المنظومة وعناصرها وإوالياتها لتنتج من روحها وتبطنها وقانونها ومنطقها الداخلي ، وفي النواة النووية من ذلك الإرادة المشتركة **la commune intention** .

وإذا أردنا أن نحلل عناصر هذه المنظومة كأساس للتفسير أمكن تحديد ذلك فيما يلي : الإرادة المشتركة - نقطة التقاء المصالح (الغرض) - إرادة كل فريق - الظروف الخارجية لكل فريق - الظروف الخارجية العامة . وبالطبع فقد تفاوتت أهمية كل عنصر ، وتبقى الإرادة المشتركة هي سواة هذه المنظومة مع التنويه بأن البحث عن هذه الإرادة المشتركة - وهي آلية تتعلق بقواعد التفسير - يرتبط وبراغمي أولية أخرى هي قواعد الإسناد ^٢ بحيث تترسم حدودها وتراعي معالمها .

^١ محمد حامد الحبل : الموظف العام ، ط ١ ، ١٩٥٨ ، القاهرة ، دار الفكر الحديث ، ص ١٥٥ .

^٢ د. أحمد شوقي محمد عبد الرحمن : قواعد تفسير العقد ، ١٩٧٧ ، كلية الحقوق ، جامعة المنصورة .

البحث الأول

استجلاء الإرادة المشتركة هو موضوع تفسير العقد

قلنا إن هنالك أعمالاً قانونية تلتبس وتتشبه بالعقد باعتبارها تقوم على صيغ توافقية للإرادات ، فعلى سبيل المثال نجد القرار الإداري يمر في بعض صيغه عن هذه التوافقية ، كما هي الحال في تعيين الموظف ، أو في الحصول على رخصة ، ومع ذلك فهذا القرار هو عمل قانوني انفرادي :

Acte unilatéral ، يقوم على إرادة واحدة هي إرادة الإدارة ، وإذا ما انضمت إرادة الفرد إلى هذه الآلية القانونية¹ ، فالأمر لا يعدو التعبير الانفرادي عن إرادة الإدارة ، دون أن يكون للفرد أي دور في تكوين القوة القانونية ، بل تقتصر إرادته على الانضمام المتحرر لما قامت به إرادة الإدارة .

وهناك صيغ أخرى تقوم أيضاً على التوافق كما في العمل الاتحادي : **Acte union** ، ومثاله القرار الذي يصدر عن مجلس ، فهنا تتفق الارادات جميعاً وتمتدح ثم تنصهر لتشكل إرادة واحدة تعبر عن هذا العمل الاتفاقي العام . أما العقد - كما سبق قوله - سواء أكان إدارياً أم مدنياً فهو عمل اتفاقي ، لكنه يتميز عن غيره من الأعمال الاتفاقية بأنه يقوم على التعارض والتجاذب والتشاد والتساوم والمساواة بين الأطراف والارادات ، حيث يمر كل طرف عن مصلحته ، ثم يصلان إلى حل في نقطة وسط هندسية .

والعقد الإداري لا يخرج عن هذه الماهية والسمة الجوهرية ، إذ على الرغم من الدور الذي تلعبه الإدارة في قبة الشروط المادية للعقد التي تسق الإفصاح عن إرادة الطرفين ، وعلى الرغم من كتلة الشرعية **Bloc légalité** التي تحيمن على إرادة الإدارة وتوجهها وترسم لها بوصلة العمل ، على الرغم من كل ذلك ، فالعقد

¹ علماً لبعض صيغ القرارات الإدارية التي هي الأمر **order** التي تصدر رغم إرادة الفرد ودون موافقته .

الإداري يبقى عقدا بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى وما ترتب من نتائج قانونية^١.

صحيح أن العقد الإداري (عمل إداري)، وبذلك فهو يدخل في عداد كلمة الأعمال الإدارية، ويخضع من حيث التجهة للنظرية العامة للعمل الإداري^٢، ومع ذلك فهو عمل عقدي يسمى - فيما يسمي إليه - إلى النظرية العامة للعقد، وينشد إلى أصرة الحياة العقدية في القانون المدني، بما يتفق مع جوهر القانون ووظيفته الذاتية وماهية العميقة، وهذا ما يفتح المجال للمزيد من اليقظة الحرث والتفتيش والمقاربة لإيجاد ما هو مشترك بين نظريتي العقد الإداري والنظريات التي تحكم مجال النشاط الخاص.

هذه السمة الماهوية للعقد الإداري - رغم خضوعها لعملية إجرائية مركبة ومتشعبة - عبرت عنها محكمة القضاء الإداري في مصر بقولها: إن النظرية القانونية العامة في العقود الإدارية تبدأ على غرار مثيلتها في العقود المدنية بالنقضي عن شروط صحة انعقاد العقد وطرائقه من حيث احتبار الطرفين المتعاقدين مع الإدارة وإعداد شروط التعاقد، وتكون العقود التي ترميها الإدارة أكثر تعقيدا منها في العقود المبرمة بين الأفراد، ويبرز أشد أنواع هذا التعقيد بوجه خاص في الشق المتعلق بالتعبير عن إرادة الإدارة، ويتكون العقد الإداري كما يتكون العقد المدني من تلاقي رضا كل الطرفين المتعاقدين برضا الآخر، وإذا كان التعبير عن إرادة المتعاقد مع جهة الإدارة يشبه في

^١ د. الطماوي: الأسس العامة للعقود الإدارية، ص ٤٠٢.

^٢ انظر في هذا الصدد رائعة ستا مينبولس حول النظرية العامة للعمل الإداري الموسومة بعنوان

Traite des actes Administratifs, Athènes, 1954

بساطته التعبير الصادر منه في نطاق القانون الخاص ، إلا أن التعبير عن إرادة جهة الإدارة غالبا ما يتم في شكل عملية متلاحقة على حسب الأحوال^١ .
هكذا يتضح مما تقدم أن العقد الإداري لا يختلف جوهرًا عن العقد المدني لجهة قيام الإرادة المشتركة ، وبذلك يكون غاية التفسير هو البحث عن تلك الإرادة المشتركة ، وهذا ما يتضح من حكم مجلس الدولة المصري الصادر في ١٩٥٧/٦/٣٠ المتضمن ما يلي : ومن حيث إنه من المتعين في مقام تفسير العقود البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ ، إذ العبرة إنما تكون بالإرادة الحقيقية (الباطنة) على أن تكون الإرادة المشتركة للمتعاقدين ، فهي التي يوحدها دون اعتداد بما لأي متعاقد فيها من إرادة فردية لم يتلاق مع المتعاقد الآخر^٢ .

وهناك ملاحظة جديرة بالتنويه هي أن موضوع بحثنا - كما قلنا - هو التحري والتعرف بآلية قواعد التفسير عن النية المشتركة ، ولكن هذا التحري قد تعوزه الوسائل ، وعندئذ يتم الرجوع إلى القواعد القانونية التي رسمها المشرع .

قد يقول قائل إن العقد الإداري يتميز بخصائصه ، والجواب بسيط جدًا ومقاده أن هذه الخصائص لا تؤثر لها إلا على بعض خصائص العقد الإداري ، وليس على جوهره .

وبيان ذلك أن العقد الإداري ظاهرة من ظواهر الحياة وسننها ، فهو يخضع للتمدد والتقلص ، ولكنه في هذا التمدد والتقلص لا ينسف ماهية العقد من جذورها ، وهذا ما يتضح من نظريات القانون الإداري الكبرى التي تسمح

^١ حكمها الصادر في ١٩٥٦/٩/٢٣ القضية رقم ١٩٦٥ لسنة ٨ قضائية السنة ١١ ، ص ١٠٦ .

^٢ القضية رقم ٣٤٨ لسنة ٩ قضائية

بإجراء تعديل في العقد على ضوء الغرض وإمكانات المتعاقد وعدم إحجراء الانقلاب في العمق أو الحفاظ على التوازنات الأساسية له ، لا بل إن هذه التعديلات خضعت لتبريرات وتفسيرات متعددة أهمها افتراض قبول المتعاقد بذلك أثناء العقد (الإرادة المفترضة) ، وهو ما سنحدث عنه في المستقبل ، كل ذلك لحفظ التوازن بين استقرار إرادة المتعاقد ، وحرية المرفق استقراراً يحقق التوازن في صيغة تلائم بين مصلحة الإرادة (حرية العقد) ومصلحة المتعاقد ((الحفاظة على جوهر العقد وتوازنه من خلال إرادة مفترضة)) .

وبيان ذلك أن القاضي قد لا يتيسر له التعرف على النية المشتركة للمتعاقدين ، فهو ملزم في هذه الحال - البحث عن هذه النية ، لكن استعلاء النية المذكورة قد يكون متعللاً ، وهذا يمنع القانون ويأخذ بيده ، ويرسم له الطرق والقواعد التي تعينه على الحال ، وهذا هو التفسير الموضوعي ، وهو لا يقوم على البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين ، بل يقوم على الضرورة بسبب أن التفسير الذاتي قد لا يؤدي أحياناً إلى نتيجة إيجابية ، ومن ثم فعلى القاضي أن لا يلجأ إلى التفسير الموضوعي إلا عندما لا تسعفه قواعد التفسير الذاتي^١ .

ومن هذه القواعد القواعد الموضوعية التي رسمها القانون والتي ندب الرجوع إليها في حال الشك فيما قصد إليه المتعاقدان ، من ذلك قاعدة الشك لمصلحة المدين وقاعدة أن الشك في عقود الإذعان يفسر لمصلحة المدعى - داتاً كان أم مديناً (١٥١ / مدين سوري) .

^١ د. محمد وحيد الدين سوار : شرح القانون المدني - النظرية العامة للالتزام ، دمشق ، مديرية الكتب

والمطبوعات الجامعية ، ١٩٩٤ ، ص ٣١٠

وفضلاً عن ذلك فهناك قواعد موضوعية لاستجلاء الإرادة المشتركة في حال غموضها ، ومن هذه القواعد عل سبيل المثال : طبيعة التعامل - الأمانة والثقة - العرف التجاري في المعاملات .

فهذه القواعد في التفسير موضوعية لسبب بسيط هو أن القاضي يعتمد في تفسير العقد لا بالإرادة الباطنة ولا بالإرادة الظاهرة وحدهما ، وإنما بالإرادة التي يمكن التعرف عليها من جميع المعايير الموضوعية المحيطة بالعقد^١ . ونحن بدورنا سنلجأ إلى تلك القواعد الموضوعية في التفسير سواء بالنسبة للشروط العقدية الغامضة أم بالنسبة للشروط التي يعنيتها الشك .

^١ د سوار : المرجع السابق ص ٤١٦

البحث الثاني

التمييز بين تفسير القانون وتطبيقه

تطبيق التشريع يقصد به إجراء حكم القاعدة القانونية على الحالات الواقعية التي تخاطبها، وهذا يقتضي أولاً تحديد الحكم القانوني في القاعدة، ثم تبيان الحال النموذجية التي وضعت بالنظر إليها ومعرفة عناصرها الجوهرية، أو أوصافها المكونة لها، ثم التحقق من مطابقة الحال الواقعية مع تلك الحال النموذجية أو إجراء حكم هذه على تلك، فهذا المعنى العام يشمل تفسير التشريع، كما يشمل تطبيقه.

والتفسير هو الاستدلال على الحكم القانوني أو على الحال النموذجية التي وضع لها الحكم في واقع ألفاظ نص القانون^١.

أما تطبيق التشريع بالمعنى الخاص فيأتي بعد التفسير، أو هو قياس الحال الواقعية على الحال النموذجية للتحقق من اتفاقها معها في عناصرها الجوهرية وإجراء حكم الثانية على الأولى^٢.

وهكذا تبدأ الخطوة الأولى بالتعرف على معنى الحكم وأخيراً التحقق من توافر هذه الشروط والأوصاف في الحال الواقعية المطلوب تطبيق الحكم عليها أي التحقق من مطابقة الحال الواقعية على الحال النموذجية^٣.

^١ د. سليمان مرقس: المدخل للعلوم القانونية المطبعة العالمية القاهرة، ٩٦٧ ص - ٢٤٠.

^٢ د. سليمان مرقس: المدخل للعلوم القانونية ص - ٢٤٠.

^٣ د. سليمان مرقس: المدخل للعلوم القانونية ص - ١٧٨.

وقريب من ذلك ما أكدته الدكتور حامد سلطان بأن تطبيق القاعدة القانونية يقتضي أولاً : نشوء واقعة أو رابطة معينة وثانياً وجود قاعدة قانونية تستند إليها الواقعة أو الرابطة ، وثالثاً تحديد معنى هذه القاعدة القانونية ونطاقها تحديداً دقيقاً توطئه لتحديد الآثار القانونية التي تترتب على الإسناد إليها^١ .

ويعطي الدكتور عدنان القوتلي للتفسير وظيفة أكثر دينامية وحيوية ، إذ التفسير لديه ليس فقط تعيين معنى النصوص ومداها ونتائجها ، بتوضيح ما أهم من ألفاظها ، وتكميل ما اقتضب منها ، بل توسيعها وتكييفها والتخريج على أحكامها والتوفيق بين أجزائها ومفاهيمها واستخراج ما أمكن من نتائجها^٢ .

والملاحظ أن القانون المدني السوري (المادة ١٥١) تكلم عن تفسير العقد على ضوء ما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين ، ثم عاد للكلام على الأمانة دون ذكر الثقة لأن ذلك يتعلق بطرف واحد في صدد تنفيذ العقد (المادة ١٤٩) .

ذلك أنه لم يعد يوحد كما كان الأمر في القانون الروماني عقود حرفية التنفيذ:

Contrats de droit strict وعقود رائدها حسن النية،
contrats de bonne foi ، بل إن العقود جميعها في القانون الحديث قوامها - في التنفيذ - حسن النية .

^١ د.حامد سلطان : القانون الدولي في وقت السلم ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، ط ٤ / ٩٦٦ / ص ٧٤

^٢ د.عدنان القوتلي : كتابه الوخير في المدخل للعلوم القانونية ، مطبعة دار الفكر بدمشق ط ٧

ويرتب وجوب مراعاة حسن النية في تنفيذ العقود أن المفاوض إذا تعهد بتوصيل أسلاك للكهرباء وجب عليه أن يقوم بتوصيلها من اقصر طريق ممكن وإن أمن النقل يجب عليه أن ينقل البضاعة من الطريق الأمثل بالنسبة إلى صاحبها^١.

ويجري القانون حسن النية في تنفيذ العقد فيصح المدين نظرة الميسرة .

^١ د. السهوري : الوجز في شرح القانون المدني ، ص ٢٤٠ .

البحث الثالث

مقدمة:

مظاهر التعبير عن الإرادة :

الإرادة هي آية القانون ، هذه العبارة الرصينة عبر أمير القانون الدكتور السنهوري عن جوهر وماهية الظاهرة القانونية .
وحقيقة الأمر أن الإفصاح والتعبير عن الإرادة يأخذ مظاهر متعددة، والمطلوب تلمس هذه الإرادة في مضامينها المتعددة وأشكالها التي تظهر بها. ويقرر علماء النفس أنه يسبق التعبير عن الإرادة عملاق تحضيريان هما اتجاه الفكر إلى أمر معين، وهذا هو الإدراك /conception/ يلي ذلك مرحلة التدبر /deliberation/، حيث يزن الشخص الأمر ويتدبره، وأخيرا تأتي مرحلة البت في الأمر وإمضاء العزيمة فيه ، وهذه هي الإرادة ذاتها /volante/ ، فإذا انعقدت الإرادة لم يبق بعد ذلك إلا التعبير عنها وهو عمل خارجي يخلاف المراحل الثلاث الأولى التي هي مراحل داخلية.^١
وهكذا يجب التمييز بين الإرادة الكامنة في النفس والمظهر المادي للمعبر عنها أما الإرادة الكامنة في النفس فهي عمل نفسي يتعقد به العزم على شيء معين ، لكنها تبقى عملا نفسيا باطنيا لا يعلم بها إلا صاحبها اللهم إلا إذا عبر عنها بأحد مظاهر التعبير ، فما هي هذه المظاهر ؟.

^١ د. السنهوري : الوجيز في شرح القانون المدني ، ص ٥٥.

الفرع الأول

التعبير الصريح والتعبير الضمني

تنص المادة /٩٣/ من القانون المدني السوري على ما يلي: «التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفاً كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالة على حقيقة المقصود».

ونجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنياً إذا لم ينص القانون أو ينص الطرفان على أن يكون صريحاً.

والواقع أن التعبير قد يكون صريحاً إذا كان المظهر الذي اتخذه - كلاً ما كان - أو كتابة أو إشارة أو غير ذلك - مظهرًا موضوعاً في ذاته للكشف عن الإرادة حسب المألوف بين الناس، فيكون بالكلام أي بإبداء الألفاظ الدالة على المعنى الذي تنطوي عليه الإرادة، أو يكون بالكتابة بأي شكل من أشكالها، ويكون بالإشارة المتداولة عرفاً كإشارة الأخرس وهز الرأس أو الكتف ولو من غير الأخرس أو يكون بالتعبير الصريح باتخاذ أي موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالة على حقيقة المقصود كعرض التاجر البضاعة على الجمهور أو كوقوف سيارات الإحرة في المواقف المخصصة لها وكوضع آلة ميكانيكية لتأدية عمل معين.

والتصرف القانوني الضمني قراراً كان أم عقداً هو تصرف حقيقي غير حكمي أو مفترض، غاية ما هنالك أنه يستفاد بصورة غير مباشرة من فعل

^١ د. السنهوري: الوجيز في شرح القانون المدني، ص ٥٧ والنظر د. عبد الفتاح حسن: مبادئ

القانون الإداري قضاء الإلغاء، مكتبة الجلاء المصورة ٩٨٢، ص ١٥٢

مادي صادر عن حجة الإرادة ، أو من كلمتها المكتوبة أو المنطوقة^١، ويكون هذا التعبير عن الإرادة ضمناً إذا كان المظهر الذي اتخذته ليس في ذاته موضوعاً للكشف عن الإرادة، لكن لا يمكن تفسيره دون افتراض وجود الإرادة ، مثل القبض على شخص فهو يفيد صدور قرار ضمني بالقبض عليه^٢، ومن ذلك أيضاً أن تعاقد الإدارة مع شخص ، ثم تنتهي المدة العقدية ، ويستمر المتعاقدان في العمل بالشروط ذاتها ، فقد اعتبر ذلك الاستمرار يقوم على إرادة ضمنية للإدارة والمتعاقد^٣، وهذا ما أكدته حكم مجلس الدولة الفرنسي المتضمن^٤ :

La continuation D'un contrat après expiration par un accord tacite.

ومن المظاهر تلك أيضاً أن يتقدم شخص بعطاء حول تقديم معاونه :
après de concoure

، فهنا المتقدم يستطيع أن يسحب عرضه في كل وقت قبل أن تقبله الإدارة ، وهذا السحب قد يتم صراحة أو ضمناً .

ومن قبيل السحب الضمني أن يتصرف الموجه في قطعة أرض كان قد تقدم بها للإدارة مساهمة منه في تنفيذ مشروع عام ، وذلك قبل أن تقبل الإدارة عرضه^٥ .

^١ د. عبد الفتاح حسن قضاء الإلغاء ص ١٥٢

^٢ د. السنهوري : الوجيز في شرح القانون المدني، ص ١٥٩، د. عبد الفتاح حسن : مبادئ القانون

الإداري قضاء الإلغاء، ص ١٥٢

^٣ د. الطماوي : الأسس العامة للعقود الإدارية ص ٣٧٣

^٤ قضية Cte hydraulique المجموعة ص ٣٤٩ تاريخ ١٩٥١/٦/١٥

^٥ حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في ١٨٦٧/٢/٢١ ، قضية lareau المجموعة ص ١٨٧

هذا وإن أي مظهر من المظاهر الصريحة أو الضمنية يكفي عادة للتعبير عن الإرادة ، ومع ذلك فهناك حالات يتقضي القانون فيها بالتعبير الصريح دون الضمني أو يكون الأمر موضع اتفاق خاص بين المتعاقدين حول شكل الإرادة^١.

الفرع الثاني

الإرادة الباطنة والإرادة الظاهرة

قد تختلف الإرادة الداخلية عن مظهرها الخارجي ، كأن يمضي شخص عقدا مطبوعا يتضمن شرطاً لا يقبله لو فطن له أو أن ينزل شخص في فندق على شروط لا يعلمها ، لكنها مكتوبة ومعلنة في غرفته ، وكمن يوصي على أُنثى منزل بطريق التأشير على بيان مطبوع ، فإذا به يوشح على غرفة نومه وهو يريد غرفة استقبال.

والسؤال المطروح هو: أي الإرادتين يجب الأخذ بها ، هل هي الإرادة الظاهرة أم الباطنة؟؟.

القاعدة المعهودة في القوانين اللاتينية أن الإرادة الباطنة هي التي يؤخذ بها في حين أن المدرسة الألمانية تأخذ بالإرادة الظاهرة أي بالمظاهر المادية الموضوعية المحسوسة^٢.

^١ د. السهوري التوحيد في شرح القانون المدني، ص ١٥٢.

^٢ د. السهوري التوحيد في شرح القانون المدني، ص ٥٢.

ولقد تأثر التشريع بالمدرستين الفقهيّتين السالفيّ الذكّر، فهناك تشريعات تغلب الإرادة الظاهرة على الإرادة الباطنة، وتعمل بالنص، ولو تناهى مع حقيقة الإرادة الباطنة^١.

ومهما يكن أمر هذا الخلاف في قواعد التفسير بين التشريعات المدنية المختلفة فإن أكثر التشريعات يأخذ بالإرادة الباطنة إذا كانت أكيدة ومحقة^٢.

ما هي النتائج المترتبة على الأخذ بهذه الإرادة أو تلك، بالذات فيما يتعلق بتفسير العقد ٢٢

لقد رتب الدكتور السهوري على الأخذ بمبدأ الإرادة الظاهرة وفي صدد تفسير العقد الشichtين الآتيين :

١. لا يلزم القاضي بأن يتحسس الإرادة الداخلية فيما تحه سيرة المتعاقدين، بل هو يقف عند المظهر الخارجي للتعبير عن الإرادة، فيفسره تفسيراً اجتماعياً لا تنصباً مستنداً في ذلك إلى العرف الحاري وإلى المألوف في التعامل .

٢. إن مسألة تفسير العقد في مثل هذه الحال تصبح مسألة قانون تخضع لرقابة محكمة النقض مادام الغرض ليس هو تفسير نية المتعاقدين ، بل تفسير نص العقد ، فيكون حكم ذلك هو حكم تفسير نص للقانون ، أما إذا كان التفسير يتجه إلى البحث عن الإرادة الباطنة فهذه مسألة واقع لقاضي الموضوع الرأي الأعلى في ذلك^٣.

^١ د. تروت بلوي ، مبادئ القانون الإداري ، القاهرة : دار النهضة العربية ١٩٦٦ ، ص ١٢٧

^٢ المراجع السابق ، ص ١٢٧

^٣ د. السهوري : الوحي في شرح القانون المدني ، ص ٥٤

أما مجلس الدولة الفرنسي فيأخذ بالإرادة الباطنة ، حتى ولو تسافت مع صراحة التصوص التي اتفق عليها المتعاقدان ، وحتى إذا لم يكن من الممكن الكشف عن تلك الإرادة الباطنة بطريقة أكيدة ومحقة^١.

ومن تطبيقات مجلس الدولة لفكرة الإرادة الباطنة الحكم الصادر في ١٧/٦/١٩٣٨ الخاص بعقد امتياز سكة حديد تضمنت نصاً يضع على عاتق الملزم نفقات تحويل خطوط السكة إذا كان ذلك بسبب إجراء أشغال عامة .

ولقد حدث بعد إبرام العقد أن قامت الحكومة بكهربية خطوط السكك الحديدية فقتضى ذلك نقل أشرطة السكك الحديدية من مكانها ، وقد أرادت الحكومة أن يقوم الملزم بتحمل نفقات هذا النقل امتثالا إلى نص العقد لكن مجلس الدولة فسر العقد على أساس أن أعمال هذا النص مرهون بقاء الظروف دون تغيير ، أما وقد تغيرت الظروف ، وقامت الحكومة بكهربية خطوط السكك الحديدية ، فإنه يجب البحث عن الإرادة الباطنة للمتعاقدين وقت إبرام العقد ، وإن خالفت الإرادة الظاهرة أو الصريحة التي أعلنها العقد ، وهكذا حكم مجلس الدولة بأن المتعاقدين لم يتوقعا وقت التعاقد كهربية خطوط السكك الحديدية ، وبالتالي لا يصح تحميل الملزم نفقات التحويل ، فالإرادة الباطنة للطرفين المتعاقدين وقت التعاقد لم تشمل هذا الحال^٢.

^١ د. ترونت ، بنوي مبادئ القانون الإداري ، ص ١٢٧

^٢ 17^e conseil d'Etat, compagnie des chemins de fer de la Camargue, 17^e juin, 1938, dalloz périodique et critique, 1940, 3^e partie, p. 5

الفرع الثالث

الإرادة المفترضة

هذه الإرادة غير موجودة في القانون المدني لسبب بسيط هو أن هذا القانون يشي نماذج معينة وعامة تنظم إرادات مفترضة نظامية وموضوعية عامة وبمجردة وغير خاصة بعقد ، كما هو الحال بالنسبة للإرادة المفترضة في العقود الإدارية، حيث يفترض في مجلس الدولة تلك الإرادة الذاتية بالنسبة لعقد بذاته.

وبيان ذلك أن القانون المدني كثيرا ما يلجأ عن طريق الصنعة *fiction* إلى تنظيم إرادات الأفراد في مجال العقود وافترض تلك الإرادات نتيجة إلى أغراض معينة في حال سكوتهم عن ذلك ، وهذه هي القواعد القانونية المقررة *déclarative* التي تعبر عن الإرادة المفترضة وتقيمها مقام الإرادة الحقيقية في حال سكوت هذه الإرادة الأخيرة عن تنظيم مجال معين^١ .

والأمر على خلافه بالنسبة للإرادة المفترضة في نظرية العقد الإداري ، فنحن هنا أمام إرادة مفترضة *supposée* بالنسبة لعقد معين ، هذا فضلا عن أن تلك الإرادة ليست الإرادة الصريحة أو الضمنية للمتعاقدين .

وتظهر الإرادة عند تغير ظروف العقد تغيرا يختلف تماما عن الظروف التي أحاطت بالعقد عند إبرامه ، هنا نجد مجلس الدولة يهادر الاتفاق ليبحث عن

^١ د. سليمان مرقس: المدخل للعلوم القانونية والفاهرة المطبعة العالمية ، ١٩٦٧ ، ص ٨٨.

الإرادة التي يمكن أن يلتقي عندها الطرفان المتعاقدان لو أنهما - وقت التعاقد - كانا قد توقعا الظروف الجديدة^١.

ولا شك أن تأسيس هذا الافتراض يقوم على دور المرفق العام في صياغة وإنشاء نظريات القانون الإداري^٢.

وحقيقة الأمر أن تغير ظروف المرفق وانعكاس ذلك على الآلية العقدية والجهود الدؤوب للقاضي الإداري في خلق التوازن الدقيق بين مصلحة الفرد الثابتة ومصلحة الجماعة المتغيرة ،

هذا الأمر هو الفكرة المفتاح "la notion -clef" في القانون الإداري. يجمع نظرياته ومبادئه الكبرى "نظرية التوازن المالي للعقد - نظرية الظروف الاستثنائية - نظرية العقوبات المادية غير المتوقعة الخ".

وقياسا على ما تقدم فإن إقحام الإرادة المفترضة للمتعاقدين في مثل هذه النظريات والمبادئ ، هذا الإقحام يقوم على الابتسار : *anticipée* والتمحل أكثر من قيامه على التعبير عن طبائع الأشياء والنسب المركوزة فيها .

ولنا أن تساءل كيف بالإمكان تفسير مبادئ عامة وردها إلى إرادة ذاتية تنقرى وجودها في عالم العدم ، ثم ننسب إليها أمورا غريبة عنها وخارجة عن طبيعتها^٣.

^١ د. ثروت بدوي مبادئ القانون الإداري ، ص ١٢٨.

^٢ د. ثروت بدوي مبادئ القانون الإداري ، ص ١٢٥ وما بعده انظر د. عبد الهادي عباس : العقود

الإدارية ج ٣ ص ٧ ، وقد اعتبر الاعتماد على هذه الفكرة هملا تعسفا .

^٣ بشاركتنا في هذا الافتراض د. عبد الإله الخافي : القانون الإداري ، مجلد ٤ ، ص ٢٤٢ ، الأستاذ عبد الهادي

عباس : العقود الإدارية ، ج ٢ ، دار المستقبل ، دمشق ١٩٩٩ ، ص ٧ وقد أشار إلى إقحام الإرادة الافتراضية

على هذا الأساس اعتبر الدكتور طماوي علواً مفرطاً رد بعض نظريات القائلون الإداري إلى النية المشتركة مؤكداً في الوقت نفسه أن نية الطرفين تؤدي دوراً كاملاً خارج النطاق الذي تستلزمها الخصائص الذاتية للعقود الإدارية. وبذلك - والكلام للدكتور الطماوي - لا يجوز رد نظرية عمل الأمير *la fait du prince* ونظرية التوازن المال للعقد *l'équilibre financier du contrat* أو نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة *sujétion imprévues* رد ذلك إلى النية المشتركة^١.

وفي نظرنا إن تلك الأحكام التي أصيحت النظريات الأنفة الذكر إن هي إلا قواعد موضوعية لتفسير إرادة الأطراف حسب التحديد الذي قمنا به سابقاً ، وميزنا بين التفسير الذاتي والتفسير الموضوعي .

وتوضيح ذلك أن القضاء الإداري هو قضاء إنشائي *constructive* يستدع القانون ويوصله ويستنه بداة ، وبالتالي فالقاضي الإداري - وأمام تغير الظروف - يبحث عن إجابات وأسس فنية وتقنوية - انطلاقاً من قواعد العدل - لسد هذا النقص ، وهنا ينشئ أحكاماً موضوعية لا تتعلق بعقد معين ، ومن ثم لا يجوز القول إن تلك الأحكام تفسر إرادة ذاتية ، هذا فضلاً عن أنه لا يجوز الافتراض في إطار تلك الإرادة الذاتية بقدر ما يمكن القول إن هذا الافتراض عام وقائم في كل مرة تحدث بها عقبات مادية أو تتوفر شروط عمل الأمير ، وهذا هو عين الأحكام الموضوعية المفسرة لإرادة المتعاقدين ، وهو ما أطلقنا عليه التفسير الموضوعي .

١ في نظرية التوازن المالي د. محمد وسام الدين سوار شرح القانون المدني ، ص ٣٤٤ ، وقد أعاد الأقرار لأنه يلزم على علم الطرفين بالحكم في حين أنهما سمداً ما يجهلان ذلك.

٢ الأسس العامة للعقود الإدارية ، ص ٤١٣

البحث الرابع

نظرية مسح العقد

قلنا سابقاً إن مهمة القاضي تتحدد في القبض على الإرادة المشتركة وتحديد مضمونها ونطاقها والوقوف عند معرفة كنهها دون أن يتجاوز ذلك إلى ابتسار هذه الإرادة واختراقها والخروج على طوائع الأشياء والقوانين المركوزة فيها، فإذا فعل ذلك معدلاً أو معطلاً إرادة الطرفين يكون قد شوه العقد أو مسحه حسب المصطلح القانوني .

ولا حاجة للتأكيد بأن رقابة محكمة القانون ((النقض)) هي بالمفهوم العميق رقابة على المعنى، حتى إن كان المعنى مستخلصاً من الوقائع ((الاستخلاص السائع للمعنى من الوقائع)) .

ويعني أوضح فرقته على الكيف : qualification والأوصاف : caractères legaus والناتج القانونية التي يرتبها القضاة على الوقائع والتصرفات : les consequences juridiques des faits et actes: constutes pars les juges du fond هذه الرقابات اعتبرت رقابات قانونية^١ .

^١ د. محمد عصفور مذاهب المحكمة الإدارية العليا في التفسير والرقابة والإفناء بالقاهرة - المطبعة

العالمية، ج ١، ص ٧

هذا ونشير بأن الرقابة على شروط العقد مسخاً أو تشويهاً وتديلاً أو تعطيلاً هي رقابة قانونية باعتبارها اعتداء على معنى العقد *sens* أو مداه *portée*^١، والأمر نفسه بالنسبة لمسح التصرفات القانونية^٢.

هذا ونوه بأن مجلس الدولة الفرنسي مارس رقابته بصفته قاضي نقض على مسح التصرفات القانونية، وإن كانت هذه أقل حراً من رقابة محكمة النقض، والسبب في ذلك حداثة هذا المجلس بالمقارنة مع القضاء العادي، الأمر الذي لم تتيح الفرصة المناسبة لبثورة نظرية متكاملة عن المسح ولا سيما أن مكان تطبيق تلك النظرية هو التصرفات الظاهرة.

ولعل المثال الوحيد الذي أشار إليه *Bargot* هو رقابة المجلس القانونية بصفته قاضي نقض على مسح قاضي الموضوع لإتفاق^٣، حيث فهم الشراح بأن المجلس أقر ضمناً أن قاضي الموضوع مسح المعنى الواضح لعقد الإذعان^٤: *contrat d'adhésion*.

وبرى الدكتور عصفور أن محكمة النقض خرجت عن مبدأ التقدير الموضوعي المطلق في قضائها المستند إلى فكرة المسح *dénature*، فطبقاً لقضائها المستقر في هذا الشأن، إنه وإن كان من حق قضاة الموضوع أن يفسروا عقود الطرفين فهم لا يملكون إذا كانت هذه العقود واضحة ومحددة أن يشوهوا معناها *sens* أو مداهها *portée*، وهذه الرقابة المتزايدة على الرقاعات لمحكمة النقض الفرنسية في مجال المسح بالنسبة للعقود أو التصرفات حدثت *merty* للقول: في اللحظة الراهنة يمكننا أن نعتبر

^١ المرجع السابق ص ٧

^٢ المرجع السابق ص ٧

^٣ قضية *lessier* مجموعة الأحكام رقم ٢٠، جلسة ١٩٤٧/٥/٦١

^٤ د. عصفور مذاهب المحكمة الإدارية/ص ٢٧

كأمر مستقر أن سلطة قضاء الموضوع في التفسير محددة بالسلطة التي تعطىها محكمة النقض لنفسها في نقض الحكم الذي يمسخ شروط العقد والتصرفات بدعوى تفسيرها .

ولقد تساءل **bujot** ونفى عن النص القانوني الذي تستند منه محكمة النقض حقها في هذه الرقابة على المسخ ، وأشار إلى أن أساس الأحكام الصادرة في هذا الشأن تستند إلى عبارات المادة ١١٣٢ من القانون المدني الفرنسي التي تنفي بأن العقود التي تزعم صحتها تعتبر شريعة المتعاقدين ، وقد استخلصت المحكمة الأعلى الذكر أنه إذا كان قاضي الموضوع يملك تفسير عقود الطرفين ، فهو لا يستطيع تحت ستار التفسير أن يمسح معناها إذا كانت النصوص واضحة .

لكن الفقه وإن أقر الحلول التي انتهت إليها محكمة النقض وأهمية الرقابة التي تخالفت المحكمة لفرضها على قاضي الموضوع إلا أنه لم يتفق على المصدر التشريعي المصطنع إلى حد ما والذي اتخلته محكمة النقض أساساً لسلطتها هذه .^١

أما الأستاذ **Marty** فقد وجد هذا السند في واجب قضاء الموضوع أن يمسوا أحكامهم ، وفي سلطة المحكمة بأن تتحقق من قيمة التنازل القانوني الذي أدى بقاضي الموضوع إلى الحل الذي فرضه .

^١ نفرض فرنسي ١١/١١/١٨٩٢ دالور، ١٨٩٣-١-٨٥

^٢ د. عصفور : مذاهب المحكمة الإدارية العليا ، ص ١٠

البحث الخامس

بعض القواعد في تفسير العقد

مقدمة:

يتضح من هذا العنوان الذي وسما به هذا البحث أننا نقصد من ذلك تلك القواعد العامة الصالحة لتفسير العقد في كافة فروع القانون وبمحللاته. وبيان ذلك أن هنالك قواعد قانونية تعبر عن جوهر فكرة القانون وطبيعتها الثابتة وماهيتها الذاتية، وإذا ما طبقت هذه الفكرة في فرع من فروع القانون فإنما تنطبق باعتبارها تعبر عن الحقائق اليعيشية الثابتة التي توصل عمقا القانون في روحه العامة، وفي النسب المركوزة فيه، ومن ثم فإذا تبناها القانون الإداري مثلا كقواعد وردت في القانون المدني، فهذا لا يعني أنه نقلها مجرد نقل، وإنما طبق فكرة حية تسود بحاله الخاص، وهذا ما عبر عنه الفقيه اليوناني ستاسينبولس بقوله: إن تطبيق القاضي الإداري لإحدى قواعد القانون الخاص لا يعني وجود نقص أو ثغرة في القانون الإداري، فبعمل القاضي على سندها بقاعدة قانونية من قواعد القانون الخاص بمعنى أنه توجد صور قانونية عامة مقررة في كل التشريعات الحديثة كالعقد مثلا، هذه الصور بصرف النظر عن النظام القانوني الذي تنتمي إليه، فهي تطبق على الحالات التي تتلاءم معها سواء أكانت تطوي تحت لواء القانون الخاص أم العام^١.

^١ مطوله في القرارات الإدارية، طبعه ١٩٥٤م، ص ٣٥. انظر: محمد كامل ليلة، مبادئ القانون الإداري.

بيروت دار النهضة العربية ص ٢١٥.

ما هي هذه القواعد العامة لتفسير العقد ؟؟

هذه القواعد هي ^١:

(١) ضرورة الأخذ بالسياق: وبالملاحظات التي أحاطت بالعقد عند إبرامه،
إذ من القواعد الأولية في التفسير أن تحديد معاني الألفاظ يجب أن يحسب
عنه في نطاق العقد بأكمله، وبالتالي فلا يجوز أن يفصل النص عن بيئته
، وإلا كان التفسير مبتوراً أو ناقصاً أو معيباً، كما يجب أن يؤخذ في
الاعتبار جميع الظروف التي أحاطت بالعقد أو أثرت في تكوينه وتكوينه
، وطلعت بالنشأة التي هو فيها ، وهذا أمر مسلم ومجمع عليه ، ففي السراي
الإفريقي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية حول شروط القبول لعضوية
الأمم المتحدة قررت المحكمة ما يلي: ((الواجب الأول على المحكمة أن
تعطي الفاعلية لنصوص هذه المعاهدة مأخوذة في حملتها ووفق المعنى
الطبيعي والعادي لألفاظها ^٢.

وهذا ما أكدته محكمة القضاء الإداري في مصر في حكمها الصادر في
١٩٥٧/٦/٣٠ قالت هذه المحكمة: ((إن عبارات العقد يفسر بعضها بعضاً
، بمعنى أنه لا يجوز عزل العبارة الواحدة عن بقية العبارات ، بل يجب
تفسيرها باعتبارها جزءاً من كل هو العقد، إذ قد تكون العبارة مطلقة ،
لكنها تتحدد بعبارة سابقة أو لاحقة ، وقد تقرر العبارة أملاً بمراد عليه
استثناء قبلها أو بعدها، وقد تكون العبارة مبهمة وتفسرها غلطة وردت في
موضع آخر ^٣.

^١ د. حامد سلطان : القانون الدولي في وقت السلم ، القاهرة ١٩٦٩ ، دار النهضة العربية ، ط ١ ، ص ٢٦١

وما بعدها

^٢ المرجع السابق ، ص ٢٦٢.

^٣ الفقرة رقم ٩٨٣ لسنة ١٩٧٢.

ولقد مضت هذه المحكمة في الحكم الآنف الذكر لتؤكد ضرورة الاستعانة بكافة ظروف الدعوى وملايساتها التي تحيط بالعقد^١. وإذا كان القانون المدني السوري والمصري لم يتعرضا لهذا المبدأ، فقد أحسن القانون الفرنسي الفعل، إذ جاء في المادة ١١٦١ منه مايلي: يجب تفسير كل شرط على ضوء باقي الشروط بحيث إن الاتفاق يعتبر وحيدة كاملة^٢.

(٢) حسن النية: يجب على المفسر أن يفسر نص العقد على أساس مبدأ حسن النية لدى الأطراف المتعاقدة. ووفقاً لهذا المبدأ يجب أن يتم التفسير على أساس أن الطرفين المتعاقدين كانا حين دخولهما في العقد ذوي نيات حسنة أو أنهما يتويان تنفيذاً للالتزامات المتبادلة على أساس ذلك، فهذه الحال هي التي يقضي بها منطق التعاقد وحكمه.

ولا يتصور أن يكون التعاقد ذا قوة ملزمة، وأن يعدد شريعة المتعاقدين، إن كان كل منهما يرتبط بالآخر، ويسود تعاقدتهما سوء النية. إذ من الأمور المسلم بها في كل نظام قانوني مهما تكن درجة تقدمه أو تأخره أن تخلف حسن النية لدى أحد المتعاقدين يجب أن يواحد عليه دائماً لسبب بسيط هو أن فكرة القانون في ذاتها تقوم على هذا الأساس، ولا يمكن إدراكها بدونها، إذ في النظم القانونية كلها - القديم منها والحديث، المتقدم منها والمتخلف، البدائية والقبلية والحضرية يرتب مبدأ سوء النية تطبيق الجزاء

^١ عرض هذا الحكم د. الطمناوي الأسس العامة للعقد - الإخبارية ص ٤١٣

^٢ انظر حكم مجلس الدولة الفرنسية الصادر ١٩٤٤/٦/٢١ قضية Sté d. entreprise المجموعة ص ٢٢

ولا يؤدي إلى ثواب ، وقد تكون الدوافع غير بريئة إلا أن اليات يجب أن تكون حسنة ويفترض دائماً أنها حسنة .

وعلى هذا لم تفرق محكمة القضاء الإداري بين ظروف توفر حسن النية لدى الإدارة ولدى الأفراد فكلهما على قدم المساواة لهذه الناحية^١ :
en pied d' égalité

ومبدأ حسن النية عريق وأصيل في القانون المدني ، ولقد عرّج عليه هذا القانون في أكثر من مقلته^٢ .

٣) أعمال النص : يجب على المفسر أن يقوم بعمله على أساس المبدأ الذي يقضي بوجوب أعمال النص : principe de l' effet utile :
principe of effectiveness

وعلى هذا إذا كانت الألفاظ تنطوي على غموض في معانيها أو تلتبس في دلالاتها ، أو يؤدي تطبيقها إلى ظهور التناقضات ، ونزاع على ذلك كله احتمال وجود تفسيرات مختلفة ، فالمبدأ يقضي بأن مواضع القصور في التعبيرات المستعملة في العقود يجب تكملتها بأفضل ما يكفل بلوغ المقاصد الرئيسية التي أرادها الأطراف المتعاقدون ويكون بلوغ ذلك عن طريق تعليب التفسيرات التي تعمل النصوح على التفسيرات التي لمعلها^٣ .

وتعتبر آخر إذا وجد المفسر نفسه أمام تفسيرين محتملين للنص ، أحدهما يعمل النص والآحر يهمله أو يجعله كأن لا معنى له ، فهنا يجب على المفسر أن يفضل التفسير الأول لأنه ليس من المنطوق أن نفترض أن الأطراف المتعاقدة لم تكن تقصد شيئاً عندما وضعت النص المختلف على

^١ حكمها الصادر في ١٩٥٧/٦/٣٠ السابق الذكر

^٢ انظر على سبيل المثال المادتين ١٤٩ و ١٥١ مدي سوري

^٣ أورد هذا الحكم د. حامد سلطان القانون الدولي وقت السلم ص ٢٦٤

تفسيره، وهذا ما أكدته محكمة التحكيم الدائمة في ٧/أيلول/١٩١٠. قالت :
((إنه لمن مبادئ التفسير المسلم بها أن الألفاظ المستعملة في اتفاق لا يمكن
أن تعد مجردة من المعاني إلا إذا وجد دليل خاص على ذلك).

(٤) عند الشك حد بالأقل : In Duboi Mitau :

مقتضى ذلك أنه إذا كانت الألفاظ المستعملة في العقد يعوزها الوضوح،
وتحتل المعاني المتفاوتة، فالأصل أن نفضل المعنى الذي يحدد الالتزام تحديداً
ضيقاً على ذلك الذي يوسع نطاقه.

فالمرعى الأول هو الذي يستجيب للنية المشتركة لأطراف التعاقد.

وهذا ما أكدته المادة ١٥٢ من القانون المدني السوري، والمادة ١٦٢ مدني
فرنسي بقولهما :

((يُفسر الشك في مصلحة المدين))

وإذا كان من الطبيعي تسويد هذا المبدأ في القانون المدني على فرض أن
المتعاقد لا يحمل نفسه إلا الشعار الأقل، وأن يسود في القانون الدولي لأن
المعاهدات ترد على أعمال السيادة وهذه الأعمال تخضع للتفسير المضيق
stricto-sense:

لأن الأصل عدم تقييد السيادة التي تعني الإطلاق، والتي هي سلطة أصيلة
وأصلية : originaire ونابعة من نفسها، ولا تقبل التقييد في الداخل أو
الخارج إلا على سبيل الاستثناء.

إذا كان الأمر كذلك فهذا المبدأ لا يطبق في مجال القانون الإداري، وهكذا
فإن مجلس الدولة الفرنسي لا يلتزم بنص المادة ١٦٢ مدني التي تقتضي بأنه
في حال الشك يفسر الالتزام لمصلحة المدين، ذلك أن اتصال العقد بالمرفق

^١ د. جامعة سلطان القانون الدولي وقت السلم، ص ٢٦٦.

العام لا يسمح بإعمال تلك القاعدة على إطلاقها لأنه لا يمكن التضييقية
بالصالح العام إطلاقاً^١، ولنا عودة في المستقبل إلى ذلك.

٥) تحرير العقد بأكثر من لغة:

قد تحرير العقد بأكثر من لغة، هنا لا توجد صعوبة إذا اتفق المتعاقدان على
أنه - في حال الاختلاف في المعنى - يرجع إلى العقد الذي أقيم بلغة معينة.
أما إذا لم يكن مثل هذا الاتفاق قائماً، وكان هنالك اختلاف في المعنى
نتيجة لاختلاف اللغات المستعملة، فإن تفسير النص يجب أن يتم على
أساس المعنى الضيق الذي يستلزم للمعاني المثبتة في النصوص المحررة
باللغات المستعملة^٢.

وبعبارة أخرى إذا كان النص المحرر بإحدى اللغات الرسمية يؤدي إلى معنى
واسع، وكان النص المطابق والمحرر بلغة رسمية أخرى يؤدي إلى معنى
ضيق، فإن تفسير النص يجب أن يتم على أساس المعنى الأضيق^٣.

٦) إذا عمل لفظ أكثر من معنى وحب حملته على المعنى الأكثر انطباقاً مع
روح العقد (المادة ١٥٧ من قانون سوري فرنسي)، فعلى سبيل المثال إذا
ورد أن البيع يشمل المنزل وما به من منقولات، فلفظ المنقولات لا يجوز
حمله على ما في المنزل من قيم منقولة (كالأشجار والسيارات)، وإنما يحصل
على أساس منزل فحسب^٤.

وهذا ما أكدته مجلس الدولة الفرنسي في حكمه الصادر في ١٩٣٧/١١/٥^٥.

^١ در الطحاوي: الأسس العامة للعقود الإدارية، ص ٤١٣.

^٢ د. سلطان القانون الدولي في وقت السلم، ص ٢٦٧.

^٣ المرجع السابق ص ٢٦٧.

^٤ د. سوار: شرح القانون المدني المرجع السابق ص ٣١٨.

^٥ قضية départ des contes du nord المجموعة ص ٤٠٠.

البحث السادس

مذاهب التفسير

مقدمة:

يمكن القول إن هذه المذاهب فلتت بحثاً وتفسيراً وتنقيحاً في مختلف أدبيات فروع القانون ، ولذلك فإننا نحيل القارئ إلى مطالعها مبين كتب الفقه الوضعي أو فقه الشريعة الإسلامية .
ومع ذلك فإن إحاطة الكاملة بهذا الكتاب تقضي بالتعريض السريع على هذه المذاهب.

الفرع الأول

مذهب مفهوم المخالفة : argumentation a contrario

يقضي هذا المذهب بأنه إذا ورد النص القانوني حول حال بذاتها ، فمعنى ذلك أن ما عداها من الحالات له حكم آخر بمعنى أن عدم ذكر الحالات الأخرى ينهض دليلاً على إخراج تلك الحالات من حكم النص .
وبالتالي فإذا وجد سبب آخر مقبول يفسر عدم ذكرها ، فالاستدلال لا يتأني بمفهوم المخالفة .

وغني عن البيان أن مفهوم المخالفة يقوم على القواعد المنطقية البحتة التي تستهدف البحث عن نية الأطراف في العقد .

الفرع الثاني

التصريح بذكر شيء لا يقتضي نفياً ما سواه

واستناداً إلى هذا المبدأ فتخصيص حال بالذكر لا يوحد منه أفرادها بالحكم (مادة ١١٦٤ مدني فرنسي).

فإذا باع شخص مزرعة، ونص على أن البيع يشمل المواشي، فليس يعني ذلك أن البيع لا يتناول سائر التوايع المخصصة لاستغلالها، وإنما يحمل النص على المواشي دون غيرها على رغبة المتعاقدين في استبعاد أي شك يشور بشأنها.

الفرع الثالث

مذهب السلوك اللاحق: *subsequent conduite*

كثيراً ما يلجأ المفسرون إلى تفسير الشرط العقدي الغامض على ضوء المسلك اللاحق للطرفين باعتباره دليلاً على ما فهمه الطرفان من معانٍ لاتفاقهما^١.

والبحث في المسلك اللاحق ليس مسموحاً به فحسب في التفسير، بل هو أمر مرغوب فيه، ذلك أن الطريقة التي نقدها الأطراف العقد بصورة فعلية هي السنية، بل هي أحياناً خير البينات على التفسير السليم.

وبيان ذلك أنه إذا كانت نوايا الدين وضعوا النص يكتنفها الشك، أو يلاسه الغموض، أو يصعب التحقق منها، فلا يوجد هذا الشك، ولا

^١ م. سوار: شرح القانون المدني ص ٣١٨

^٢ د. سلطان المرجع السابق ص ٢٧

تقوم مثل تلك الصعوبات فيما يتعلق بالكيفية التي تنفذ بها الأطراف العقد^١. وهذا هو توجه محكمة القضاء الإداري في حكمها الذي سبق الإشارة إليه، والصادر في ١٩٥٧/٦/٣٠، قالت هذه المحكمة: (كما أن من العوامل الخارجية لتفسير العقد الطريقة التي ينفذ بها وتكون متفقة مع ما يوجه حسن النية في تنفيذ العقود^٢)

الفرع الرابع

مذهب التفسير الواسع : interpretation extensive

ومذهب التفسير الضيق : restrictive

كان علماء القانون الإيطاليون (مدرسة علماء الحاشية) يقسمون النصوص القانونية قسمين رئيسين: النصوص المستحقة، والنصوص المستهجنة، وكانوا يذهبون في تفسير النصوص الأولى مذهباً واسعاً من شأنه أن ييسر أحكامها النافعة حتى على الحالات التي لا يتطوي عليها معنى الألفاظ المستعملة، وذلك على أساس أن حكمة النص أو نية الأطراف أن تميز إدخال كل ما يمكن إدخاله من الحالات تحت حكم هذا النص ذي الآثار النافعة من أجل مآل فائدته ومنفعته.

أما النصوص المستهجنة فكانوا يذهبون في تفسيرها مذهباً من شأنه أن يضيق من بسط أحكامها التي تتطوي على التقييد من الأعباء والالتزامات، وذلك عن طريق إخراج كل ما يمكن إخراجها من الحالات من تحت

^١ د. سلطان المراجع السابق ص ٢٧٠

^٢ القضية رقم ٩٨٣ لعام ١٩٥٧، السنة القضائية السابعة

حكمتها حتى ولو كان يبدو أن حكم النص يشملها ، كي تحدد الآثار الضارة للنص في أضيق الحدود^١.

ومذهب التفسير الضيق يقيد عملية التفسير التي تقوم على أساس الواقع بوصفه المذهب الذي يكمل مبدأ وجوب إعمال النص ، فضلاً عن أنه يؤدي وظيفة خاصة هي أخذ العوامل الموجودة في سياق العقد مأخذ الاعتبار ، كما أنه يؤدي إلى أن الاستنتاجات التي قد يصل إليها المفسر يجب أن تقتصر على ما هو ضروري للحصول على الأغراض الرئيسية لأطراف العقد ، فلا يفرض عليهم أغراضاً جديدة أو التزامات تفصيلية لم تنص صراحة عليها ، ومن ثم فوظيفة هذا المبدأ الرئيسية هي المحافظة على كيان العقد وعدم المساس بنصوصه بحجة تفسير أحكامه^٢.

لكن إذا كان التفسير لا ينطلق إلى تحديد المسائل الفرعية فهل ينصدي الشارع إلى تلك المهمة مستنداً إلى تقنياته وإوالياته لا سيما آلية القواعد القانونية التي سبق الإشارة إليها ، هذا هو موضوع بحثنا المقبل.

لكن إذا تعذر معانقة المسائل الفرعية عن طريق آلية التفسير أي إذا تعذر إدخال هذه المسائل في إطار النص عن طريق التفسير ، فما هي الوسائل التي نعتد بها لاحتواء هذه الفرعات وتنظيمها .

لاشك أن تلك المهمة يضطلع بها النص من زاوية أخرى هي زاوية تنظيم الثغرات أو تكملتها.

^١ د. سلطان المرجع السابق ص ٢٧٣

^٢ د. سلطان المرجع السابق ص ٢٧٤

البحث السابع

نطاق العقد و تكملته

هناك ثلاث مسائل يجب تمييز بعضها من بعض : تفسير العقد ، تحديد نطاقه ، كيفية تنفيذه .

ولاشك أن أول ما يجب على القاضي أن يفعله هو تفسير العقد فإذا فرغ من ذلك واستخلص الإرادة المشتركة انتقل إلى تحديد نطاقه ، فلا يقتصر في هذا التحديد على ما ورد فيه وفقاً للإرادة المشتركة ، بل يتجاوز ذلك إلى مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام ، وأخيراً ينتقل القاضي بعد التفسير وتحديد النطاق إلى تنفيذ العقد بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية^١ .

وكما قلنا فالقاضي يسترشد في تحديد نطاق العقد بمستلزماته ، وهذا ما يتضح من نص المادة ١٤٩ من القانون المدني السوري المتضمنة : «ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقدين بما ورد فيه ، لكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة وحسب طبيعة الالتزام . وبوجيز القول فالعوامل التي يسترشد بها القاضي لتحديد ما يلي :^٢

(١) طبيعة الالتزام : nature de l' obligation .

(٢) القواعد القانونية المكملّة أو المفسرة لإرادة الطرفين : supplétoire .

^١ د. السهوري: الوجيز في شرح القانون المدني، ص-٢٣٧

^٢ د. السهوري: الوجيز في شرح القانون المدني، ص-٢٣٨

٣) العرف والشروط المألوفة: usages et clauses de style .

٤) العدالة : équité.

فطبيعة الالتزام تملئ على القاضي أن يستكمل نطاق العقد بما تقتضيه هذه الطبيعة، إذ من باع متجراً وجب عليه أن يسلم المشتري سحلاته.

والقواعد المكتملة تعين القاضي على استكمال العقد فيما تركه المتعاقدان من تفصيلات لم يتوقعها أو تركاها لأحكام القانون، من ذلك مثلاً ميعاد تسليم المبيع ومكانه وميعاد الوفاء .

والعرف يساهم أيضاً في تحديد نطاق العقد فهو يجري مجرى القانون مكماً لنطاق العقد.

وأخيراً يسترشد القاضي بقواعد العدالة في استكمال شروط العقد لتحديد نطاقه، فبائع المتجر يلتزم قبل المشتري ألا ينافسه في أعمال المتجر، وهو التزام تقتضيه العدالة، وإن لم يذكر ذلك في العقد^١.

ولقد أتيح للقضاء الإداري الفرنسي أن يطبق هذا المبدأ المبدئي المتعلق بنطاق العقد^٢.

كما أتيح لمحكمة القضاء الإداري المصري اعتناق نظرية مستلزمات العقد في حكمها الصادر في ١٩٥٧/٦/٣٠، وهو حكم مطّول لختري منه ما يتعلق بموضوعنا، تقول المحكمة : حيث لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد

^١ د. السنهوري: الوحي في شرح القانون المدني، ص ٢٣٩.

^٢ حكمه الصادر في ١٩٤٤/٧/١١، قضية: reczimbaud.

المجموعة ص ١٨٩، وحكمه الصادر في ١٩٥٤/٧/٢، قضية galopin مجلة القانون العام سنة

١٩٥٥، ص ٢٢٧.

عما ورد فيه ، لكن يتناول ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف
والعدالة بحسب طبيعة الالتزام^١.
وفي حكم آخر لهذه المحكمة نطقت بما يلي : ومن حيث إن التزام صاحب
المصلحة بإنتاج عدد معين من الدقيق الصافي من كل أردب من القمح
الذي تقوم بتسليمه إليه سلطات التموين ، ثم مسماعته عن عدم إنتاج هذا
المقدار يجب أن يقوم على سبب قانوني ، وهذا السبب يكون إما بنص من
التشريع أو بنص في لائحة صادرة عن جانب صاحب المطن يمثل هذه
المعدلات المقررة عند إبرامه في العقد مع جهة الإدارة التي تبيع على مرفق
التموين ، وإما باتفاق يتضمن ذكر المعدل المقصود فإذا جاء حلاً من ذلك
فقد يسترشد بما هو من مستلزمات العقد وفقاً للعرف الجاري^٢.
كذلك فقد أكد الفقه الإداري في سيرة ضرورة الاسترشاد بمستلزمات
العقد من أجل تكملته^٣.

^١ القضية رقم ٩٨٣ لسنة ٧ قضائية.

^٢ المحكم الصادر في ١٩٥٧/٦/٢ القضية رقم ٣٤٨٠ لسنة ٩ قضائية

^٣ د. عبد الإله الحاي : القانون الإداري المجلد ٢ ص ٢٤٦

موضوعات الكتاب

تمهيد:

قلنا إن العقد منظومة أو نسق متكامل عراه، و تتواشع خلفائه، وبذلك فالمفروض بأي تفسير أن يعتمد أولاً النطق الداخلي لهذه المنظومة، وإذا أعوزته السبل والوسائل لجأ إلى الوسائل الخارجية كالعادة وطرق تفسير العقد، وغير ذلك من الأمور.

ولقد أدخلنا أيضاً في هذه الطرق وسائل الإتيات، إذ قد يكون لدى أحد المتعاقدين دليلاً على أن مضمون العقد أو نطاقه أو فحواه محمول على معنى من آليات التفسير وأدواته.

ومن جهة أخرى فقد ميزنا بين التفسير الذاتي والتفسير الموضوعي، وقلنا إن التفسير الأخير يضمم قواعد موضوعية وأحكاماً عامة اعتمدها القانون ليعين القاضي في التفسير إذا أعوزته الوسائل في الوصول إلى النية المشتركة، أي إذا واجه القاضي الشك في تغليب معنى على آخر، فهذا يجري القائلون لسد هذه الثغرة.

زد على ذلك فهناك قواعد موضوعية أخرى تساعد المفسر على استخلاص الإرادة الذاتية للمتعاقدين، وبذلك فإن هيكلية الموضوع وإقامة بنائه يقتضي مراعاة هذه الأمور، ومن ثم فتقسيم هيكل هذا الكتاب سيقوم على التقسيم الذاتي والتفسير الموضوعي، وكل من هذين التقسيمين سيتفرع على فصول وأبحاث وفروع وفقاً للآتي :

الباب الأول

التفسير الذاتي للعقد

تمهيد:

سنفرع على هذا الباب فصلين نتكلم في الأول على الطرق والوسائل الداخلية ، وفي الثاني على الطرق والوسائل الخارجية.

الفصل الأول

الطرق الداخلية لتفسير العقد

تمهيد:

وستقسم هذا الفصل إلى الأبحاث الآتية :

- ♦ تفسير الشرط واضح المعنى
- ♦ تفسير الشرط غامض المعنى
- ♦ الأهمية الخاصة لبعض شروط العقد.

البحث الأول

تفسير الشرط واضح المعنى

تمهيد:

سنقسم هذا البحث إلى الفروع الآتية :

- مدى أهمية الشرط الواضح في تفسير العقد.
- تحديد المعنى الواضح المستمد من الشرط الواضح.
- شروط تطبيق المعنى الواضح المستمد من الشرط.

{ الفرع الأول }

مدى أهمية الشرط الواضح في تفسير العقد

(الالتحاضات والمواقف)

ما تحذر الإشارة إليه أن بعض النظم القانونية الحديثة تغلب الإرادة الظاهرة على الإرادة الباطنة وتعمل النص ولو تنافى مع حقيقة الإرادة التي كان يطنها الطرفان المتعاقدان، لكن نظاماً أخرى ترحح الإرادة الباطنة على الإرادة الظاهرة متى كانت أكيدة وثابتة، وأمكن الكشف عنها بصورة متيقنة و محققة.

ومهما يكن هذا الخلاف بين النظم المدنية المختلفة حول قواعد التفسير فبل أن أكثر التشريعات إعمالاً للإرادة الباطنة تستلزم حتى يمكن الأخذ بها على خلاف الإرادة الظاهرة أن تكون الإرادة الباطنة أكيدة ومحقة، وليس نمسة بخلاف في تحديد مضمونها.

وحقيقة الأمر أن للتفسير نطاقاً خاصاً يقتصر على النصوص التي يكتبها
المفوض، أو التي تعمل ألفاظها أو تعبيراتها معانٍ متناقضة، وأن هذا النطاق
لا يشمل الأحكام القانونية ذات المعاني الظاهرة التي لا تؤدي ألفاظها إلى
اللبس أو التشتت، أو بتعبير آخر ليس مسموحاً أن يقوم المفسر بتفسير مدلول
يحتاج إلى تفسير.

١٢٧-١٢٨-١٢٩-١٣٠-١٣١-١٣٢-١٣٣-١٣٤-١٣٥-١٣٦-١٣٧-١٣٨-١٣٩-١٤٠-١٤١-١٤٢-١٤٣-١٤٤-١٤٥-١٤٦-١٤٧-١٤٨-١٤٩-١٥٠-١٥١-١٥٢-١٥٣-١٥٤-١٥٥-١٥٦-١٥٧-١٥٨-١٥٩-١٦٠-١٦١-١٦٢-١٦٣-١٦٤-١٦٥-١٦٦-١٦٧-١٦٨-١٦٩-١٧٠-١٧١-١٧٢-١٧٣-١٧٤-١٧٥-١٧٦-١٧٧-١٧٨-١٧٩-١٨٠-١٨١-١٨٢-١٨٣-١٨٤-١٨٥-١٨٦-١٨٧-١٨٨-١٨٩-١٩٠-١٩١-١٩٢-١٩٣-١٩٤-١٩٥-١٩٦-١٩٧-١٩٨-١٩٩-٢٠٠-٢٠١-٢٠٢-٢٠٣-٢٠٤-٢٠٥-٢٠٦-٢٠٧-٢٠٨-٢٠٩-٢١٠-٢١١-٢١٢-٢١٣-٢١٤-٢١٥-٢١٦-٢١٧-٢١٨-٢١٩-٢٢٠-٢٢١-٢٢٢-٢٢٣-٢٢٤-٢٢٥-٢٢٦-٢٢٧-٢٢٨-٢٢٩-٢٣٠-٢٣١-٢٣٢-٢٣٣-٢٣٤-٢٣٥-٢٣٦-٢٣٧-٢٣٨-٢٣٩-٢٤٠-٢٤١-٢٤٢-٢٤٣-٢٤٤-٢٤٥-٢٤٦-٢٤٧-٢٤٨-٢٤٩-٢٥٠-٢٥١-٢٥٢-٢٥٣-٢٥٤-٢٥٥-٢٥٦-٢٥٧-٢٥٨-٢٥٩-٢٦٠-٢٦١-٢٦٢-٢٦٣-٢٦٤-٢٦٥-٢٦٦-٢٦٧-٢٦٨-٢٦٩-٢٧٠-٢٧١-٢٧٢-٢٧٣-٢٧٤-٢٧٥-٢٧٦-٢٧٧-٢٧٨-٢٧٩-٢٨٠-٢٨١-٢٨٢-٢٨٣-٢٨٤-٢٨٥-٢٨٦-٢٨٧-٢٨٨-٢٨٩-٢٩٠-٢٩١-٢٩٢-٢٩٣-٢٩٤-٢٩٥-٢٩٦-٢٩٧-٢٩٨-٢٩٩-٣٠٠-٣٠١-٣٠٢-٣٠٣-٣٠٤-٣٠٥-٣٠٦-٣٠٧-٣٠٨-٣٠٩-٣١٠-٣١١-٣١٢-٣١٣-٣١٤-٣١٥-٣١٦-٣١٧-٣١٨-٣١٩-٣٢٠-٣٢١-٣٢٢-٣٢٣-٣٢٤-٣٢٥-٣٢٦-٣٢٧-٣٢٨-٣٢٩-٣٣٠-٣٣١-٣٣٢-٣٣٣-٣٣٤-٣٣٥-٣٣٦-٣٣٧-٣٣٨-٣٣٩-٣٤٠-٣٤١-٣٤٢-٣٤٣-٣٤٤-٣٤٥-٣٤٦-٣٤٧-٣٤٨-٣٤٩-٣٥٠-٣٥١-٣٥٢-٣٥٣-٣٥٤-٣٥٥-٣٥٦-٣٥٧-٣٥٨-٣٥٩-٣٦٠-٣٦١-٣٦٢-٣٦٣-٣٦٤-٣٦٥-٣٦٦-٣٦٧-٣٦٨-٣٦٩-٣٧٠-٣٧١-٣٧٢-٣٧٣-٣٧٤-٣٧٥-٣٧٦-٣٧٧-٣٧٨-٣٧٩-٣٨٠-٣٨١-٣٨٢-٣٨٣-٣٨٤-٣٨٥-٣٨٦-٣٨٧-٣٨٨-٣٨٩-٣٩٠-٣٩١-٣٩٢-٣٩٣-٣٩٤-٣٩٥-٣٩٦-٣٩٧-٣٩٨-٣٩٩-٤٠٠-٤٠١-٤٠٢-٤٠٣-٤٠٤-٤٠٥-٤٠٦-٤٠٧-٤٠٨-٤٠٩-٤١٠-٤١١-٤١٢-٤١٣-٤١٤-٤١٥-٤١٦-٤١٧-٤١٨-٤١٩-٤٢٠-٤٢١-٤٢٢-٤٢٣-٤٢٤-٤٢٥-٤٢٦-٤٢٧-٤٢٨-٤٢٩-٤٣٠-٤٣١-٤٣٢-٤٣٣-٤٣٤-٤٣٥-٤٣٦-٤٣٧-٤٣٨-٤٣٩-٤٤٠-٤٤١-٤٤٢-٤٤٣-٤٤٤-٤٤٥-٤٤٦-٤٤٧-٤٤٨-٤٤٩-٤٥٠-٤٥١-٤٥٢-٤٥٣-٤٥٤-٤٥٥-٤٥٦-٤٥٧-٤٥٨-٤٥٩-٤٦٠-٤٦١-٤٦٢-٤٦٣-٤٦٤-٤٦٥-٤٦٦-٤٦٧-٤٦٨-٤٦٩-٤٧٠-٤٧١-٤٧٢-٤٧٣-٤٧٤-٤٧٥-٤٧٦-٤٧٧-٤٧٨-٤٧٩-٤٨٠-٤٨١-٤٨٢-٤٨٣-٤٨٤-٤٨٥-٤٨٦-٤٨٧-٤٨٨-٤٨٩-٤٩٠-٤٩١-٤٩٢-٤٩٣-٤٩٤-٤٩٥-٤٩٦-٤٩٧-٤٩٨-٤٩٩-٥٠٠-٥٠١-٥٠٢-٥٠٣-٥٠٤-٥٠٥-٥٠٦-٥٠٧-٥٠٨-٥٠٩-٥١٠-٥١١-٥١٢-٥١٣-٥١٤-٥١٥-٥١٦-٥١٧-٥١٨-٥١٩-٥٢٠-٥٢١-٥٢٢-٥٢٣-٥٢٤-٥٢٥-٥٢٦-٥٢٧-٥٢٨-٥٢٩-٥٣٠-٥٣١-٥٣٢-٥٣٣-٥٣٤-٥٣٥-٥٣٦-٥٣٧-٥٣٨-٥٣٩-٥٤٠-٥٤١-٥٤٢-٥٤٣-٥٤٤-٥٤٥-٥٤٦-٥٤٧-٥٤٨-٥٤٩-٥٥٠-٥٥١-٥٥٢-٥٥٣-٥٥٤-٥٥٥-٥٥٦-٥٥٧-٥٥٨-٥٥٩-٥٦٠-٥٦١-٥٦٢-٥٦٣-٥٦٤-٥٦٥-٥٦٦-٥٦٧-٥٦٨-٥٦٩-٥٧٠-٥٧١-٥٧٢-٥٧٣-٥٧٤-٥٧٥-٥٧٦-٥٧٧-٥٧٨-٥٧٩-٥٨٠-٥٨١-٥٨٢-٥٨٣-٥٨٤-٥٨٥-٥٨٦-٥٨٧-٥٨٨-٥٨٩-٥٩٠-٥٩١-٥٩٢-٥٩٣-٥٩٤-٥٩٥-٥٩٦-٥٩٧-٥٩٨-٥٩٩-٦٠٠-٦٠١-٦٠٢-٦٠٣-٦٠٤-٦٠٥-٦٠٦-٦٠٧-٦٠٨-٦٠٩-٦١٠-٦١١-٦١٢-٦١٣-٦١٤-٦١٥-٦١٦-٦١٧-٦١٨-٦١٩-٦٢٠-٦٢١-٦٢٢-٦٢٣-٦٢٤-٦٢٥-٦٢٦-٦٢٧-٦٢٨-٦٢٩-٦٣٠-٦٣١-٦٣٢-٦٣٣-٦٣٤-٦٣٥-٦٣٦-٦٣٧-٦٣٨-٦٣٩-٦٤٠-٦٤١-٦٤٢-٦٤٣-٦٤٤-٦٤٥-٦٤٦-٦٤٧-٦٤٨-٦٤٩-٦٥٠-٦٥١-٦٥٢-٦٥٣-٦٥٤-٦٥٥-٦٥٦-٦٥٧-٦٥٨-٦٥٩-٦٦٠-٦٦١-٦٦٢-٦٦٣-٦٦٤-٦٦٥-٦٦٦-٦٦٧-٦٦٨-٦٦٩-٦٧٠-٦٧١-٦٧٢-٦٧٣-٦٧٤-٦٧٥-٦٧٦-٦٧٧-٦٧٨-٦٧٩-٦٨٠-٦٨١-٦٨٢-٦٨٣-٦٨٤-٦٨٥-٦٨٦-٦٨٧-٦٨٨-٦٨٩-٦٩٠-٦٩١-٦٩٢-٦٩٣-٦٩٤-٦٩٥-٦٩٦-٦٩٧-٦٩٨-٦٩٩-٧٠٠-٧٠١-٧٠٢-٧٠٣-٧٠٤-٧٠٥-٧٠٦-٧٠٧-٧٠٨-٧٠٩-٧١٠-٧١١

٢٥٧. حاتم سلطان : القانون الدولي في وقت السلم - ٢٥٧

والحكمة التي يرمي إليها هذا المبدأ ظاهرة، إذ يجب عدم الابتعاد عن النص أو رفض تطبيقه، أو مجانبة حكمه بحجة تفسير مضمونه، مادام النص واضحاً في معناه، ولا ينطوي على اللبس أو الغموض، ومثل هذا النص يجب أن ينطبق بدقة وفقاً للمعنى الطبيعي والعادي للألفاظ^١.

وعلى الرغم من أن هذا المبدأ ((لا يسمح بتفسير مالا يحتاج إلى تفسير))، هو مبدأ قائم على المنطق، إلا أنه يجب أن لا يؤخذ على إطلاقه.

وتوضيح ذلك أن تفسير أي عقد هو عمل منطقي يوجهه وتحكم فيه الإدراك القانوني السليم بقصد التعرف على النية الحقيقية للمتعاقدين في مكان الاتفاق وزمانه، وهذه النية - بقدر ما يمكن التعرف عليها - هي التي يجب أن تقرر معاني ألفاظ العقد، حتى يتم التوفيق بين الكلمات المستعملة والنية المشتركة من جهة وبين تطبيق هذه الألفاظ على الحوادث الخارجية التي اختلفت في شأنها الأطراف من جهة أخرى.

ومن المعلوم أن للألفاظ - بصورة عامة - معاني كثيرة حتى في المعاجم، وبذلك فليس من الصواب أو الحكمة القول بأن ألفاظ العقد الواضحة لا تحتاج إلى تفسير إلا بعد عرضها على محك غرض العقد وأهدافه وإرادة منشئيه، وكثيراً ما حذر الحكماء مدللين بأن وضوح لغة العقد لا يفيد دائماً وضوح المقاصد.

^١ د. سلطان الرجعي السابق ص ٢٥٧، وانظر الرأي الافتائي الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ

Ambatelos في قضية ١٩٥٢/٧/١

وفضلاً عن ذلك فكما أن وظيفة الألفاظ المستخدمة في عقد هي إظهار مقاصده، فإن قيمة هذه الألفاظ في فهم العقد فهماً صحيحاً لا بد أن تتوقف على تحديد العلاقة بين الألفاظ والغايات التي يراد تحقيقها^١.

ذلك أننا حيال منظومة متكاملة ونسق متواشج العرى وبنية جدلية متفاعلة يؤثر كل عنصر في بقية عناصر المنظومة كما أنه يتأثر في بقية هذه العناصر... والحقيقة الحققة هي التعامل الحي والجدلي بين عناصر المنظومة.

هذا هو الموقف العام للفقهاء، وهو موقف يملئ طيناع الأشياء المركوزة في فكرة القانون بذاتها، وبذلك فلنا أن نتساءل عن النهج الذي سلكه في هذا المضمار القانونيين المدني والإداري.

والواقع أن جانباً من الفقه المدني يتجه نحو اعتبار العبارة الواضحة لا تعني دائماً وضوح الإرادة، لأن الظروف الخارجية تلعب - إلى جانب عبارة العقد - دوراً في الإفصاح عن النية المشتركة للمتعاقدين، بحيث يجوز للقاضي أن يعدل عن المعنى المستمد من العبارة الواضحة للعقد بناءً على الظروف الخارجية التي تتضمن معنى مخالف^٢.

ويستند هؤلاء إلى نصوص القانون المدني (٩٠ مصري - ٩٣ سوري) المتضمنة التعبير عن الإرادة يكون باللفظ أو الكتابة وبالإشارة المتداولة

^١ - د. حامد سلطان المرجع السابق ص ٢٥٩.

^٢ - ولیم سلیمان قلائی: رسالة في التعبير عن الإرادة في القانون المدني المصري، دراسة مقارنة، ص ٣١٩-١٩٥٠.

د. السهري: الوسيط، ج ١، صفحة ٣٩١.

٢- سليمان مرقس: شرح القانون المدني الالتزامات ج ٢، صفحة ٢٢٦.

عبد السلام الترماني: بحث في سلطة القاضي في تعديل العقود في المؤتمر السادس للمحاميين العرب بالعمارة

عرفاً، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً بدلالته على الحقيقة المقصودة.

فالتعبير إذاً لا يقتصر على الإفصاح الرئيسي عن الإرادة، بل يجب أن يضم إليه الظروف الخارجية، ولا يمنع التفسير إلا إذا كانت عبارة العقد في مجموعها واضحة، وهذا هو بالذات نظام الإرادة، حيث يستخلص المضمون من التعبير الرئيسي ومن مجموع الظروف الخارجية^١.

ولقد استقر قضاء محكمة النقض في مصر على أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة بأن تعدل عن المعنى الواضح للتعبير الرئيسي إذا وجدت أن النية المشتركة قد ظهرت خارجاً عنها، لكنها إذا ما مارست تلك السلطة أخذت بغير ظاهر العقد فعليها أن تبين في حكمها أسباب عدولها عن المدلول الظاهر، وكيف أفادت صيغة المعنى الذي افتتحت به، ورححت أنه هو مقصود المتعاقدين، بحيث يتضح من هذا البيان أنها قد أخذت في تأويلها باعتبار مقبولة يصح استخلاص ما استخلصته منها، فإن هي لم تفعل كان حكمها معيياً متعيناً نقضه^٢.

ولقد أدلت محكمة النقض السورية دلوها في هذا الموضوع، قالت هذه المحكمة:

وضوح عبارة العقد غير وضوح الإرادة فقد يكون المتعاقدان أساءا استعمال التفسير الواضح، وقصدا معنى وعبرا عنه بلفظ لا يستقيم معه، وعندها يعدل القاضي عن العبارة الواضحة إلى مدلول الإرادة^٣.

^١ وللم سلبمان ثلاثة: المرجع السابق ص ٣٤٠.

^٢ أحمد شوقي محمد عبد الرحمن كتابه قواعد تفسير العقد، ١٩٧٩، القاهرة: المطبعة العربية الحديثة ص ٩.

^٣ مجموعة أحكام محكمة النقض لعام ١٩٧٢ ص ٢٤٠ قاعة ٢٦ وانظر الاجتهاد القضائي في ربع قرن إعداد عزت ضاحي، وأحمد بشر، ص ١٥٣٩.

وفي حكم آخر لهذه المحكمة قالت فيه : إذا كانت عبارة العقد واضحة لكن نية المتعاقدين انصرفت إلى سواها كان من حق المحكمة أن تفسر العقد وفق الإرادة الحقيقية^١

وجاء في حكم ثالث للمحكمة المذكورة مايلي : يجوز للقاضي اعتبار المبلغ المدفوع من قبل المشتري إلى البائع جزءا من ثمن المبيع ، ولو نص العقد صراحة على أنه عربون ، لأن العدول عن المعنى الظاهر للفظ الواضح إلى معنى آخر يقنع بأنه هو الذي قصد إليه المتعاقدان ، مادام أنه يورد الأسباب المعقولة التي تبرر ذلك^٢.

ومع هذا التصويب للأمور من قبل محكمة النقض السورية إلا أننا نرى أحكاما أخرى منافضة للإحكام السابقة الذكر :

- إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها^٣
- إذا كانت عبارة العقد واضحة فهي تعبر عن إرادة المتعاقدين ، ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير^٤.
- هذا وللهيئة العامة لمحكمة النقض حكم بتيم ، وقد أبدت فيه حق المحكمة في العدول عن اللفظ الواضح قالت : إن تكييف المحكمة للعقد بأنه حق شراكة أو عقد عمل بالتعرف من خلاله على نية المتعاقدين دون الوقوف عند النص الحرفي للألفاظ هو من صميم اختصاص القضاء^٥.

^١ مجموعة ١٩٧٤ ص ٦٢ - ٦٤ سنة ٩١ وانظر الاجتهاد القضائي في ربيع قرن السلف الذكر ص ١٥٣٩

^٢ القرار رقم ٥٨٠ - أساس مبدئي ١٩٩٣ تاريخ ١٩٧٦/٦/٣ محامون لعام ١٩٧٦/٥/٢٩ ص ٦٧٣

^٣ القضية رقم ٣٢٠٨ قرار ٥٩٠ تاريخ ١٩٩٢/٣/١٩ محامون لعام ١٩٩٢ ص ٩٠٣ قاعدة ٤٩٩

^٤ قضية ٩٣٦ قرار ٣٠٥ تاريخ ١٩٩٥/٥/١٦ محامون لعام ١٩٩٦/٥/٢٨ ص ٢٨٤ غرفة المختصة

وانظر أيضا القضية ٣٨٦ قرار ٢١٩ تاريخ ١٩٩٥/٧/١٩ محامون لعام ١٩٩٦ ص ٥٤٧

^٥ محامون لعام ١٩٧٦ قاعدة ٤٣٥ ص ٣٣٩

واستطراداً فلمحكمة الاستئناف المدنية في دمشق حكمت عارضت فيه الخروج على المعنى الواضح للعقد قالت : (إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعريف على إرادة المتعاقدين^١).

واضح جداً من أحكام القضاء المدني في سورية وجود تعارض بالنسبة للفظ الواضح، وما إذا كان يجوز الخروج عليه أم لا.

ويبدو أن هذا الخلاف شجر بين ظهراني الفقه على كافة صعيد فروع القانون ، فهناك الجهم الغفير من الفقهاء الذين يرون أنه لا يجوز الانحراف عن عبارة العقد الواضحة إلى معنى آخر تحت ستار التفسير اللسهم إلا إذا تبين للقاضي أن المعنى الذي تدل عليه العبارة الواضحة ليس هو المعنى الذي أنجحت إليه الإرادة المشتركة ، لأن المتعاقدين أساءوا التعبير ، فاستعمال عبارات لا تتفق مع قصده فعلاً، كما إن على القاضي أن يفترض أن المعنى الواضح هو الذي قصده المتعاقدان ، فإذا تم التحول عنه بوجود قرينه يجب تبيان الأسباب^٢.

ومع ذلك فهذه الكثرة الكثيرة من الفقهاء المؤيدة لضرورة الخروج عن المعنى الواضح لا تعدم وجود فقهاء آخرين يتمسكون بالمعنى الواضح ، ولا يجوزون الخروج عليه بأي تفسير، ووجهة هؤلاء هي الآتي^٣ :

^١ القضية رقم ١٥٥٨ قرار ٢٤٦ تاريخ ١٩٨٩/٧/٢٧، محامون لعام ١٩٩٨ قاعة ١٥٣ ص ٧٢٠.

^٢ د. محمد عي الدين سوار : شرح القانون المدني ص ٣١٣ - ح. الأودود نجى : مبادئ القانون - دروس في مبادئ القانون - القاهرة دار النهضة العربية ١٩٧٩ - ٧٦ - ٧٧ - ص ٤٧٥ - محمد سامي عبد الحميد : أصول القانون الدولي العام - جامعة الإسكندرية - مؤسسة شباب الجامعة ط ٢ ١٩٧٤ - ص ٢٠١ و انظر الحشد الكبير من المؤيدين لهذا الرأي أشار إليهم - د. أحمد شوقي عبد الرحمن : قواعد تفسير العقد ص ٨.

^٣ أحمد شوقي محمد عبد الرحمن قواعد تفسير العقد ص ٧٧.

- (١) تضمنت المادة ١٥٠ مديني مصري - ١٥١ مديني سوري مايلي :
- إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.
- (٢) المدكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المصري المدني الجديد ، فقد جاء فيها مايلي :
- لا ريب أن إرادة المتعاقدين هي مرجع ما يرتب التعاقد من آثار ، بيد أن هذه الإرادة وهي ذاتية بطبيعتها ، لا يمكن استخلاصها إلا بواسطة مادية أو موضوعية هي عبارة العقد ذاتها ، فإذا كانت هذه العبارة واضحة لسزم أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة العاقدتين المشتركة ، وليس يجوز الانحراف عن هذا التعبير لاستقصاء ما إذا كانت إرادة العاقدتين حقيقية من طريق التفسير أو التأويل ، وتلك قاعدة يقتضي استقرار التعامل حرصاً بالغاً على مراعاتها .
- (٣) لن يغور والكلام للدكتور أحمد شوقي عبد الرحمن في رأيا استناد أصحاب الاتجاه المخالف إلى النص المادة ٩٠ مديني مصري (٩٢ مديني سوري) التي تميز التعبير عن الإرادة باللفظ والكتابة وبوسائل أخرى ، فهذه المادة ترسم طرقاً متعددة للتعبير عن الإرادة ، واختيار أطراف العقد للكتابة يفضيهم لحكم المادة ١٥٠ مديني مصري .
- (٤) لا تميز المادة ١٦١ من قانون الإثبات المصري الإثبات بشهادة الشهود فيما يخالف أو يتجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي .

^١ مجموعة الأعمال التشريعية للقانون المدني المصري ، ج ٢ ، ص ٢٩٦ .

٥) ينجم القضاء المصري والفرنسي إلى ضرورة التعويل على الإرادة المستمدة من عبارة العقد الواضحة، ولا يجوز رفض تطبيقها أو إهدار حكمها، إذ يتضمن ذلك انحرافاً عن المعنى الظاهر للاتفاق^١.

ويبدو أن الخلاف بين الفريقين الأنفي الذكر نشب حول القوة القانونية والإنائية لعبارة المادة ١٥٠ مدي، وهل إن هذه القوة مطلقة أو نسبية، وبعبارة أوضح هل تعطى العبارة الواضحة قرينة مطلقة لصالح التوضيح، أم إن هذه القوة نسبية. نعتقد أن ما قصده المادة ١٥٠ هي نسبية الحقائق ونسبية القوة القانونية وإلا ألا يمكن أن يسمى المتعاقدان التعبير عن معنى معين، ثم يتضح أن هذا التعبير يتعارض مع الواقع ذاته، فكيف إذن نخضع لهذا التعبير السيئ...؟ وما هو موقف القانون الإداري من ذلك؟

الملاحظ أن القضاء الإداري المصري أخذ بوجهة نظر نسبية قوة العبارة الواضحة، ومعنى أوضح فقد تمسك بالمادة ١٥٠ مدي مصري، لكن على أساس إعطاء العبارة الواضحة قوة نسبية، وهذا ما يتضح من حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في ١٩٥٧/٦/٣٠^٢ الذي غتري بعض فقراته، بقول هذا الحكم: ((إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين، أما إذا كان هنالك محل لتفسير العقد، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعاقد، وبما ينبغي

^١ لقد عرض الدكتور أحمد شوقي للعديد من أحكام محكمة الفسخ المصرية والفرنسية، انظر في ذلك كتابه

قواعد التفسير العقد ص ١١

^٢ القضية رقم ٩٨٣ لسنة ٧ قضائية.

أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات، فهذه القاعدة، وإن كانت مقتنة في القانون الخاص ((المادة ١٥٠ م.د))، إلا أنها تطبق على العقود الإدارية أيضاً، وتقرر أصلاً عاماً في تفسير هذه العقود لأنها تقن مبادئ عملها طبيعة الأمور ومقتضيات العدالة، مما لا يختلف معه روابط القانون الخاص، ومقتضى هذه القاعدة أنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين، إلا أنه لا يجب أن يفهم من ذلك أن العبارة إذا كانت واضحة، فلا يجوز تفسيرها، بل إن القاضي قد يجد نفسه في حاجة إلى تفسير العبارات الواضحة مهما بلغ من وضوحها، ولسن معناها، ولارتفع عنها اللبس والإبهام، ذلك أن وضوح العبارة غير وضوح الإرادة، فقد تكون العبارة في ذاتها واضحة، لكن الظروف تدل على أن المتعاقدين أساءا هذا التعبير الواضح فقصدا معنى، وعبرا عنه بلفظ لا يستقيم، له هذا المعنى، بل هو واضح في معنى آخر، ففي هذه الحال لا يأخذ القاضي بالمعنى الواضح، بل يجب أن يعدل عنه إلى المعنى الذي قصد إليه المتعاقدان، وذلك بشرطين:

❖ الأول هو أن يفترض بادئ الأمر أن المعنى الواضح في اللفظ هو ذات المعنى الذي قصد إليه المتعاقدان، فلا ينحرف عنه إلى غيره، إلا إذا قام أمامه من ظروف الدعوى ما يبرر ذلك.

❖ الثاني هو أن القاضي إذا عدل عن المعنى الواضح إلى غيره، وجب عليه أن يبين الأسباب التي دعت به إلى ذلك.

وعلى مقتضى هذا يكون للمحكمة السلطة التامة في تفسير صيغ العقود الإدارية والشروط والقيود المختلف عليها بما تراه أوفق لمقصود المتعاقدين مستعينة بجميع ظروف الدعوى وملاساتها، ولها هذه السلطة أن تعدل عن

المدلول الظاهر إلى خلافه على أن تبين الأسباب التي من أجلها عدلت عن هذا الظاهر، وكيف أفادت تلك الصيغ هذا المعنى الذي اقتنعت به، ورجحت أنه مقصود المتعاقدين .

وقرب من ذلك ما أكدته المحكمة الإدارية العليا في سورة في حكمها الصادر في ٩٦٢/١٢/٣، قالت المحكمة المذكورة: (بتعين على القاضي استبعاد المعنى الواضح و الأخذ بالمعنى الذي يتفق مع ظروف الدعوى ضمن الشرطين الآتين :

✓ انتقاء الغلط في سياق العبارة الواضحة للشرط.

✓ توافق المعنى الواضح مع هدف العقد.

والملاحظ أن هذين الشرطين هما شرطان سلبيين (شرطا استبعاد) ، والمفروض أصلاً إعمال اللفظ الواضح، والاستثناء هو الإهمال عند تحقق شروط معينة خارجية.

المطلب الأول

استبعاد الغلط في صياغة العبارة الواضحة للشرط التعاقدي

الأصل أنه لا يجوز لأحد المتعاقدين أن يتعلل بوقوعه في الغلط في

التعبير عن إرادته للتفصل من هذا المعنى .

ويختلف الأمر إذا كانت العناصر الداخلية للعقد تؤكد حقيقة الإرادة المشتركة للمتعاقدين.

إذا فالمهم في تفسير العقد استنباط الإرادة المشتركة من عناصر العقد الداخلية، ولا يجوز إثبات الغلط المشترك في الصياغة بناء على الظروف الخارجية لأن ذلك يخالف الدليل الكتابي^١.

المطلب الثاني

دور المكان في تحديد المعنى العادي للفظ

يختلف مكان وجود المتعاقدين، وتختلف الأعراف السائدة في هذين المكانين فيما يتعلق بتحديد معنى اللفظ الوارد في العقد،

قد

فهل نأخذ بالعرف السائد في موطن الموجب، أم المتلقي الإيجاب؟
الراجح هو الأخذ بالمعنى السائد في المكان الذي موجه الموجه إليه الإيجاب^٢، اللهم إلا إذا تبين من ظروف التعاقد أن الموجه إليه الإيجاب يعلم بالمعنى العادي للفظ في المكان الخاص بالموجب.

أما بالنسبة للعقد المكتوب بلغة أجنبية، فقد اعتدت محكمة النقض الفرنسية بالمعنى المقرر في المكان الذي يقيم فيه الموجه إليه الإيجاب^٣.

لكن إذا كان التعاقد بين حاضرين وحرر العقد بلغة أجنبية، فيؤخذ بالمعنى الفني والقانوني الذي تفيده اللغة الأجنبية لعبارة العقد التي تتفق مع النية المشتركة^٤.

^١ د. أحمد خويكي محمد عبد الرحمن : قواعد تفسير العقد المدني ص ١٨ ويمكن ذلك بعد الاستعانة بنظرية العقد ص ٨٢٩.

^٢ د. أحمد خويكي المرجع السابق ص ١٦ وانظر : gounaros : Thèses p.259

^٣ civ.11/juiv. 1943.D.g 1943

^٤ د. أحمد خويكي، المرجع السابق والأحكام التي أشار إليها ص ١٦.

وتحرير العقد بلغة أجنبية ظاهرة تكرر على صعيد القانون الدولي، ولقد
أشرنا سابقاً إلى القواعد التي تحكم التفسير في مثل هذه الحال، وفي نظرنا
إنه يمكن الأخذ بالقواعد الدولية التي سبق الإشارة إليها على اعتبار أن هذه
القواعد تنبع من طبائع الأشياء ومن جوهر الظاهرة العقدية وبالتالي الأعيد
بها على صعيد القانون المدني والإداري.

المطلب الثالث

الوقت الذي يعتد به في تحديد المعنى العادي للفظ
وبداهة أن هذا الوقت هو وقت إبرام العقد^١، ولا يعتد بأي معنى آخر طرأ
على الألفاظ المستخدمة في العقد، كما لا يعتد بالمعنى القديم للفظ الذي
يسبق إبرام العقد، ومع ذلك يمكن إعمال هذا المعنى القديم شريطة أن
يتضمن الاتفاق ما يفيد الأخذ به^٢.

{ الفرع الثاني }

شروط تطبيق المعنى الواضح المستمد من الشرط التعاقدي
قد تبين للقاضي أن استخدام المتعاقدين لتعبير معين، وإن كان واضحاً إلا
إنهما لا يقصدان هذا المعنى بسبب وقوعهما في خطأ في صياغة العقد، كما
قد يظهر أن المعنى الواضح للشرط يتعارض مع الهدف المشترك للمتعاقدین

^١ Demolombe, T. 25, NO. 6, P. 7-

^٢ Larombière, T. 2, no 10, p. 110-

وأن تفسير العقد يقتضي البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ^١.

كما إن محكمة القضاء الإداري في سورية أكدت بأنه يتعين عدم الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ والبحث عن النية المشتركة للمتعاقدين في كل ما شأنه أن يوضح هذه النية، أو ما يدل عليها^٢.

كما أكدت هذه المحكمة أن التفسير اللفظي للعقود يمكن الأخذ به ما لم نصطدم بمقتضيات المنطق والإنصاف، وما لم تكن بخافية للمألوف في الظروف المحيطة في تنفيذ العقود^٣.

وهناك ملاحظة دقيقة حول القوة القانونية للفظ الواضح والموقف من هذا اللفظ من قبل أصحاب المعيار الضيق، فهؤلاء يقبلون الخروج عن هذا المعيار في حالات متعددة كالغلط والخروج على أغراض العقد^٤.

{ الفرع الثالث }

تحديد المعنى المستمد من الشرط الواضح ((وسائل التحديد))

مقدمة:

اتضح لنا سابقاً أن الأصل هو التعامل مع اللفظ الواضح وأن الخروج عليه لا يتم إلا ضمن الحدود الضيقة التي سبق الإلماع إليها، وهي وحود قرينة

^١ المجموعة المدونة القانونية التي فررها المحكمة الإدارية العليا في سوريا لعام ١٩٥٩-١٩٦٢، المطبعة الجديدة دمشق، ص ٩٩.

^٢ الحكم رقم ١١٣، القضية رقم ٢٧٦ لسنة ١٩٦٦، مجموعة المبادئ المقررة في القضاء الإداري لعام ١٩٦٦، ص ٢٩٠.

^٣ القرار رقم ٨٩، القضية ١١١ لعام ١٩٧١ مجموعة مبادئ هذه المحكمة، ص ٣٣٣.

^٤ د. أحمد شوقي محمد عبد الرحمن: قواعد تفسير العقد، ص ١٨ وما بعدها.

تصرف المفسر عن اللفظ الواضح إلى ما سواه.
وتحسب طبائع الأشياء ، فالمقصود باللفظ هنا في المقام الأول المعنى اللغوي
السائد في قوم أو جماعة معينة ، وإن كان كل في من الفون ، أو محال من
محالات الحياة يعتمد لغة وضعية خاصة بهذا المجال ، فهنا يجب الأخذ بالمعنى
الوضعي .

وقد يتفق المتعاقدان على تحديد المقصود بلفظ معين ، عندئذ فشرعية
المتعاقدين هي التي تفرض قوتها القانونية ، كذلك فالعرف هو أحد الوسائل
الوضعية التي تحدد معاني الألفاظ ، وبالتالي إذا ما جرى التعامل على تحديد
معنى معين بلفظ محدد ، عندئذ فهذا المعنى هو المتبع^١ .

ولا يلتفت القاضي إلى ادعاء أحد المتعاقدين بأنه كان يقصد من عبارته
معنى مخالفاً ، فمثل هذا الإدعاء يتضمن مخالفةً وتجاوزاً للدليل المكتوب ، ولا
يجوز إثباته إلا بالكتابة^٢ .

وبوجيز القول ، فالقاضي لا يلتفت إلى الإرادة الخاصة لأحد المتعاقدين إذا
ما تعارضت مع المعنى المستمد من عبارة العقد الواضحة ، طالما أن العقد يخلو
من الإشارة إلى هذه الإرادة الخاصة بأنها توافقت مع الإرادة الحقيقية
للمتعاقد الآخر .

وبالمقابل ففوق كلا المتعاقدين في غلط مشترك يؤدي إلى استبعاد الشرط
الواضح ، وهذا الغلط المشترك يأخذ المظهرين الآتيين :

^١ د. أحمد شوقي محمد عبد الرحمن : قواعد تفسير العقد ، ص ١٥ .

^٢ Tonlicr, T, 6, no. 308 - Laromiere, T, 2, no. 7, p. 108 .

^٣ د. أحمد شوقي محمد عبد الرحمن : قواعد تفسير العقد ، ص ١٤ .

المطلب الأول:

غلط مشترك في عيب من عيوب الإرادة يتعلق

بصفة جوهرية في الشيء.

من المعلوم أن وقوع غلط مشترك من قبل المتعاقدين يصلح أساساً للإبطال بإبطال العقد إذا انصب هذا الغلط على صفة جوهرية في الشيء، وهذا ما تقرره الأصول والمبادئ المدنية والإدارية.

لكن السؤال يثور حول تفسير العقد، وهل يتم ذلك كما توهمه المتعاقدان، أم بناء على حقيقة الصفة الجوهرية التي تعلق بها الغلط؟^١

الحقيقة أن الهدف من التفسير هو الوصول إلى النية المشتركة، إذ يجب أن يكون التفسير وفقاً لما توهمه المتعاقدان، لسبب بسيط هو أنهما لم يكونا على علم بحقيقة الشيء الجوهرية حتى يمكن القول بتوفر النية المشتركة. ولقد أتيح لمحكمة النقض الفرنسية أن تحكم في هذا الشأن فتصدق حكم محكمة الموضوع التي فسرت عقد بيع بضائع خاضعة للرسوم الجمركية تضمن حسم مبلغ معين مقابل هذه الرسوم، حيث أعلت الاتفاق على الرغم من الغلط المشترك الذي وقع فيه المتعاقدان عند تفسيرهما للاتحة الجمركية، ولقد استندت في ذلك إلى أن التحديد الذي توهمه المتعاقدان للرسوم يمثل النية المشتركة^٢.

وعلى الصعيد الإداري فقد أكد الدكتور الطماوي على ضرورة الأخذ بالقواعد المدنية فيما يتعلق بالغلط الذي يحدث في مجال العقد الإداري، سواء أعلق بأشخاص العقد، أم بمحمل التعاقد، أم بطبيعة العقد أم بغير ذلك من الأمور.

^١ eiv.25, about 1856, J.38

وهذا الموقف يجعل القضاء الإداري يسير في ركب قواعد^١ التفسير المتعلقة بالغلط بما يتفق مع موكب القضاء المدني، وهذا ما يتضح من حكم محكمة القضاء الإداري في مصر الصادر في ١٩٥٧/٦/٣٠، حيث عرض لموضوع الإساءة المشتركة عند استعمال اللفظ، كما أن مجلس الدولة الفرنسي اعتمد أحكام القانون المدني في هذا الشأن وفي أكثر من حكم^٢.

المطلب الثاني : غلط مشترك في صياغة الشرط الوارد في العقد :
ومن باب أولى إذا كان الخطأ مادياً ومشاركاً، فهذا الخطأ يصحح على ضوء النية المشتركة، أما إذا كان الخطأ في صياغة شرط عقلي فيشترط لتصحيح النص الواضح مايلي :

١. لا يجوز الاستناد إلى عناصر خارجية عن العقد للقول بوجود التعارض بين المعنى المفهوم من عبارة العقد والنية المشتركة للمتعاقدين، فهذا الاستناد يعتبر مخالفاً وتجاوزاً للدليل المكتوب .

٢. يجوز تصحيح الشرط الواضح إذا تضمنت العناصر الداخلية للعقد ما يشير إلى وقوع الخطأ المشترك، وعندئذ يتم التصحيح على أساس هذه النية المشتركة^٣.

ما هي انعكاسات ذلك على صعيد قواعد الإثبات؟؟
❖ يرى فريق من الفقه عدم جواز إثبات الغلط في الصياغة إلا بالكتابة^٤.

^١ كتابه الأسس العامة للعلوم الإدارية، دار الفكر العربي، القاهرة، ط٢، ١٩٦٥، ص٣٨٣.

^٢ د. أحمد شوقي عبد الرحمن : قواعد تفسير العقد ص٢٣، نفس مدني مصري، ١٩٠/١٠/١٩٦٩.

المجموعة سنة ١٩٥٠ عدد ١١ رقم ٣٤٤

^٣ د. أحمد شوقي عبد الرحمن ص٢١.

^٤ من هذا الرأي Faurent جزء ١٩، فقرة ٤٨٠ - Baudy et Bardi جزء ١٥، فقرة ٢٥٧١

❖ وعلى العكس من ذلك، فهناك فريق يرى أنه يجوز إثبات الغلط في التعبير عن الإرادة المشتركة في جميع وسائل الإثبات الداخلية أو الخارجية، أي يمكن أن يستدل من الظروف على أن المتعاقدين أساء استعمال التعبير ومن هذه الظروف مراكز أطراف العقد وصفاتهم ومهمتهم، وغير ذلك^١.

المطلب الثالث: الرقابة القضائية على الغلط المشترك

لصياغة الشرط العقدي ((بعض التطبيقات القضائية)).

وفي ما يلي بعض الأحكام على ذلك :

• حكم محكمة النقض الفرنسية الصادر في ١٨٦٥/١١/٢٢، حيث صححت الخطأ المادي بعد أن تبين لها أن المعنى الواضح للشرط يتعارض مع النية المشتركة المستمدة من عناصر العقد الداخلية، وهكذا فقد حددت عدد الأبقار ليس على أساس ما ورد في العقد، بل على ضوء مساحة الأرض المبيعة^٢.

• حكم محكمة النقض الفرنسية الصادر في ١٨٨٩/٦/١٩، إذ صحح على ضوء النية المشتركة للمتعاقدين الخطأ في تحديد مكان نافذة، كما أقر المتعاقد على فتح النافذة في مكان يطل على فناء الحار، ويختلف عن المكان المحدد في الشرط لتحقيقاً لنية المتعاقدين^٣.

ونطبقاً للمبدأ نفسه أصدرت هذه المحكمة حكماً في ١٩٢٦/٧/١٢ أكدت فيه حكم محكمة استئناف Davaï الذي صحح الخطأ المادي في صياغة عبارة العقد إعمالاً للنية المشتركة للمتعاقدين المستمدة من عقد المقاولات

^١ جزء ١ مقالة ٢٦٦ وانظر د. السنهوري الوسيط جزء واحد مقالة ٣٩١.

^٢ Req. 22 nov. 1865, s. 1866, T. 23.

^٣ Req. 19 juin, 1859, s. 1890, T. 112.

الذي ينص فيه أنه لا يجوز لأطراف العقد الرجوع على كشوف الحساب بعد مراجعتها من المهندس بحجة الغلط، أو السهو أو تغيير قيمة المواد الأولية، أو أجرة اليد العاملة، أو قيمة أي تكاليف أخرى. وقد فسرت محكمة الموضوع هذا الشرط على ضوء النية المشتركة للمتعاقدين، ولم تطبقه على الغلط أو السهو الأكيد الناتج عن النسيان أو الخطأ في الحساب، حيث يمكن إعادة تصحيح كشوف الحساب، وهكذا فقد اعتبرت أنه قد وقع غلط من هذا القبيل بحضور المفاوض على مبالغ نفدية مقابل الرسوم المقررة على المواد المستخدمة في البناء، وقد تبين أن المجلس المحلي قد أعفاها من أية رسوم.

وقد قضى أيضاً بأن قاضي الموضوع يمكنه أن يستخلص غلطاً مادياً في صياغة شرط ورد في الوصية، حيث كتب سهواً بأن المنقولات هي المال الموصى به، ولكنه تبين أن عبارة الوصية في مجموعها تفيد أن نية الموصي تنحصر إلى الإيلاء بالعقارات، وليس بالمنقولات.

وقد ذهبت محكمة الاستئناف المختلطة في ١٢/٦/١٩٤٦^٢ إلى عدم اعتبار التسمية الواردة في العقد للشيء المبيع، إذا كانت الصفات المتفق عليها لهذا الشيء تفيد وقوع غلط في هذه التسمية.

وعلى العكس إذا كانت عبارة العقد واضحة، فلا يجوز إثبات وقوع غلط مادي في صياغته، استناداً إلى عناصر خارجية، وإن ذلك يتضمن خروجاً على قاعدة عدم جواز إثبات ما يخالف

^٢ Req 9 Mai 1870, D.P 1871, 1, 6, Dijon, 21 juill, 1869, D.p. 1870, 174.

^٣ Appel Mixte, 12, 1946, Buill, de leg et juris, Egypt, 59, 17.

أو يجاوز الكتابة إلا بالكتابة، وتطبيقا لذلك فقد قضي^١ بأنه إذا كانت عبارة الوصية واضحة في تعيين الموصى له باسمه ولقبه ودرجة قرابته، فلا يجوز الاستعانة بالشهادة وإثبات غلط الموصي، بأنه كان يقصد تعيين شخص آخر له نفس اللقب ودرجة القرابة، ولكنه يختلف في الاسم عن الموصى له المعين في الوصية.

الفرع الرابع

توافق المعنى الواضح مع الغرض المقصود من التعاقد
لاشك أن لكل عقد غرضه الخاص المحمول عليه والذي يمتزج بالنية المشتركة للمتعاقدين، هذا فضلا عن أن الأحكام التفصيلية لشروط العقد، إن هي إلا وسائل لتحقيق هذا الغرض، ومن ثم فإذا ما وجد تعارض بين الغرض والحكم التفصيلي للشرط، فالغلبة للعنصر الأول، حتى ولو اتسم الشرط بالوضوح في العبارة.

هذه الأهمية للغرض حددت القانون المدني المصري السابق إلى معالجة ذلك في المادتين ١٣٨-١٣٩ المتضمنتين:

- يجب تفسير المشارطات حسب الغرض الذي يظهر أن المتعاقدين قصدا منه، ومهما كان المعنى اللغوي للألفاظ المستعملة فيها.

كما أن المادة ٢١٥ من المشروع التمهيدي للقانون المصري الجديد نصت على مايلي:

^١ - Req. 23Fev. 1863. D. p. 1863. I. 171, obser. Vations Nachet conseiller rapporteur -

إذا كان هنالك محل لتفسير العقد، وجب البحث عن النية المشتركة دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبالغرض الذي يظهر أن المتعاقدين قد قصدها.

ولقد حذفت لجنة المراجعة عبارة ((وبالغرض الذي يظهر أن المتعاقدين قد قصدها)) اكتفاء منها بعبارة: فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين^١.

وبيان ذلك أن الغرض المقصود من العقد يمثل النية المشتركة للمتعاقدين، وبذلك فعدم مراعاة هذا المقصد يجعل تفسير العقد حرفياً وهذا أمر حرص المشرع على تفاديه^٢.

هذا ونوه بأننا لا نقصد بالاستبعاد المعنى الحرفي لتجاوز معنى عبارات العقد بناء على الظروف الخارجية التي توضح النية الحقيقية للمتعاقدين، إذا أن ذلك من شأنه إثبات عكس المعنى المستمد من عبارات العقد المكتوب^٣، وهذا ما تفادت الوقوع به الفقرة الثانية من المادة ١٥١ مدي سوري المتضمنة: ((أما إذا كان هنالك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين، وفقاً للعرف الجاري في المعاملات).

^١ مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني، جزء ٢، ص ٢٩٨.

^٢ د. أحمد شوقي محمد عبد الرحمان: قواعد تفسير العقد، ص ٢٤.

^٣ نقض مدي مصري: ١٢/٣/١٩٣٥، المجموعة الرسمية سنة ١٩٣٦، ١١٤، ص ٢٦٩.

وعلى ذلك ينبغي أن يستخلص العرض المقصود من عبارات العقد
ذاتها وهذا ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون
المدني المصري بقولها :

((يراعى أن ذلك العرض يتوخى في استخلاصه التزام
الظاهر، وفقاً لعبارة النص))

ولا يجوز للقاضي إهمال العرض المقصود من التعاقد وإلا تعرض حكمه
للإلغاء وإذا لم يتضح العرض من العناصر الداخلية للعقد فلا يجوز الانحراف
عن المعنى الظاهر لعبارة الشرط بحجة تعارضه مع الهدف المشترك الذي تدل
عليه عناصر خارجية، فذلك يخالف الدليل المكتوب .

هذا وقد أكد الفقه الإداري في سوربة على ضرورة تفسير العقد على ضوء
الهدف الذي يتجه إليه أطراف العقد^٢.

ما هو الموقف العام للقضاء الإداري من مسألة المعنى الواضح ؟
في الحقيقة لقد أتيح لهذا القضاء أن يدلي دلوه في هذا الموضوع في أكثر من
حكم :

- فهو يبحث عن النية الحقيقية للمتعاقدين دون أن يفسر عند ظاهر
النصوص الواردة في العقد^٣.
- وهو يعمل الشروط التي ترد في العقد على أقرب المعاني اتفاقاً مع نية
الطرفين، وما تؤدي إلى ترتيب آثار عليها، وذلك في حال احتمال تلك

^١ مجموعة الأعمال التشريعية للقانون المدنى، ج ٢، ص ٢٩٧ .

^٢ د. عبد الإله الخاني: القانون الإداري، ج ١، ص ٢٤١ .

^٣ حكمه في ١١/٥/١٩٣٧، قضية: députés du Nord .

الجمعية، ص ٩٠، ١٩٥١/٦/٥، قضية: Cie de l'épau .

الجمعية، ص ٣٠، ١٩٥١/١/٣٠، قضية: Site citroyen .

الشروط لأكثر من معنى^١.

- وهو يجعل العقد وحدة كاملة، بحيث يفسر كل شرط على ضوء الشروط الأخرى^٢.

وهذا هو عين موقف مجلس الدولة المصري، حيث أكد أن تخصيص حالة بالذكر لا يجعلها تفرد بالحكم، وإن عبارات العقد يفسر بعضها بعضها، بمعنى أنه لا يجوز عزل العبارة الواحدة عن بقية العبارات، بل يجب تفسيرها باعتبارها جزءاً من كل هو العقد، فقد تكون العبارة مطلقة ولكن تحددها عبارة سابقة أو لاحقة، وقد تقرر العبارة أصلاً يرد عليه استثناء أو قبلها أو بعدها^٣.

ولقد سار الفقه السوري الإداري في سيرة شوطاً واسعاً في هذا المضمار حيث أكد^٤:

((على القاضي أن يتجاوز التعابير التي يستخدمها الأطراف والبحث عن إرادة هؤلاء الأطراف الحقيقية سواء لاستبعاد أخطائهم الظاهرة، أم لتمييز تناقض تلك التعابير، أم حتى لإعطاء المعنى المناسب لبعض الأحكام العقدية ونلمس الهدف الذي يتجه إليه أطراف العقد ... كما أن ثمة قاعدة لا تقل عنها، وهي أن الاتفاق يشكل كلاً لا ينجزاً لهذا يجب تفسير النود إحداها بالمقارنة مع الأخرى. ثم إن قاعدة أن الاتفاق يلزم ليس فقط بما قام التعبير عنه، ولكن بما يقتضيه أيضاً الاتفاق والتعامل الذي يسمح به القانون حسب طبيعة الأشياء)).

^١ حكمه ١٩٣٧/١١/٥ المشار إليه سابقاً

^٢ حكمه في ١٩٣٧/١١/٥ قضية: Ste citroyen المجموعة ص ٢٢

^٣ محكمة القضاء الإداري: ١٩٥٧/٦/٣٠ القضية رقم ٩٨٣ لسنة سبعة قضائية.

^٤ د. الحلبي: القانون الإداري، مجلد ٤ ص ٣٤١

البحث الثاني

تفسير الشرط الغامض

مقدمة :

عرجنا سابقاً على حال تفسير الشرط الواضح، حيث عرضنا
للاتجاهات المختلفة حول ذلك ، وقلنا إنه يجب على
القاضي أن يعزل أسباب خروجه على المعنى الواضح، ثم يجسد ومساائله في
ذلك؟

والسؤال المطروح هو : ما هو موقف القاضي عند تعامله مع نص غامض
، هل عليه الالتزام بالتعليل؟؟

قبل الإجابة على ذلك لا بد من التعرّيج البسيط على مدى الالتزامات
الملقاة على عاتق القاضي :

♦ عليه أولاً أن ينظر إلى العقد كوحدة متكاملة، والقول بغير ذلك يعني
تمزيق أوصاله ، وهذا التمزيق تنتقل آثاره إلى تمزيق إرادة المتعاقدين والتعامل
معهما كحقيقة مبعثرة ، وهذا ما يتعارض مع طبائع الأشياء المتماهية في
العقد .

♦ التعامل مع منطقة العقد قاصدين من ذلك الملبسات والظروف السابقة
و اللاحقة لإبرام العقد (حالات التنفيذ) .

- ♦ عدم تفسير أي بند من بنود العقد بمعزل عن بقية البنود، وإلا فهذا التفسير فاسد، وبعض النظر عن صحة تفسير البند^١.
- ♦ يتعين على قاضي الموضوع التوفيق والتقريب بين شروط العقد المختلفة باعتبارها مظاهر للنية المشتركة، فإن أعوزه ذلك رجع المعنى الذي يتفق مع قصد المتعاقدين المستمد من عبارات العقد في جملة^٢.
- ♦ إذا تبين للقاضي أن أحد هذه الشروط مبهم حاز له استبعاده^٣.
- ♦ لا يجوز للقاضي تفسير الشرط الغامض بمعزل عن الشرط الواضح إلا إذا ثبت وجود تعارض بين مختلف نصوص العقد^٤.
- ♦ لا يجوز استبعاد الشرط الواضح بحجة وجود شرط آخر غامض إذا لم يكن هنالك تعارض مطلق بينهما^٥.
- ♦ يتعين على القاضي عند استحالته غموض النص أن يستعين أولاً بالمعنى المستمد من عبارته لأن الاعتماد على العناصر الخارجية عن العقد قد يؤدي إلى مفهوم يتعارض مع المعنى الذي تدل عليه عبارته^٦، وهذا ما يخالف الدليل الخطي، وهو الأمر الذي أكدته محكمة النقض السورية

^١ نقض مدني مصري : ١٩٣٩/٣/٢٣، مجموعة القواعد القانونية التي قررتها هذه المحكمة، ج ٢، ص ١٨٤٦.

المجموعة الرسمية سنة ١٩٤٠، ص ٤٩٦.

^٢ د. أحمد شوقي محمد عبد الرحمان : قواعد تفسير العقد، ص ٢٩ وانظر الأحكام الفرنسية والمصرية التي أشار إليها.

^٣ Civ. 29 juin, 1948, D. 1948, 554.

^٤ Civ. 5 juin, 1948, D. 1948, 266.

^٥ Civ. 29 juin, 1948, D. 1948, 554.

^٦ د. أحمد شوقي محمد عبد الرحمان : قواعد تفسير العقد، ص ٣٠.

بقولها : ((لا يسمح الاجتهاد بسماع البينة الشخصية في حال الغموض والالتباس في الدليل الكتابي ^(١))).

♦ يتعين على القاضي الاستعانة بعبارات العقد في مجموعها لتحديد معنى معين لعبارة تحتل أكثر من معنى ، أو لتخصيص العبارة العامة ، أو لعدم تخصيص الحكم على الحال التي ذكرتها.

♦ على القاضي أن يفسر غموض النص على ضوء غرض العقد.

وعلى ضوء جماع ما تقدم فنفسر العبارة الواضحة بشر المسائل الآتية :

(١) احتمال العبارة لأكثر من معنى.

(٢) تخصيص العبارة العامة.

(٣) عدم تخصيص الحكم على الحال التي وردت في العقد.

(٤) تفسير الغموض على ضوء غرض العقد.

هذا وسنقوم بشرح هذه البنود وفقاً للتفصيل الآتي :

{ الفرع الأول }

تحديد معنى معين لعبارة تحتل أكثر من معنى

هنا يستند القضاء إلى نصوص العقد في يحملها على ضوء نية المتعاقدين ، وبأخذ ذلك الطريقتين الآتيتين :

(١) الاستعانة بالنصوص المختلفة في تفسير معنى العبارة الغامضة.

(٢) الاستعانة بموضوع العقد.

^١ قاعدة رقم ٤٦٤ أساس ٩٥ قرار ١٧٠ تاريخ ١٩٨٣/٢/٩ هامون لعام ١٩٨٣.

المطلب الأول

الاستعانة بالنصوص المختلفة في تفسير معنى العبارة الغامضة

والمثال التطبيقي على ذلك حكم محكمة استئناف باريس الصادر في ١٣/٢/١٨٩٤^١ المتعلق بتفسير عقد إيجار ميدان للسباق، فقد ورد فيه نص بزيادة القيمة الإيجارية على السباق الزائد على الثمانية عشر، وقد تار الخلاف حول تفسير هذا النص، وهل تسري الزيادة في القيمة الإيجارية على كل سباق على حده أم على اليوم الذي يزيد فيه استخدام السباق على العدد المحدد، ولقد استعانت المحكمة بنصوص العقد المختلفة لاستخلاص النية المشتركة، فتبين لها أنها تنجّه إلى حساب الزيادة على اليوم الواحد. ولقد أيدت محكمة النقض الفرنسية حكم قاضي الموضوع^٢ في نزاع حلص حول تفسير عقد إيجار تضمن حق المستأجر في ثلث الأغصان المقطوعة من الأشجار الخاصة بالمؤجر، وقد شجر الخلاف حول تحديد حق المستأجر في قطع الأغصان، وهل يتحدد في كافة الأغصان المتفرعة من الأشجار، أم يجب ترك قدر منها من شأنه أن يزيد حجم هذه الأشجار. ولقد أخذت المحكمة بالتفسير الثاني مستهدية في ذلك بروح العقد وبمجملة نصوصه.

وهذا ما أكدته محكمة النقض السورية بقولها: استظهار ما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين المشتركة من عبارات العقد لا تراقب في ذلك محكمة

^١ - D.P.1894,2,430

^٢ - Req.15,dec,D.p.1903,1,448

الموضوع إذا كان استخلاصه قائما على مصادر موجودة في الدعوى ومؤدية إلى النتيجة التي قررتها في حكمها^١.

وقولها : محكمة الموضوع تستقل في تفسير العقد، والوقوف على إرادة المتعاقدين، وقد استظهرت بأن البيع كان بائنا معجزا، وأن المحكمة استمدت هذا التفسير من عبارات هذا العقد^٢.

وقولها : لا يتقيد القاضي في فهمه للعقد بمادة واحدة من بنوده، وإنما يستخلص مضمونه من مجمل بنوده وعباراته^٣.

وهذا ما أكدته محكمة النقض الإداري في مصر في حكم مطول أجتزئ منه العبارة الآتية : قد تكون العبارة مبهمة، وتفسرها عبارة وردت في موضع آخر^٤.

وهذا ما أكدته محكمة النقض السورية بقولها : تفسير العقد في حال علم وضوحه يكون من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها من محكمة النقض^٥.

^١ محامون لعام ١٩٨٧، قاعدة ١٠٨، ص ٢٨٦، قضية رقم ٨٤٥ قرار ١٦٥٧ تاريخ ١٠/٢٥/١٩٨٧.

^٢ نقض مدني قرار ١١٢٩ أساس ١٠٤٦، ١٢/٩/١٩٧٥، محامون لعام ١٩٧٦، ص ٢٨١، قاعدة ٣٥٦.

^٣ محامون لعام ١٩٧٩، قاعدة ١٧٣، ص ١٣٢، قرار ١٧٠٤، أساس ١٥٩٠، ١٢/٢٨/١٩٧٨.

^٤ ١٩٥٧/٦/٣، قضية رقم ٩٨٣ لسنة ٧ قضائية.

^٥ القضية رقم ٢٦٠٣، قرار رقم ٧، ١/١٥/١٩٩٢، محامون لعام ١٩٩٢، قاعدة ٩٢، ص ٦٠٥.

المطلب الثاني

الاستعانة بموضوع العقد في تحديد معنى معين لعبارة العقد

لكل عقد أحكام معينة تتوافق مع طبيعته ، ومن ثم فاتفق المتعاقدان على نوع العقد يقيد رضاءهما على الأحكام التي تنسق معه^١. وبذلك يجب استبعاد المعنى الذي يتعارض مع طبيعته ، فإذا تخرج أحد الورثة على قضية في الميراث ، فهذا يعني أنه تنازل عن جميع حقوقه في التركة ، ولو كان بعضها مجهولاً^٢.

وهذا ما حكمت به محكمة النقض الفرنسية مؤيدة قاضي الموضوع الذي قضى بالتعويض على البائع عن تسليم الشيء المبيع على الرغم من الشرط الوارد في العقد الذي يعفيه من الالتزام بالتعويض في حال عدم التسليم ، وقد قرر القاضي أن القصد المشترك للمتعاقدان المستمد من روح العقد يحصر نطاق تطبيق هذا النص على حال التسليم المتأخر للشيء المبيع وموافقة المشتري على ذلك ، ولا يطبق على حال الإمتناع النهائي عن التسليم ، وهذا ما يتوافق مع الطبيعة القانونية للعقد .

ذلك أن توسيع حكم الإعفاء من التعويض ليشمل عدم التنفيذ النهائي للالتزام بالتسليم يتعارض مع صفة هذا العقد ، إذ أن ذلك من شأنه أن يضع المشتري تحت رحمة التقدير الإرادي للبائع ، ويزيل جزاء عدم تنفيذ

^١ حسن عامر : القوة الملزمة للعقد ، القاهرة طبعة ٩٤٩ فقرة ١٦٧ .

^٢ د. عبد الرؤوف يحيى : دروس في مبادئ القانون ص ١٧٥ .

الالتزام بالتسليم، مما يفقد العقد الفائدة المرجوة، وهو أمر لا يمكن أن يقصده المتعاقدان^١.

كذلك فقد قضت محكمة استئناف باريس بأن الرجوع عن الوصية هو أمر يمثل أحد الخصائص الأساسية لهذا العمل القانوني، وبذلك فإن النص في الوصية على جواز الموصي بالرجوع في وصيته هو تزييد لا أثر له، ويتعين تفسير النص الذي يجيز للموصي الرجوع في الوصية في أي وقت فلا بتقييد مدة معينة طالما اتجهت نيته إلى الإبقاء^٢.

وفي حال تعارض أحد الشروط مع الآثار القانونية المترتبة على الطبيعة الخاصة للعقد، فهنا يعني وجود غموض في عبارة العقد، يجيز للقاضي أن يهدر الشرط الوارد فيه، بحيث يستمد التفسير من موضوعه^٣.

وإذا كان هنالك شك في تحديد معنى العقد حاز للقاضي أن يأخذ بالتفسير الذي يجعله صحيحاً^٤.

هكذا استبعدت محكمة الاستئناف المختلطة اعتبار العقد شركة بسبب نوافر الأهلية لدى الحارس القائم بإبرامه فضلاً عن تضمينه شرط أسد يؤدي إلى إبطال عقد الشركة، وبالمقابل فقد اعتبرت العقد إنجاًراً، لأن الشروط الواردة فيه لا ترتب بطلان عقد الإنجاء^٥.

ولقد أتبع لمحكمة النقض في سورية أن تدلي ببلوها بهذا الموضوع مؤكدة ضرورة تفسير ألفاظ العقد على ضوء طبيعته والتي هي توريد كمية

^١ لورد هذا الحكم د. أحمد شوقي عبد الرحمان مرجع سابق ص ٣٢.

^٢ Paris, 4, dec. d 1957, Samm. 45, 1996/9/1.

^٣ محكمة الاستئناف المختلطة بوايط د. أحمد شوقي محمد عبد الرحمان المرجع السابق ص ٣٣.

^٤ Toulier, T6, W. 321-.

^٥ Appel mixte, 15 Avril, 1930, Bull de leg et de juris, egypt, 42-.

الشوندر^١، وهذا هو عين ما قامت به محكمة القضاء الإداري في مصر في تفسير كلمة نور الواردة في عقد استغلال مقصف لمبنى حكومي، إذ فسرت هذه الكلمة - التي تعمل أكثر من معنى للنور - على ضوء طبيعة العقد^٢.

{ الفرع الثاني }

تخصيص العبارة العامة

قد ينصرف الاتفاق إلى مجموعة أموال أو حقوق، فعندئذ يجب تعميم حكم الاتفاق ليشمل كافة العناصر المتعلقة بهذه المجموعة، حتى ولو لم يكن المتعاقدان على علم بما وقت التعاقد، طالما أن النية تنحى إلى التعامل مع المجموعة المتكاملة الكلية للأموال مجردة من العناصر الداخلة فيها^٣، فلو تخارج مؤثر على نصيبه في الميراث، فإن تنازله يمتد إلى جميع حقوقه الموروثة حتى ولو كان جاهلاً وجود بعضها^٤، اللهم إلا إذا ظهر في العقد أن قصد الطرفين يقتصر على التعامل على أساس الأشياء التي يعرفونها وقت التعاقد، كما لو كانت هذه الأموال التي يجهلونها لا يتوقع أحد وجودها كمحوريات ثمينة لا ينتظر أحد أن تشملها التركة^٥.

^١ حكمها الصادر في ١٩٧٦/٢/٢٤ قرار ١٥٦ أساس مدني ١٢٧٢ بحامون لعام ١٩٧٦ قاعدة ٤٦ =

٤٣٢ =

^٢ حكمها الصادر في ١٩٥٧/٣/٣ /مجموعة أحكام المحكمة لسنة ١١ - ٢٣٨.

^٣ - Demolombe, T.25, No.31.

^٤ - Demolombe, T.25, no.31, Baudy et Barde, v.12, No. 567.

^٥ أحمد شوقي عبد الرحمن قواعد تفسير العقد - ٣٤

ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ، بل يتناول مستلزماته وفقاً للقانون والعرف بحسب طبيعة الالتزام (المادة ١٤٩ مدني سوري) وهذا ما يتفق مع النية المشتركة للمتعاقدین التي تنحى إلى اعتبار الالتزام وملحقاته مجموعة متكاملة.

فعقد الكفالة يمتد إلى الفوائد القانونية والاتفاقية ، طالما أن العقد لم يتضمن عكس ذلك^١.

وبالمقابل إذا كان موضوع الاتفاق أموالاً محددة ، فالعبارة العامة في العقد تحدد بشروط العقد الأخرى التي تخصص عموميتها ، بحيث ينحصر نطاق الاتفاق في حدود الحقوق المالية موضوع التعاقد^٢.

وقد تضمن التفتين السوري نصاً يتعلق بعقد الصلح ، إذ حصر نطاقه بالنزاع الذي يتعلق به (المادة ٥٢٣ مدني) ، وبالتالي فقد أوجبت هذه المادة تفسير عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسيراً ضيقاً ينصب على الحقوق التي كانت وحدها بصفة حلية محلاً للنزاع الذي حسمه الصلح . وهذا هو موقف محكمة النقض المصرية المتضمن مايلي : أيأ كانت العبارات المستحكمة في العقد سواء أكانت عامة أم خاصة بالتنازل ، فلا تنصب إلا على الحقوق التي كانت وحدها بصفة حلية محلاً للنزاع الذي حسمه الصلح (مادة ٥٥٥ مدني مصري).

كذلك فقد قضت محكمة النقض الفرنسية في نزاع خاص بتفسير وصية بأن لفظ الابن الوارد فيها يفيد الابن الشرعي و الابن الطبيعي أو بالتبني ، لكن

^١ د. السنيوري : نظرية العقد ، ص ٢٠٠

^٢ حكم محكمة الاسكندرية المتعلقة ، ١٩١٦/٤/١٤ وانظر د. أحمد شوقي عبد الرحمن المرجع السابق ص ٣٤٠.

لمحكمة الموضوع أن تخصص عمومية هذه العبارة عند تفسيرها للوصية بقصرها على الابن الشرعي استناداً إلى نصوص الوصية ذاتها^١.

كما قضت محكمة الإسكندرية المختلطة بأن الاتفاق على توريد بنزين دون تحديد الكمية، هذا الاتفاق يتحدد بهدف المتعاقدين من التوريد، وهو تشغيل المصنع الخاص للطرف الآخر من العقد، وبالتالي فإن كمية البنزين تتحدد على أساس الكمية المعقولة اللازمة لتشغيل هذا المصنع^٢.

ولقد ذهبت محكمة النقض المصرية إلى أن الشرط الوارد في عقد التأمين بضرورة حصول قائد السيارة المؤمن عليها على رخصة قيادة سليمة يستلزم أن تكون لدى السائق رخصة قيادة لنوع السيارة المؤمن عليها، ولا يكفي الحصول على رخصة قيادة لسيارة من نوع آخر، ولا تضمن شركة التأمين المؤمن له على التلغيات التي تحدث لسيارة يقودها سائق لم يحصل على رخصة قيادة لنوع السيارة نفسها المؤمن عليها^٣.

وفي جميع الأحوال فإن تخصيص العبارة العامة الواردة في العقد يعتبر مسخاً له إذا لم يتضمن عناصر العقد الداخلية ما يفيد هذا التخصيص.

^١ Req. 18, oct. D.P. 1933.1.187. Not. c. pylon.

^٢ الإسكندرية المختلطة: ١٩١٣/١١/١٩ تورد هذا الحكم د. أحمد شوقي عبد الرحمن فواعظ تفسير العقد ص ٣٧.

^٣ نقض مدني مصري: ١٩٦٥/٢/١٠ مجموعة النقض المدنية، سنة ١٣ رقم ١٢٣ ص ١٤٨ نقض مدني مصري ١٩٩٦/٩/٧ مجموعة النقض المدنية سنة ١٣ رقم ١٢٨ ص ٧٦٥.

ولقد أكدت محكمة النقض السورية أن الصلح كاشف للحقوق يفسر تفسيراً ضيقاً وأن بطلان جزء منه يفيد بطلان العقد كله إلا إذا تبين أن الطرفين توافقاً على استقلال أجزائه^١.

{ الفرع الثالث }

تفسير الشرط العقدي المقتصر على تخصيص حال معين

نصت المادة ١٠٦٤ من القانون المدني الفرنسي على أن تخصيص حال بالذكر لا يجعلها تنفرد بالحكم.

والسؤال المطروح هو : هل يمكن اعتبار تلك المادة قد قررت مبدأ عاماً من مبادئ التفسير؟؟

وحقيقة الأمر أنه لا بد من الإشارة إلى أن القياس بنوعيه الإيجابي أو القياس بمفهوم المخالفة ، هذا القياس أمر ظني على ما قرره أغلب علماء الأصول في الفقه الإسلامي.

وعلى ذلك يجب استبعاد القياس بمفهوم المخالفة ، إذ أن إعماله يؤدي إلى نتيجة عكسية مقتضاها أن الاهتمام بالنص على حال معينة يفيد اختلاف الحكم المطبق على الحالات الأخرى التي لم ينص عليها ، إذ أن تطبيق قاعدة

^١ خامون لعام ١٩٨١ قاعدة ٦٣٨ ، حكم محكمة النقض السورية رقم ٦٠٢ ، أساس ٣١٥٧ تاريخ ١٩٨٢/٣/٣.

القياس بمفهوم المخالفة يؤدي إلى تفسير ظني، وقد لا يتوافق مع القصد المشترك للمتعاقدين^١.

والواقع أن اهتمام المتعاقدين بإيراد حال معينة قد يرجع إلى تخوفهما من الشك الذي قد يحيط بهذه الحالة بالذات، أو إلى أهميتها الخاصة لدى المتعاقدين، أو لجرد النص عليها على سبيل المثال توضيحاً لموضوع التعلق، وأياً كان الهدف الذي سعى إليه المتعاقدان في ذكر هذه الحال فاستبعاد الحالات الأخرى التي لم يذكرها العقد يتعارض مع نيتها المشتركة^٢.

ومع ذلك فقد يقصد المتعاقدان من تخصيص حالة معينة انفرادها بالحكم دون الحالات الأخرى التي سكت عنها العقد.

وهنا يثور التساؤل عن ورود حال على سبيل المثال أو الحصر وكيفية إحلاله وبالطبع فهذا الإحلال يتم عن طريق العقد ذاته، وبالتالي فإذا لم ينضج من العناصر الداخلية، أمكن اللجوء إلى العناصر الخارجية السابقة أو المصاحبة أو اللاحقة على إبرام العقد، وهذا هو فحوى نزاع يتعلق بتفسير عقد تأمين^٣ حيث حدد هذا العقد نوع الدراجة النارية وقوتها، لكن المؤمن له قام بشراء دراجة نارية من نوع آخر تساوي من حيث القوة قوة الدراجة النارية المؤمن عليها، وهكذا أثبت النزاع حول ما إذا كان عقد التأمين ينحصر أثره على الحوادث الناجمة من استخدام الدراجة النارية المحددة في العقد، أم أنه يمتد إلى الدراجة النارية التي اشتراها المؤمن له.

^١ - Laurent, t. 1, 16 No. 513.

^٢ - المرجع السابق.

^٣ - المرجع السابق.

ولقد تقصت محكمة الموضوع النية المشتركة من خلال عمل نصوص العقد فأتضح لها أن البيانات الخاصة بالدراجة النارية ليست شروطاً أساسية في العقد، حيث ورد شرط قرر صراحة أنه يترخص للمؤمن له في حال إصلاح الدراجة أن يستلخدم أخرى مملوكة للغير شريطة ألا تزيد قوتها على قوة الدراجة المؤمن عليها، وهذا يعني أن الاعتبار الرئيس الذي علق عليه المتعاقدان كل الأهمية هو قوة الدراجة وقد تبين أن الدراجة التي اشترها المؤمن له تتساوى في قوتها مع قوة الدراجة المعينة في العقد، إذاً فعقد التأمين يغطي الحادث^١.

وإذا كانت المحكمة لم تنقيد بتفسير الشرط تفسيراً مضيقاً كما في الحال السابقة، فهناك حالات أخرى تدفع المحكمة إلى مثل هذا التفسير الضيق، كما في حال الشروط الخاصة بالإعفاء من المسؤولية، حيث ينحصر تطبيقها على الحال التي وردت بشأنها^٢.

ولقد أتبع محكمة القضاء الإداري في مصر أن تفصل في مثل هذا الموضوع في حكمها الصادر ١٩٥٧/٦/٣٠^٣، قالت هذه المحكمة :

((إن تخصيص حالة بالذكر لا يجعلها تنفرد بالحكم)).

^١ د. أحمد شوقي محمد عبد الرحمن قواعد تفسير العقد ص ٣٨.

^٢ د. أحمد شوقي محمد عبد الرحمن قواعد تفسير العقد ص ٣٨.

وانظر Durand, these, No, 144.

^٣ سبق الإشارة إلى هذا الحكم وتوثيقه انظر الدكتور الطماوي : الأسس العامة للعقود الإدارية ص ٤١٦.

{ الفرع الرابع }

تفسير الشرط الغامض بناء على غرض العقد

لا شك أن غرض العقد هو علته الغائية، والمهدف منه، وهو عنصر هام من عناصره، وبذلك تبدو الحاجة ملحة لتفسير غموض العقد على ضوء غرضه^١.

وهذا هو محتوى حكم محكمة الاستئناف المختلطة المتعلق بتفسير عقد بيع قطعة أرض ورد فيه شرط يلزم المشتري بإقامة منزل حسن البناء من الناحية الهندسية، حيث تبين للمحكمة أن المهدف هو خلق حي جميل النيسان في المنطقة، خاصة أن القصر الذي يمتلكه البائع يلاصق الأرض المنيبة، وأن الاهتمام اتجه إلى سرعة البناء بتحميل قصره، ورفع قيمة الأرض التي لم يتم بيعها.

وعلى ضوء ذلك فسرت المحكمة غموض الشرط لجهة تحديد مدة المشروع و الانتهاء من البناء، ورفضت ادعاء المشتري [أنه حر في اختيار الوقت الذي يروق له في إقامة البناء والانهاء منه، بحجة أن الشك يفسر لمصلحة المدين، إذ أن هذه القاعدة لا تطبق إلا في حال عدم تبين النية المشتركة للمتعاقدين^٢، وهكذا فقد ألزمت المشتري بإقامة البناء خلال مدة معقولة حددتها بثلاث سنوات.

^١ - Alexandria Mixte, 274, 1899, Bull, de leg. et juris, egypt, 11, 197-

^٢ - Alexandria Mixte, 19, Nov, 1913, Bull, de, leg. et juris, egypt, 26-

كما قصت هذه المحكمة بأن الاتفاق على توريد بسزين لمصنع دون تحديد الكمية، إنما يجب تفسيره وفق الغرض الذي قصده المتعاقدان، وبمما يلي احتياجات المصنع.

وفي هذه الإطار أبدت محكمة التقض المصرية حكم قاضي الموضوع الخاص بتفسير شرط وارد بعقد البيع بترك مسافة معينة من البناء المجاور، وعدم شغله بالبناء، حيث بنت المحكمة تفسيرها على الغرض الذي قصده المتعاقدان، وهو عدم إشغال الأجزاء المتروكة من العقار المرتفق به ببناء تحجب النظر أو تعيق الهواء والنور عن العقار المرتفق، ثم طبقت ذلك على الشرفة المختلف عليها، فرأت أنه لا يمكن اعتباره من المباني بالمعنى الذي قصده المتعاقدان، إذ أن الشرفة أشيدت من حديد مفرغ لا تحجب النظر، ولا يعيق سير الهواء، ولا يمنع أشعة الشمس والنور عن المنزل المرتفق.

البحث الثالث

مدى الأهمية الخاصة لبعض شروط العقد

تمهيد :

يواجه قاضي العقد شرطاً مألوفاً يتكرر في عقود أخرى مشابهة، فهل يترجم هذا الشرط النية المشتركة للمتعاقدين، أم أنه لا أهمية له ؟؟

قد

وقد يتضمن العقد شروطا مطبوعة وأخرى مكتوبة ،وهنا يثور التساؤل عن مدى التزام القاضي بهذه الشروط وصلاحيته في تفضيل بعضها على بعض .
وهناك ملاحظة استطرادية مفادها أننا أدرجنا الشرط المألوف في منظومة التفسير الذاتي ،أي اعتبرناه إحدى الأدوات التي تفسر النية المشتركة ،وبالتالي لم نعتبره عادة ،بل فصلناه عن العادة ، ودرسنا العادة من خلال الطرق الخارجية لتفسير العقد .
وفيما يلي الحالات التي تقتضي معالجتها بالنسبة للشرط المألوف .

الفرع الأول

أهمية الشرط المألوف في العقد

يقصد بالشرط المألوف ذلك الشرط الذي يتكرر بالنسبة لنوع معين من العقود ، ويثور التساؤل عن هذا الشرط ومدى سلطة القاضي في إهماله بمقولة إن طرفي العقد نصا عليه على سبيل المحاكاة دون أن يعبر عن النية المشتركة .

والواقع أن الأصل هو إعمال النص ، وعدم استبعاد الآثار القانونية المترتبة على إعمال الشرط ، وهذا الإثبات لا يجوز أن يتم بالنسبة للعقد المكتوب إلا بالكتابة .

وعلى ذلك فلا يجوز إهمال النص المألوف إلا إذا تحقق مايلي :

« تعارض الشرط المألوف مع النية المشتركة المستمدة من العناصر الداخلية للعقد .

« تعارض الشرط المألوف مع نص قانوني آخر .

وفيما يلي توضيحا لذلك :

{ المطلب الأول }

تعارض الشرط المألوف مع النية المشتركة للمتعاقدين

المستمدة من العناصر الداخلية للعقد

تمهيد :

إن تفسير الشرط المألوف على ضوء النية المشتركة المستمدة من نصوص العقد في مجموعه تطبيقاً للقاعدة العامة المتضمنة عدم بخرئة العقد، وبذلك يجوز للقاضي أن يهمل الشرط المألوف إذا تبين له تعارضه مع النية المشتركة المستمدة من نصوص العقد وروحه¹.

وقد يتضمن العقد نصاً يكذب الشرط المألوف، أو يشتمل على نص يعكس قصد المتعاقدين ويتعارض مع الشرط المألوف، وأخيراً فإن قصد المتعاقدين المتعارض مع الشرط المألوف قد يستبين من مجموع نصوص العقد.

البند الأول

العقد المتضمن مخالفة للشرط المألوف

لاشك أنه يجب استبعاد الشرط المألوف إذا تضمن العقد ما يفيد تكذيبه لمضمون هذا الشرط، وهذا ما يتضح من حكم محكمة النقض الفرنسية الذي صدق حكم قاضي الموضوع القاضي بمسؤولية وكيل الدعوى لأنه لم يذكر بعقد البيع حق الارتفاق الذي يتقل العقار المبيع، ولم تعد المحكمة بالشرط المألوف في العقد الذي يقرر عدم استلامه مستندات الملكية، واستندت المحكمة

¹ - Durant, thes, 2, 15, D. 52-Planiol et Repert par Eisman, L6, No. 373.

في ذلك إلى أن تسليم وكيل الدعوى مستندات الملكية أمر حتمي لإمكانية تسجيل العقد وعلى ذلك قضى باستبعاد الشرط المألوف موضوع النزاع الذي أعناد وكلاء الدعوى إدراجه في مثل هذه العقود^١.

البند الثاني

تعارض الشرط المألوف مع شرط آخر يعكس القصد

الحقيقي للمتعاقدين

قد يصاغ الشرط المألوف بعبارة كما أن العقد قد يشتمل نصا آخر خاصا بتعارض مع الشرط المألوف، فهنا نتحدد العبارة العامة للشرط المألوف بالنص الخاص فيما يتعلق بالحالة التي اشتملت عليها.

هكذا قطعت محكمة النقض الفرنسية بأن لقاضي الموضوع سلطة تفسر قائمة الشروط الخاصة بالاتفاق على بيع العقار الشائع، حيث يوجد تعارض بين نصين الأول يجيز إعادة البيع بالمزاد العلني لعدم توفر الشروط الخاصة بالمزايدة، والثاني ينص بأن رسو المزاد على أحد الملاك على الشيوع يتضمن رضا جميع الملاك الآخرين باختصاص كل منهم بحصة من الثمن الذي رسي عليه المزاد^٢.

ولقد قدرت محكمة الموضوع أن النص الأول يعتبر شرطا مألوقا، وأنه ورد في عبارة عامة، وبذلك فهو يفقد كل اثر قانوني بالنسبة للحال التي تضمنتها في النص الثاني والتي تتعلق برسو المزاد على أحد الشركاء على الشيوع.

وعلى العكس يمكن إعمال الشرط الخاص بإعادة البيع بالمزاد في مواجهة المالك على الشيوع الراسي عليه المزاد عن الوفاء بالالتزامات التي تقع على عاتق أي

^١ Civ. 29, oct. 1928, D. II, 1928, 315.

^٢ د. أحمد شوقي محمد عبد الرحمان: قواعد تفسير العقد ص ٤٢.

^٣ 29, oct. 1928, d. II, 1928, 574.

تخص برسو عليه كإمتناعه عن دفع معدل القسمة الناتج من فروق الأنصبة بالرغم من وجود شرط آخر يقضي باختصاص الشركاء بأنصبتهم في المال الشائع، إذ أنه في مثل هذه الحال لا يوجد تعارض بين الشرطين، فتخصيص عبارة النص ينحصر في عدم إعادة البيع في المراءد العلني عند رسوه على أحد الشركاء، أما فيما عدا ذلك فيجب تطبيق أحكام البيع بالمراءد التي تقضي بإعادة البيع بالمراءد عند تخلف المشتري عن الوفاء بالالتزامات التي تنقل الراسي عليه المراءد^١.

{ المطلب الثاني }

تعارض الشرط المألوف مع النية المشتركة

وهذا تطبيق للقواعد العامة، وهو ما أكدته محكمة النقض الفرنسية بالنسبة للشرط المألوف في عقد بيع قضى بإعفاء البائع من الضمان بالنسبة لحقوق الارتفاق التي تبين أنها تنقل العقار المبيع، ويفقد هذا الشرط أهميته بالنسبة لحقوق الارتفاق الظاهرة، حيث يفترض فيها أن البائع قد أشترط عدم الضمان^٢، أو على العكس فإن أهمية الشرط تظهر في حال وجود حقوق إرتفاق خفية تنقل العقار المبيع، لكن قد يتعارض الشرط المألوف بإعفاء البائع من الضمان مع قصد المتعاقدين، وهكذا فقد ميز القضاء الفرنسي والمصري بين الحالتين :

الأولى عندما يذكر في عقد البيع حق الارتفاق الذي يتقل العقار المبيع .

^١ - Montpellier, Savril, 133 gaz. pal, 1933, 1890 -

^٢ د. أحمد شوقي محمد عبد الرحمان قواعد تفسير العقد ص ٤٠.

في هذه الحال تنوافر إرادة المشتري وإرادة البائع على إعفاء الأخير من حق الارتفاق الذي أشار إليه العقد^١.

ويكفي أن يحيل العقد إلى المستندات التي تبين وجود حق الارتفاق الخفي^٢.
الثانية : وتتمثل في حلو العقد من أي ذكر لحق الارتفاق الخفي الذي يتقل العقار المبيع لا سيما أن هذا الحق قد يبلغ من الأهمية الأمر الذي يمتنع معه على المشتري إبرامه للعقد لو كان يعلم به.

والمثال على ذلك يتضح في حق ارتفاق بعدم إقامة بناء بالنسبة لمشتري كان يقصد البناء من شرائه للأرض ،فلا يعمل في هذا الحال بالشرط المألوف الذي يعلي البائع من الضمان لتعارضه مع الية المشتركة للسنعاقدين.

{ المطلب الثالث }

تعارض الشرط المألوف مع نص قانوني آمر

ويتفرع على هذا البحث مايلي :

البند الأول

بطلان الشرط المألوف

وهذا أمر طبيعي و تختص الأصول العامة ،ومع ذلك فقد قضى ببطلان شرط عدم الضمان الوارد في عقد البيع بالنسبة لحقوق الارتفاق الخفية التي ترجع إلى فعل البائع ،ويبقى هذا الأخير مسؤولا عنها لأن الشرط يتعارض

^١ -Dijon,29Mai,D.P,1889,213-

^٢ د. أحمد غزوي محمد عبد الرحمن قواعد تفسير العقد ،ص ٤٤٠ وقد اعتمد في ذلك حكم محكمة

الإسكندرية المحتلة والصادر في ١١/٢/١٨٥٩

مع نص القانون الذي يقضي بمسؤولية البائع عن أي استحقاق ينشأ من فعله، وببطل كل اتفاق خلاف ذلك ((المادة ٤٤٦ مدني مصري - ٤١٥ مدني سوري))، ولا يستطيع البائع التخلص من المسؤولية إلا إذا ثبت علم المشتري وقت التعاقد بحق الارتفاق وموافقته على تحمل نتائج ذلك^١. ويتور التساؤل عن مدى إعمال الشرط المألوف بعدم ضمان حقوق الارتفاق التي تنقل العقار المبيع إذا كان المشتري لا يعلم بذلك، ولكنه كان يستطيع العلم به.

وتظهر أهمية هذا التساؤل في ضرورة تسجيل التصرفات القانونية لإنشاء أو نقل الحقوق العينية الواردة على عقار البائع ومن ثم فليس هنالك ضمان في مواجهة البائع إذا كان التصرف المنشئ لحق الارتفاق ليس مسجلاً بسبب عدم نشوء هذا الحق، وعلى العكس إذا كان التصرف القانوني مسجلاً هنا ينشأ حق الارتفاق، لكن هل يعني ذلك الإعفاء من الضمان بمجرد أن المشتري كان يستطيع أن يعلم بنشوء الحق المذكور، وذلك لإطلاعه على السجل العقاري.

لعل الإجابة عن هذا التساؤل تتوقف على ما إذا كان البائع يلتزم بإعلام المشتري بحقوق الارتفاق الحقة التي تنقل العقار المبيع، أم أن على المشتري الاستقصاء عن مدى حلو العقار من تلك الحقوق^٢.

القاعدة العامة هي : أن البائع يلتزم بضمان حقوق الارتفاق الحقة التي لم يكن قد أبانها للمشتري^٣ ((مادة ٤٤٥ مدني مصري))، إذن يقع على عاتق البائع الالتزام بإعلام المشتري عن هذه الحقوق التي تنقل العقار المبيع^٤.

^١ - المرجع السابق، ص ٤٤٤.

^٢ د. أحمد شوقي عبد الرحمان قواعد تفسير العقد ص ٤٥٥.

وفضلاً عن ذلك فالمادة ٤٤٦ مدين مصري تشترط علم المشتري بسبب الاستحقاق وقت البيع لإعفاء البائع من الضمان ، ولأن تكفي باستنطاعة علم المشتري ، ذلك أنه مما يتنافى مع المبادئ العامة أن يحتج في مواجهة المشتري بأنه أهمل القيام بعمل لم يلزمه به القانون ، بينما يتمتع البائع عن واجب فرضه القانون عليه^٢.

وعلى ذلك فلا يكفي لإعفاء البائع من الضمان أن يكون التصرف القانوني المنشئ لحق الارتفاق الخفي قد سجل بتاريخ سابق على البيع لأن هذا التسجيل لا يعفي البائع من التزامه بإعلام المشتري عن حقوق الارتفاق الخفية ولا يستطيع بالتالي أن يحتج بالتسجيل لإعفاءه من ضمان الاستحقاق بحجة أن المشتري كان يستطيع أن يعلم بحق الارتفاق الخفي الذي ينتقل العقار المبيع^٣.

والذي يعزز هذا الرأي أن البائع ملزم بالضمان إذا تبين أن العقار المبيع منقول بحق رهن على الرغم من أن قيد هذا الحق في السجل العقاري يجعل من اليسير على المشتري أن يعلم بوجود هذا الحق . وقد يعترض على هذا الرأي بأن المشرع أعفى البائع من الضمان بالنسبة لحقوق الارتفاق الظاهرة ((٤٤٥ مدين مصري)) ، ولا يرجع ذلك إلى علم المشتري بها إذ قد لا يعلم بها حقيقة ، وإنما يقوم هذا العلم على مجرد استطاعته العلم بمثل هذه الحقوق.

Req, 30 dec, 1940, D c, 1941, Note carbonnier egypt, 21, 228-

Alexandrie Mixte, 11, ver. 1909, Bull de juris egypt, 21, 228-

Laurel, T. 24, No, 219-

Req, 30 dec, 1940, drecite-

Laurel, T. 24, No 269, D, 267-

إذا فلماذا لا يمتد هذا الحكم إلى حقوق الارتفاق الخفية بحيث يكفي استطاعة المشتري العلم بما لإعفاء البائع من الضمان^١.

والرد على هذا الاعتراض أن المشتري قد أقام قرينة على علمه بحقوق الارتفاق الظاهرة، والقاعدة بالنسبة للقرائن عدم التوسع بها عن طريق القياس^٢.

وأبعد من ذلك فلا مجال للقياس لأنه فلما يشتري شخص عقاراً دون أن يراه، ويكفي ذلك لمعرفة حقوق الارتفاق الظاهرة، بينما قد لا يتفحص المشتري سجلات التسجيل في أكثر الحالات لمعرفة الحقوق العينية التي تنقل العقار المبيع^٣.

ومن أمثلة الشروط المألوفة شرط الدفع بالذهب بسبب صدور نص قانوني بمنع التعامل بذلك.

البند الثاني

تأثير بطلان الشرط المألوف على العقد

إذا تبين أن الشرط الباطل ليس جوهرياً بالنسبة للمتعاقدين، فلا يؤثر بطلانه على قيام العقد ((١٤٤ مدني سوري)).

ويستعين قاضي الموضوع بالعناصر الداخلية للعقد للتعرف على الشرط الباطل^٤.

^١ د. أحمد غزوي عبد الرحمان: فواحد تفسير العقد ص ٤٦.

^٢ Laurent, T. 24, No 269, P. 267 -

^٣ Laurent, T. 24, No 269, P. 267, 268 -

^٤ Trib. Civ de Melun, 5 juin -

كما أن الرقابة القانونية تفرض على قاضي الموضوع أن يضمن حكمه الأسباب التي دعت إلى تقدير الشرط الباطل، وتأثير ذلك على بطلان العقد، والعكس^١.

ويتضح من الأقضية التي عرضنا لها بشأن الشرط المألوف أنه على الرغم من تأكيدها على استبعاد مثل هذه الشروط لاعتبارها لا تمثل النية المشتركة، فإن استبعاد الشروط المذكورة لا يتم بصورة آلية، والقول بغير ذلك يعني هدم مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، فضلاً عن مخالفة قاعدة عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة.

وبوجيز القول بعدم ترتيب أية آثار قانونية على تلك الشروط يتوقف على وجود عناصر داخلية في العقد تؤكد أن النية المشتركة للمتعاقدين تتعارض مع مضمون الشرط المألوف، أو أن هذه الشروط تخالف نصاً قانونياً آمراً، والقضاء الحديث لمحكمة النقض الفرنسية يذهب إلى أن الشروط المألوفة الواضحة في العقد لا يجوز استبعاد آثارها.

الفرع الثاني

أهمية شروط العقد التي تعطيه وصفاً قانونياً معيناً

من المعلوم أن القاضي يكيف العقد بعد قيامه بعملية التفسير، إذ على هدي تعرفه على النية المشتركة يعطي الوصف القانوني للعقد وعمل القاضي هذا يعتبر مسألة قانونية تخضع لرقابة النقض.

^١ - Civ.21, 1932, Précité.

والمسلم به أن قاضي الموضوع لا يتقيد بالوصف الذي حدده المتعاقدان إذا
وحده متعارضا مع النية المشتركة التي استخلصها من تفسير العقد^١.
ويثور التساؤل عن أهمية شروط العقد التي تعطيه وصفا قانونيا معيناً، وما
إذا كان القاضي يتمتع بإزاء هذا الشرط بالحرية نفسها الممنوحة له بالنسبة
 للعقد الذي يخلو من أي نص يتعلق بذلك^٢.

قد يقال إن تكليف المتعاقدين ليس له أي أثر قانوني خاصة أن التكليف يلبي
التفسير ويقوم عليه، ومع ذلك فالشرط الوارد بالعقد بإعطائه وصفا قانونيا
محددا يقيد حرية القاضي في التفسير إذ يعتبر شرطا مكتوبا لا يجوز إثبات
عكسه إلا بالكتابة، وإن تقيد القاضي بالتكليف الوارد في العقد يلزم أن
يقوم على عناصر مستمدة من كامل نود العقد، ولا يجوز للقاضي أن
يعتمد في تعديل هذا التكليف على عناصر خارجية عن العقد، ولا يمكن
تغيير الوصف القانوني عند حلول العقد من عناصر داخلية تؤكد وصفا
قانونيا يختلف عما حدده المتعاقدان، والأمر على خلافه بالنسبة للعقد الذي
يخلو من شرط يعطيه تكييفاً قانونيا، إذا يجوز للقاضي في مثل هذه الحال
تفسيره على ضوء العناصر الخارجية عن العقد طالما أن العناصر الداخلية
فصرت عن ذلك.

وباستقراءنا للقضاء الفرنسي يتأكد صحة المقولة الأخيرة، إذ رفضت محكمة
النقض الطعون ضد أحكام قاضي الموضوع التي عدلت الوصف القانوني
المحدد من قبل المتعاقدين، طالما أن ذلك التعديل يستند إلى نصوص العقد

^١ د. السهورى: الوسيط ج ١ فقرة ٣٨٨ ص ٦٦٤.

^٢ د. أحمد شوقي محمد عبد الرحمن: قواعد تفسير العقد ص ١٩.

^٣ د. أحمد شوقي محمد عبد الرحمن: قواعد تفسير العقد ص ١٩.

ذاته^١، وهكذا فقد أيدت اعتبار العقد بيعا على الرغم من أن المتعاقدين اعتبراه إيجارا ووعدا بالبيع^٢.

وفي الحقيقة فقاضي الموضوع لا يتقيد بتكييف المتعاقدين بأن العقد حبة إذا تبين له أن التكليف الذي يتحمله الطرف الآخر يساوي قيمة المال المتصرف فيه^٣.

وعلى العكس فعدم كفاية الثمن قد تقيد بأن التكليف الحقيقي للعقد هو حبة بعكس النص الوارد في العقد الذي يعطيه وصفا مختلفا^٤، وهذا ما استقر عليه القضاء المصري فهو يتقيد بنصوص العقد عند التكليف، أو يعدل التكليف الذي حددته المتعاقدان^٥.

وبالمقابل فاستخدام المتعاقدين لاصطلاح قانون معين، ليس من شأنه أن يقيد القاضي في التكليف وفقا للمصطلح القانوني السليم، شريطة أن يتضمن العقد العناصر التي تقيد النية الحقيقية، وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض الفرنسية بأن استخدام كلمة ((اجر)) لا يقيد حتما أن المتعاقد يشغل المكان طالما أن ذلك يتعارض مع النية المشتركة للمتعاقدين المستمدة من نصوص العقد ذاته^٦، كما قضت بأنه على الرغم من ذكر عبارة شراء في

^١ - Civ.juin, 1894, D.p. 1894, 1, 556.

^٢ - Req. 26.juin, 1942, gaz. pal. 1932, 563.

^٣ - Req. 21.dec. 1887, S. 1888, 1, 412.

^٤ - Req. 14.Mai, 1934, D.M. 1934, 330.

^٥ - نص من مصري ١٩٧٢/٥/٣، مجموعة النصوص المدنية ٣ رقم ١٢٦ ص ٨٠٦، وانظر الأحكام الأخرى المتعددة التي أشار إليها الدكتور أحمد شوقي في قواعد تفسير العقد ص ٥٠.

^٦ - Civ. 19.Mai, 1952, j.c.p. 1952.

الإيصال المؤقت بالعقد فهو يعتبر إيجارا أو بيعا إذا تبين ذلك بما لا يدع مجالا للشك بناء على المستندات الأخرى المكونة للعقد^١. وعلى العكس لا يجوز للقاضي تعديل الوصف الذي حدده المتعاقدان إذا كان يتفق مع نصوص العقد، وتطبيقا لذلك فقد ألغت محكمة النقض الفرنسية الحكم الصادر عن قاضي الموضوع بتعديل الوصف القانوني الوارد بالعقد بأنه إيجار ووعد بالبيع، حيث ورد في العقد أن ملكية الأشياء المباعة لا تنتقل إلا بعد دفع القسط الأخير من الثمن، وإن للموخر أن يسترد هذه الأشياء في حال عدم الوفاء بالأقساط عند حلول أجل استحقاقها وإنذار المستأجر بذلك، ويحتفظ الموخر بالأقساط التي يسلمها باعتبارها أحجره، وقد رفضت محكمة النقض الفرنسية تقدير قاضي الموضوع بأن العقد هو عقد بيع يجيز للبائع في حال عدم الوفاء المطالبة بالأقساط المتأخرة، حيث إن نصوص العقد وما تضمنته من التزامات على عاتق طرفيه تتفق مع وصف المتعاقدين بأنه عقد إيجار ووعد بالبيع^٢.

الفرع الثالث

أهمية الشروط المطبوعة والمكتوبة

القيمة القانونية لكل من الشروط المطبوعة والمكتوبة باليد على ما إذا كانت متعارضة فيما بينها على ما هو محدد فيما يلي.

توقف

^١ Appel Mixte, 26 juin, 18888, gaz de trib mixte, d. Egypt, 120, 307.

^٢ Civ, 1 juille, 1925, S1926, 269.

{ المطلب الأول }

عدم التعارض بين الشروط المطبوعة والمكتوبة باليد

لا حاجة للتدليل بأن العقد إذا ما انطوى على شروط مطبوعة وأخرى مكتوبة باليد، فإن توقيع المتعاقدين على هذا العقد يعني موافقتهم على كامل تلك الشروط إعمالاً لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، وقاعدة عدم جواز إثبات ما يخالف الدليل الكتابي^١.

ويرى فريق من الفقهاء أن الشرط المطبوع لا يلزم المتعاقد إلا إذا ثبت علمه ورضاه به معتمدين في ذلك على أحكام القضاء^٢، وهذا الرأي مرجوح لا سيما أن الأحكام القضائية التي اعتمدها هذا الفريق تتعلق بشروط لم تدبّل بالمضاء المتعاقد^٣، أو أنها شروط وضعت في لوحات لم يكن هنالك مسرر لذكرها في العقد ولم يثبت علم المتعاقد بها وموافقة عليها^٤.

وتطبيقاً لذلك فقد قضى بأن الشرط الوارد في عقد التأمين الذي ينص على حالات سقوط حق المؤمن له يرتب آثاره القانونية، ولا يؤثر في ذلك كون هذا الشرط مطبوعاً، وإنه لأمر غير منطقي أو عادل أن يعتد المتعاقد بمجهله بشروط عقد مطبوعة قام بالتوقيع عليه، ثم يزعم أنه لم يقرأه، فهذه الإدعاء يخالف العقد المكتوب، ويجب ترتيب آثاره طالما لم يوجد في عناصره الداخلية ما يفيد عكس الشرط المطبوع^٥.

^١ Civ, 12 fev. 1921, s. 1922, I, 1102.

^٢ josesant, T. 2, D. 241, M.

^٣ Marty et Raynaud, 12, v. I, N. 201, Note, 4.

^٤ Civ, 28 juin, 1906, D. p. 1910, 21.

^٥ د. أحمد خولي عبد الرحمن: قواعد تفسير العقد ص ٥٣

والأمر على خلافه بالنسبة للشروط المطبوعة القائمة بعد توقيع العقد، فهناك احتمال عدم الإلمام بها خاصة إذا طبعت بأحرف صغيرة تصعب قرائتها، فهنا يجوز لقاضي الموضوع أن يستبطن عدم التزام المتعاقد بها بسبب عدم العلم بها¹. وبالطبع يشترط أن تكون شروط العقد السابقة على التوقيع قد حلت من الإشارة إلى رجوع المتعاقد للشروط الواردة في أسفل توقيعه². إضافة لما تقدم فالسؤال ينور حول مدى إلزامية الشروط المطبوعة إذا لم يكن العقد مديلاً بتوقيع المتعاقد، وهو الأمر الذي طرح على محكمة النقض الفرنسية حول نزاع يتعلق بعقد نقل حوي، فقد ذكر في تذكيرة السفر شرط مطبوع يعفي الناقل من مسؤوليته المدنية، إذ قضت محكمة باريس بأن هذا الشرط لا يلزم المسافر بسبب عدم توقيعه على تذكيرة السفر التي ورد فيها شرط تحديد المسؤولية³، ولقد نقضت محكمة النقض الفرنسية هذا الحكم استناداً إلى أن تقييد المتعاقد بشروط العقد يقوم على رضائه بها، ولا يشترط لذلك أن يذيل العقد بتوقيعه إذ يكفي رضاؤه الضمني بهذه الشروط⁴، التي مكنته من التعرف على كافة الشروط المطبوعة وموافقته بعد ذلك على قيامه بالرحلة على الطائرة⁵، في الوقت الذي كان يستطيع فيه أن يرفض تذكيرة السفر⁶.

¹ - Trib de grand.jost de Paris, 2 Mai, 1960, gaz. pal., 1968, n. 124 -

² - Trib de grand.jost de Paris, 30 Mai, 1968, pricite -

³ - Paris, 23 juill, 1937, gaz. pal., 1937, 2, 692 -

⁴ - Civ, 27 fev, 1947, gaz. pal., 1, 206 -

⁵ - Civ, 9 Mars, 1942, pal., 1942, 1, 266 -

⁶ - S. Civ, 9 mars, 1942, pricite -

هكذا يتضح أن لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في استخلاص عدم رضا المتعاقد بالشروط المطبوعة التي لم تُذيل بتوقيعه، وهذا ما قضت به محكمة استئناف القاهرة بعدم إعمال شرط الإعفاء من المسؤولية الوارد في عقد النقل، حيث لم يوقع المرسل على البوليصة، وقد ورد في شرط مطبوع في سياق عبارات أخرى مطبوعة في وضع لا يمكن الالتفات إليه، ولا يسترعي انتباه المرسل، ولا يفيد قبوله لاحتمال أن يكون لم ير هذا الشرط وبالتالي فلا يعتبر قابلاً له^١.

وهذا ما قضت به محكمة النقض الفرنسية^٢ مؤيدة في ذلك الحكم الذي ألزم صاحب محل لتنظيف الملابس بأن يدفع تعويضاً إلى عميله عن الأضرار بسبب تلف الرداء المكلف بتنظيفه، ولم تعد المحكمة بشرط الإعفاء من المسؤولية الوارد على ظهر الإيصال المسلم للعميل، حيث قدرت عدم رضائه بهذا الشرط.

وبصورة عامة فالمتعاقد لا يلزم بالشروط المكتوبة بالإعلانات واللوحات إذا لم يرد ذكرها في العقد^٣ إذ إن هذه الشروط تمثل الإرادة المنفردة لواضعها، ولا تعتبر من متضمنات العقد إلا إذا ثبت علم المتعاقد الآخر وموافقته عليها بتاريخ سابق على إبرام العقد.

^١ ٤٩٦٣/٤/٣٠، المجموعة الرسمية سنة ٦١ عدد ٢ رقم ٥٦ ص ٤١٥.

^٢ Civ. 31 juiv. 1950, gaz. pal. 1950.241. Lyon, 12 juin. 1951, D. 1951. som. 2.

^٣ د. أحمد شوقي محمد عبد الرحمن: فواحد تفسر العقد ص ٥٥.

{ المطلب الثاني }

التعارض بين الشروط المطبوعة والشروط المكتوبة يدويا

هنا تتعلب الشروط المكتوبة يدويا باعتبارها أقرب إلى الية المشتركة، حيث يتحده المتعاقدان إلى الخروج على الشروط المطبوعة^١، ومع ذلك فعلى القاضي التوفيق بين نوعي الشروط، فإذا أمكنه ذلك وجب تطبيقهما معاً، وهذا ما اتجهت إليه محكمة النقض الفرنسية مريدة حكم محكمة الاستئناف المتضمن تمديد وقف نفاذ شرط التأمين، إذ أن الشرط العام المطبوع الوارد في العقد نص على أنه يترتب أثره ظهيرة اليوم التالي لليوم الذي يدفع فيه القسط السنوي للتأمين، لكن العقد المذكور تضمن عبارة مكتوبة يدوياً بخط السمسار المكلف بإبرام العقد بصفته وكيلًا للمؤمن حدد فيها لنفاذ العقد تاريخاً سابقاً للوقت الذي عينه الشرط المطبوع، وقد اعتدت محكمة الموضوع في نفاذ عقد التأمين بالتحديد الوارد في الشرط المكتوب يدوياً باعتباره يمثل الية المشتركة للمتعاقدين^٢.

^١ محكمة مصر الابتدائية الأهلية التجارية ١٩١٠/٢/٣١ - المجلوعة الرسمية سنة ٥٢ عدد = رقم ١١٦

^٢ Trib. com. Alexandrie, 2 nov, 1915 -

^٣ Civ, 31 janv 1927 -

الفصل الثاني

الطرق الخارجية المعتمدة في تفسير عبارات العقد

تمهيد:

هذه الطرق متعددة وإن كان المشرع السوري والمصري والفرنسي لم يشير إلا إلى العرف ((المادة ١٥٠ مدي مصري-١٤٩، ١٥١ مدي سوري-١١٥٩ مدي فرنسي)).

وعلى الرغم من ذلك فقد استمر القضاء -إذا لم تسعفه الطرق الداخلية - يلجأ إلى طرق أخرى للوصول إلى غايته في تلمس الإرادة المشتركة، وهذه الطرق متعددة، وتدخلنا في وسائل وأساليب الإثبات العامة.

معنى أن طرق الإثبات ليست معزول عن إثبات النية المشتركة، لاسيما إذا فصرت الوسائل الداخلية في ذلك، وبالتالي ففي حال التقصير تنهض طرق الإثبات العامة لتؤدي دورها الذي كان محجوباً بفعالية العناصر الداخلية للعقد. والطرق الخارجية لإثبات النية المشتركة متعددة، وفيما يلي أهم هذه الطرق: الشهادة -التفويض اللاحق للعقد -العادة.

البحث الأول

دور الشهادة في التعرف على النية المشتركة للمتعاقدين

تمهيد : وبطبيعة الحال فالإثبات بالشهادة يصطدم بمبدأ عدم جواز الإثبات بما يخالف الدليل الكتابي، ويثار في هذا البحث موضوع جواز الشهادة لتفسير

التصرفات القانونية الناتجة بالكتابة ، كما يثار موضوع جواز الشهادة لتفسير مضمون التصرفات القانونية الثابتة بالإقرار القضائي على التفصيل الآتي :

الفرع الأول

الإثبات بالشهادة لتفسير التصرفات القانونية الثابتة بالكتابة
لقد اشترط القضاء الفرنسي شرطين لإثبات بالشهادة التصرفات القانونية الثابتة بالكتابة ، وهذان الشرطان هما :

١. غموض عبارة العقد.
٢. الدور التكميلي للشهادة.

المطلب الأول

غموض عبارة العقد

لا حاجة للتأكيد بأن قاعدة لزوم الكتابة لإثبات ما يخالف أو يجاوز الدليل الكتابي لا تقف عقبة أمام الاستعانة بالشهادة لتفسير العقد المكتسوب إذا وجد غموض في بعض عباراته ، إذ أن التفسير يختلف عن الإثبات ، ودور المفسر يقتصر على البحث عما يتضمنه العقد ، ولهذا يمكن اللجوء إلى كافة الوسائل التي من شأنها إيضاح معنى العقد^١ ، والأمر لا يتعلق بإثبات العقد ذاته بل بتفسير عباراته الغامضة التي لا نزاع فيها^٢.

وعلى ذلك فعجواز الإثبات بالشهادة لتفسير العبارة الغامضة لا يتضمن خروجاً على قاعدة عدم جواز الإثبات بما يخالف أو يجاوز الدليل الكتابي

^١ Lousourn, rev. Trim de droit Civ, 1969, P. 764

^٢ د. أحمد شوقي عبد الرحمن : قواعد تفسير العقد ص ٦١.

إلا بالكتابة^١، بسبب بسيط هو أن هذا الإثبات لا يخالف نصاً، بل يعتمد
إلى تأكيد معنى الشرط العقدي^٢.

وتفسير الشرط العقدي بالشهادة ينير النقاط الآتية:

♦ حال الغموض في عبارة العقد.

♦ حال تحديد مضمون العقد.

أولاً : الغموض في معنى عبارة العقد

ويتفرع على هذا البحث ما يلي :

أ. احتمال العقد على حال معين :

إن نص الشرط العقدي على حال معينة ينير سؤالاً حول ما إذا كانت تلك
الحال قد وردت على سبيل المثال أو الحصر .

مما لا شك فيه أن الغموض يمكن إجماله عن طريق العقد ذاته من خلال
بيته الداخلية، فإذا لم ينضح قصد المتعاقدين من ذلك أمكن اللجوء إلى
كافة العناصر الخارجية بما في ذلك الشهادة^٣.

هكذا أجازت محكمة النقض الفرنسية الاستعانة بالشهادة لتفسير عقد
تأمين تضمن أن المؤمن له يستخرج أحجار الجير، وقد وقعت حادثة لأحد
عماله بسبب قيامه باستخراج أحجار عادية، وهنا تثار النزاع حول ما
إذا كان عقد التأمين ينصرف إلى الأعمال التي يقوم بها المؤمن له .

^١ - Civ, 31 Mai, 1948, gaz. pal, 1948, 2, Somm, 4.

^٢ - د. أحمد شوقي عبد الرحمن : قواعد تفسير العقد ص ٦١.

^٣ - د. أحمد شوقي عبد الرحمن : قواعد تفسير العقد ص ٦٢.

ولقد أجازت المحكمة اللجوء إلى الشهادة والقرائن لتفسير المعنى الحقيقي لعبارة العقد، وبالنيحة اعتبرت الشركة المؤمنة ضامنة للمخاطر التي تعيق لها المؤمن له نتيجة استخراج الأحجار العادية^١.

ب. انطواء العبارة على عدة معان :

قد تحتل عبارة العقد عدة معان ، وهنا يبرز دور الشهادة في ترجيح أحد المعاني ، وهنا ما يتضح من حكم محكمة النقض الفرنسية حول تفسير عبارة وردت في عقد التأمين ضد مخاطر الحريق ، وتضمنت سقوط حق المؤمن له في الضمان إذا لم يعلن عن الحوادث التي سبق وتعرض إليها. حيال هذه العبارة العامة ،ثار السؤال حول ما إذا كانت تشمل العقارات المؤمن لها أم تمتد إلى كافة عقاراته ،وقد اتضح أن المؤمن له لم يعلن المؤمن عن الكوارث التي أصابت معمل تفتير لم يرد ذكرها في عقد التأمين. ولقد استندت شركة التأمين إلى المعنى العام للعبارة،وتمسك المؤمن له بشأن التبليغ عن الحوادث السابقة تقتصر على العقارات المؤمن عليها ، ومع ذلك فالشهادة تعدد المعنى الحقيقي لعبارة العقد بما يتفق مع القصد المشترك ولا يخالف الدليل الكتابي، وإنما يوضح المعنى^٢.

وفي قضية أخرى أهدت محكمة النقض الفرنسية حكم قاضي الموضوع الذي امتنع بالشهادة والقرائن لتفسير عقد بشأن عقار دفع نصف ثمنه عند توثيق العقد ، وحين طالب المشتري بدفع الباقي أدعى أنه وفاه ، وأبرز

^١ - Req.23 Mai.1881.d.p.1882,1,1,170-

^٢ - وأحمد غولي عبد الرحمن يتوحد تصو العقد - ٦١.

^٣ - Civ.23.Nov.1938.pal 1939,1,85-

إيضالاً محرراً بتاريخ لاحق لتوثيق العقد أقر فيه البائع بتسلمه مبلغاً بصقعة
قسط من ثمن المبيع .

والملاحظ أن كلمة قسط الواردة في العقد لم تحدد ما إذا كان الأمر يتعلق
بالقسط الأول أم الثاني ، هنا فضلاً عن أن ظروف العقد ، وإن رجحت
أحد المعنيين إلا أنها ليست قاطعة ، ذلك أن دفع القسط الأول وقت توثيق
العقد يرجح أن المتخالصة خاصة بالقسط الثاني ، ومع ذلك فهذا المعنى ليس
مؤكدًا .

ثانياً : الغموض في مضمون العقد
وقد يقترب الغموض لمضمون العقد فهنا يجوز اللجوء إلى الشهادة والقرائن
، ولسنا حيال مخالفة لقاعدة الدليل الكتابي .
ولقد صدر قضاء غزير بهذا الشأن وفيما يلي بعض التطبيقات المتعلقة
بذلك :

أ . عقد البيع : لقد أجازت محكمة النقض الفرنسية الاستعانة بالشهادة
والقرائن بصدد تفسير العقد ومن أجل تحديد الأشياء المبيعة ، ولقد قبلت
المحكمة الإثبات بالشهادة والقرائن من أجل توضيح كيفية تنفيذه ، وما
إذا كان المشتري باشر على الأرض سلطات الاستغلال الخاصة
بالمالك¹ .

وعلى العكس لم يجز القضاء قبول الإثبات بالشهادة إذا كانت عبارات
العقد واضحة ، وهذا ما ينضج من حكم محكمة النقض الفرنسية المتضمن
أن نص عقد البيع واضح ، وأن العقار لا يتعلق به حق لأحد ، ولا يجوز للبلع
عند الرجوع عليه بالضمأن أن يثبت بالشهادة أن المشتري كان يعلم بحقوق

¹ - Req, 9 Mars, 1909, S. 1910, I, 28 -

إيجار يتعلق بالعقار المبيع، ومن ثم فعبارة العقد واضحة لا يجوز نقضها أو تعديلها عن طريق الشهادة^١.

وفي حكم آخر لهذه المحكمة نضمن أنه إذا نص عقد البيع بأنه لا يشمل أموالاً معينة فلا يجوز الشهادة لإثبات أن العقد يشمل هذه الأموال طالما أن العبارة واضحة، وقبول الشهادة بوجود هذه الأموال يتعارض مع الدليل الكتابي^٢.

وفي حكم ثالث قررت هذه المحكمة أنه إذا حدد في عقد المقايضة عقار باسم معين، فلا يجوز الإثبات بالشهادة على أن المقايضة تتضمن قطعاً أرضاً آخرين لكل منها أسم مغاير للعقار المحدد للعقد المكتوب، إذ أن ذلك يتضمن مخالفة لعبارة العقد، وإذا كان من الجائز إثبات ملحقات الشيء المبيع، فشرط ذلك عدم تحديد العقد لها والأمر على خلافه بالنسبة للأشياء المستقلة التي لا تعتبر من الملحقات.

ب. عقد الإيجار: قضت محكمة استئناف باريس بإمكان الاستعانة بالشهادة لتحديد الأشياء المؤجرة عند عدم تضمين عقد الإيجار ذلك^٣، وقد صدقت هذه المحكمة حكم محكمة Pontoise المتضمن أن استغلال المؤجر للأشياء وقت إبرام العقد يقوم مقام السهو عن ذكر تلك الأشياء.

^١ - Civ. 5 janv. 1874, D.p. 1874, I, 12.

^٢ - Civ. 7 fev. D.p. 1904, I, 490.

^٣ - D. 1888, 2, 65, Note, Flurer.

وخلاف ذلك فقد اتجهت هذه المحكمة إلى عدم جواز الإثبات بالشهادة بأن
الإيجار انصرف إلى جزء معين من العقار إذا كان ذلك يتعارض مع النص
الصريح المتضمن أن الإيجار تناول العقار بكامله^١.

وذهبت محكمة Nevers إلى أنه لا يجوز للمستأجر أن يثبت بالشهادة أن
عقد الإيجار سمح له باستعمال المأجور بصفة مقهى، لأن نص العقد الصريح
يتضمن استعماله مطلقاً^٢.

ج. عقد القسمة : ولقد أجازت محكمة النقض الفرنسية اللجوء إلى الشهادة
لتحديد مضمون عقد القسمة بسبب غموض عبارة العقد وعدم
تحديد أنصبة المتخاصمين.

د. الوصية : ولقد قضت محكمة النقض الفرنسية بأنه يجوز الاستعانة بكافة
وسائل الإثبات الخارجية للوصول إلى نية الموصي، وذلك في حال وجود
غموض في عبارات الوصية^٣، ولقد قضت ذلك بأنه إذا كانت عبارة الوصية
واضحة في تعيين لقب الموصى له واسمه ودرجة قرابته للموصي، فلا تقبل
الشهادة لإثبات أن الموصي كان يقصد تعيين شخص آخر له اللقب نفسه
ودرجة القرابة نفسها، ولكنه يختلف عن الموصي له في الاسم لأن ذلك
يخالف الدليل الكتابي^٤.

^١ D.P.1897,2,188-

^٢ gaz.pal.1928,1,620-

^٣ Req,Avril,1907,D P.1907-

^٤ Req,23.fev,1863,D.p.1863,1,171-

المطلب الثاني

الشهادة بصفتها طريقا احتياطيا لتفسير العقد المكتوب

وهنا يقتضي دراسة الحالات الآتية :

□ تقدير قاضي الموضوع لعبارة العقد الواضحة.

□ تقدير قاضي الموضوع لعبارة العقد الغامضة.

البند الأول : تقدير قاضي الموضوع لعبارة العقد الواضحة:

إن تسليم قاضي الموضوع بوضوح عبارة العقد أمر يدخل في صميم تقديره ، ولا يخضع في ذلك للمراقبة القانونية وهذا ما أكدته محكمة النقض الفرنسية في حكم يتعلق بتفسير عقد أبرم بين مالك أرض وشخص آخر استخدمه المالك مديرا لشؤون زراعته ، وقد تضمن عقد الاستخدام بأنه في حال انتهاء الرابطة بينهما فلا يبقى للمستخدم أي تعويض ، وهكذا فقد رفضت محكمة النقض - مؤيدة حكم محكمة الاستئناف - Aix en Provence -

فيول الإثبات بالشهادة والقرائن بسبب وضوح عبارات العقد.

البند الثاني : تقدير قاضي الموضوع بأن العبارة غامضة :

وهنا نعرض أن هنالك عناصر داخلية للعقد تفسر الغموض والعكس

أولا: غموض العبارة مع وجود عناصر داخلية للتفسير

هكذا يبرز دور الشهادة والقرائن بصفتها طريقا احتياطيا بحيث لا يجوز اللجوء إليهما إذا تضمنت عبارة العقد ذاتها عناصر تكفي لتفسير النص

الغامض، وفي هذه الحالة لا يكون قبول الشهادة بمجرد سلطة تقديرية للقاضي، بل يتعين عليه استبعادها إذا لم يوضح عبارة العقد^١ ثانياً : غموض العبارة وعدم وجود عناصر داخلية لإحلاء الغموض ولقد اتّمعت محكمة القضا الفرنسية إلى أنه لا يجوز لقاضي الموضوع أن يرفض قبول الشهادة والقرائن لتفسير العقد، وذلك في حال غموض عبارة العقد، وفي الوقت نفسه أكدت أن رفض محكمة الموضوع ذلك يعتبر إنكاراً لسلطانها التقديرية وتطبيقاً خاطئاً لنصوص القانون، منهين بأن النزاع كان يتعلق بتحديد مضمون الوكالة الضمنية^٢.

الفرع الثاني

مدى جواز الإثبات بالشهادة لتفسير مضمون الإقرار القضائي ومضمون

التصرفات القانونية الثابتة بالإقرار القضائي

قد يتطلب الأمر تفسير التصرف القانوني الثابت بالإقرار القضائي أو تحديد نطاقه.

وقد يطرح على القاضي استبعاد بعض الوقائع المرتبطة بالإقرار على اعتبار أن الأمر لا يتجزأ.

هكذا تنهض الحاجة لبحث ما يلي :

« سلطة القاضي في استبعاد الوقائع المرتبطة بالإقرار.

^١ د. أحمد شوقي محمد عبد الرحمن : قواعد تفسير العقد - ص ٧٠، وانظر عكس ذلك الأحكام التي أشار إليها.

^٢ - محكمة القضا الفرنسية : ١٩٠٧/٤/٢٩

« سلطة القاضي في تفسير مضمون التصرف القانوني الثابت بالإقرار القضائي.

المطلب الأول

سلطة القاضي في استبعاد بعض الوقائع

يثار التساؤل عن سلطة القاضي عندما يظهر من أقوال المقر أو تصرفاته في القضية المعروضة تعارضاً أو تكادياً للوقائع المقر بها. في هذه المسألة قرر القضاء الفرنسي حواشٍ لحرمة الإقرار، ووجهته أن الإقرار لا يقتصر على ما يعلنه المقر صراحة أمام القاضي، بل يمتد إلى كافة الأقوال والتصرفات التي تصدر عن المقر، فهذا التعارض يشكل غموضاً يوجب على القاضي إجماله مستعيناً في ذلك بالشهادة للوصول إلى النية الحقيقية للمقر، وهذا ما يسمح طرح بعض الوقائع المقترنة بالإقرار^١.

وبذلك فمشرط استبعاد إحدى الوقائع يكمن فيما يلي :

١. ثبوت كذب الواقعة.

٢. وجود تعارض في أقوال المقر المتعلقة بالواقعة.

أولاً : ثبوت كذب الواقعة

ومثاله ما يتضح في إقرار أحد الأطراف في الدعوى بأنه مدبر من مبيع لشخص آخر، لكنه أضاف بأنه اشترى به عدداً من أسهم الشركة الحديدية بتكليف من الدائن.

^١ د. أحمد شوقي عبد الرحمن : قواعد نصيب العقد ص ٧٢.

ولقد رفضت محكمة النقض الفرنسية أعمال الجزء الثاني من الإقرار بعد أن تبين لها أن الأسهم المشتركة لم تكن باسم وحساب المقر له¹، وبالمقابل فقد أقرت هذه المحكمة بتحرئة إقرار صادر عن منحاصم تضمن أنه تسلم من المدعي مبلغاً معيناً بأنه تم لنسره ومنقولاته التي باعها له، ولقد استندت المحكمة في ذلك إلى ثبوت عدم صحة ملكية المقر للأشياء التي ادعى بيعها للمقر بناءً على عقود رسمية².

ثانياً : حال التعارض في أقوال المقر

ولقد استقرت محكمة النقض الفرنسية على أن تناقض الأقوال في واقعة معينة يفيد كذبها ويوجب استبعادها حرجاً على مبدأ عدم تحرئة الإقرار.

على هذا الأساس أجازت تحرئة الإقرار الصادر عن طيب اعتراف بأنه مدني وأضاف أن الدائن قد أبرأه من جزء منه، ولكن المحكمة لم تعتمد بالإبراء لما لمسته من أقوال متناقضة لا يمكن تصديقها، ذلك أن المقر صرح بأنه أعطى الدائن إيصالاً بالدين، وقد علم من أحد الأشخاص أن نية الدائن انحبت إلى الإبقاء لأبنة مبلغ يقوى مبلغ الدين، وأن عدم العثور على الإيصال يفيد اعتناء الدائن له وإبراء المقر من الدين، ومن ناحية أخرى أعلن المقر في وقت لاحق أن الدائن أعلمه بإبرائه من الدين المستحق، وإزاء هذه الأقوال المتعارضة فقد أبدت حكم محكمة الاستئناف الذي استبعد واقعة الإبراء لعدم إمكان تصديقه.

¹ - Req. 8 fev. 1864, D. p. 1864, 486.

² - Req. 5, dec. 1881, D. p. 1883, 1, 206.

ولقد أيدت هذه المحكمة أيضاً حكم محكمة الاستئناف، التي استئنفت
 عدم صحة الإقرار بسبب التعارض القائم به، إذا أن المقر صرح بأن
 تعامله مع المدعى لم يكن بصفته وكيلاً له، بل متعاقداً يشتري ما يبيعه
 له المدين، ويبيع ما يشتري له، وأضاف بأنه تصرف بصفته
 وكيلاً، وهكذا فقد تأكد لمحكمة الموضوع التعارض في أقواله لجهة عدم
 حواز الجمع بين المتعاقد والوكيل، إذاً لا مناص للمحكمة أن تعتد
 بإحدى الصفتين، لذلك فقد حرأت الإقرار، وأخذت بصفته التعاقدية.

المطلب الثاني

سلطة القاضي في تفسير مضمون التصرف القانوني الثابت

بالإقرار القضائي

وهنا تواجه الخاليتين :

❖ تعلق الإقرار بالتزام معين مستمد من تصرف قانوني.

❖ تعلق الإقرار بالتصرف القانوني ذاته.

البند الأول : تعلق الإقرار بالتزام معين مستمد من

تصرف قانوني

هنا تنفيد المحكمة بالإقرار لجهة تحديد مدى هذا الالتزام، ومن ثم إذا أقر

شخص بأنه مدين بمبلغ معين ثمناً لأشياء اشتراها، فإن مبلغ الدين يتحدد

بهذا الإقرار⁹.

⁹ - Req.9 Mars.1010.1.248 -

⁹ - Civ.9. oct.1870.D.p.1870.1.356 -

البند الثاني : تعلق الإقرار بالتصرف القانوني ذاته

إن ثبوت التصرف القانوني بناء على الإقرار لا يلزم القاضي بتفسير العقد على النحو الذي يحدده المقرر^١، ذلك أن هدف القاضي من التفسير هو التعرف على النية المشتركة للمتعاقدين، أما التفسير الذي يدعيه المقرر فقد لا يمثل إلا وجهة نظره .

وحقيقة الأمر أن ثبوت التصرف القانوني بالإقرار كثيراً ما يكتنفه الغموض خلافاً للعقد المكتوب الواضح، وهكذا يتعين على القاضي الاستعانة بالشهادة والقرائن^٢.

وتتجه محكمة النقض الفرنسية إلى أن قاعدة عدم حواز تجزئة الإقرار لا يمنع القاضي من تفسير التصرف الثابت بالإقرار بصورة تختلف عن التفسير الذي يعطيه المقرر^٣.

ووفقاً للقواعد العامة فقاضي الموضوع يختص بتحديد معنى الإقرار في ذاته ونطاقه ولا يخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض.

أولاً تحديد نطاق التصرف القانوني المقر به :

قد يتضح من القرائن أن نطاق التصرف أكثر اتساعاً مما هو عليه في الإقرار، وهكذا فقد ألحقت محكمة النقض الفرنسية إلى الأحكام هذه القرائن مصدقة بذلك حكم محكمة الموضوع الذي استعان بدليل القرينة

^١ د. أحمد خوقي محمد عبد الرحمن ص ٧٥.

^٢ Civ. 3 juill. 1889, D. p. 1890, 1, 249 -

^٣ Civ. 1 fev. 1955, J. e. p. 1955, 4, 38 -

للقول بأن وكالة الزوجة لا تقتصر على فوائد الدين كما ورد في الإقرار، بل تمتد ذلك إلى استيفاء أصل الدين^١.

ولقد صدقت أيضا هذه المحكمة^٢ حكم قاضي الموضوع الذي وسع من نطاق الوكالة المقر بها، حيث ورد في الإقرار أنها تتعلق بإدارة شؤون المتجر الخاص بالموكل، لكن محكمة الموضوع ذهبت إلى أن الوكالة قائمة بعد أن تمثلت الوكيل المتجر مستندة في ذلك إلى المراسلات المتبادلة بين الأطراف.

وفي حكم ثالث أيدت هذه المحكمة^٣ حكم محكمة الاستئناف : السدي فسر عقد مقايضة قطعتي أرض ثابت بإقرار طرفي النزاع مقررة بأن هذا العقد يتضمن حق الارتفاق المجري المقرر على عقار أحدهما لمنفعة عقار الآخر مستندة إلى أن هذا الحق لا يتضمن أية إضافة إلى مضمون العقد، بل الأمر يتعلق بتفسير العقد الثابت بالإقرار إذ ثبت وجود المجري وقت المقايضة، كما إن نية المتعاقدين اتجهت إلى استبعاد حق الارتفاق، ولا يوجد ما يدل على أنهما يقصدان تغيير الحال التي كانت قائمة وقت المقايضة خاصة أن صاحب العقار المخدم ظل يباشر حقه في الارتفاق منذ إبرام العقد ولمدة تسع سنوات دون منازعة، كما أن إنكار حق الارتفاق يجعل صاحب الأرض التي بقيدتها هذا الحق في وضع أسوأ مما كان قبل إبرام عقد المقايضة حيث يخلو من أي فائدة له^٤.

^١ - Req. 12 juin, 1899, D p. 1900, 1370.

^٢ - Req. 22 juin, 1926, S. 1926, 1, 253.

^٣ - D.P. 1878, 1, 259.

^٤ - د. أحمد شوقي عبد الرحمن فوائد عدم العقد ص ٧٧.

ثانياً تكيف التصرف القانوني الثابت بالإقرار القضائي

قد يعطى المقر بالتصرف القانوني الذي أقر به وصفاً معيناً لكن القاضي لا يقتنع بذلك لأنه يجد في عناصر الإقرار وقائع لعقد آخر، والأمر هنا لا يتعلق بالتفسير، وإنما بالتكيف القانوني للعقد.

هكذا أكدت محكمة النقض الفرنسية^١ حكم قاضي الموضوع المتضمن أن الوقائع المقرها تفيد أن المبلغ المستحق في ذمة المقر يقوم على الوكالة أو الفضالة، وليس على الوديعة كما يدعي المقر، وهذا الأمر يدخل في نطاق التفسير الموضوعي دون أن يخضع لرقابة النقض.

وحقيقة الأمر فهذا الحكم وإن كان سليماً من حيث النتيجة إلا أن الحظ جانبه من جهة الأساس القانوني.

وبيان ذلك أن نصديق محكمة الموضوع للوصف الذي يعطيه المقر للتصرف القانوني لا يتعلق بتفسير العقد، وإنما بتكييفه القانوني، وهذا التكيف من مسائل القانون، وتخضع لرقابة المحكمة^٢.

البحث الثاني

دور تنفيذ العقد في تفسيره

وفي هذا الصدد نذكر الحالتين التاليتين :

❖ حالة وضوح عبارة العقد.

❖ حالة غموض عبارة العقد.

^١ - Civ, 7 Mars, 1887, D. p. 1887, 1, 403.

^٢ د. أحمد شوقي عبد الرحمن قواعد تفسير العقد - ص ٧٧.

الفرع الأول

حالة وضوح العقد

يرى الأستاذ gallatay أن تكوين العقد لا يقوم على عباراته، وإنما على النية المشتركة، وهذا ما يرتب تفسيره على ضوء أسلوب تنقيده ولو تعارض الأمر مع عباراته، طالما أن طرف العقد الذي يحتاج في مواجهته بطريقة التنفيذ لم يثبت أن هذا التنفيذ لا يعبر عن نية كما أن يثبت أن التنفيذ قد تم تحت تأثير غلط أو بناء على تسامح من حاته^١، وهذا الرأي لا يمكن التسليم به لأنه يتعارض مع التشريع ومع استقرار القضاء والتنفيذ لا يعبر شيئاً من قواعد تفسير العقد. لا سيما إذا تعارض مع المعنى المستمد من عباراته الواضحة، كما أن الأخذ بطريقة التنفيذ يتعارض مع مبدأ عدم جواز مخالفة الدليل الكتابي .

ومع ذلك فإن ثبات تنفيذ العقد بطريقة تعارض مع المعنى المستمد من عباراته الواضحة قد يقيد التدليل على النية الضمنية للمتعاقدين الذي يحتاج في مواجهته بطريقة التنفيذ بإبراء الطرف الآخر من جرمه من التزاماته الناتجة من العقد، فهذا يتعلق الأمر بنسوة إرادة ضمنية محددة دول أن يتعلق بطرق خارجية للتفسير^٢.

^١ - Callatay, these, No. 55, P. 116

^٢ - وأحمد شوقي عند الركن قواعد تفسير العقد ص ٧٩.

الفرع الثاني

حالة غموض العقد

تلعب طريقة تنفيذ العقد دوراً في تفسيره عندما تكون عباراته غامضة، وهذا ما أكدته القضاة الفرنسي^١ والمصري^٢.

المطلب الأول

شروط الأخذ بطريقة التنفيذ من أجل تفسير العقد

لقد اشترط الفقه الشروط الآتية :

١. أن يكون التنفيذ لاحقاً لإبرام العقد.
 ٢. أن يعلم المتعاقد بطريقة التنفيذ التي يجريها المتعاقد الآخر.
 ٣. أن تمضي مدة معقولة على التنفيذ دون اعتراض أو تحفظ من جانب المتعاقد.
- وقاضي الموضوع يستقل بالتحقق من قيام هذه الشروط^٣.
- ويجوز للمتعاقد الذي يخرج في مواجته بطريقة التنفيذ إثبات أن رضاه كان على سبيل التسامح، وأن طول مدة التنفيذ دون تحفظ قد يتعارض مع هذا الادعاء^٤.

^١ - Trib. Civ de la Seine, 22 janv, 1930, D.M., 1930, 323.

^٢ - وأحمد خيري محمد عبد الرحمن ص ٨٠ والأحكام المكتوبة التي أشار إليها في الحاشية.

^٣ - المرجع السابق ص ٨٠ وانظر الأحكام المشار إليها في الحاشية.

^٤ - المرجع السابق ص ٨١ وانظر الأحكام المشار إليها في الحاشية.

المطلب الثاني

دور تنفيذ العقد في تفسيره في مجال العقد الإداري

المفروض حسب طبائع الأشياء أن يوطر التنفيذ بالإرادة المشتركة للمتعاقدين دون أن يعي انسلاخه عن شريعة المتعاقدين ، فهذه الشريعة تنطلق من نظام الأشياء وماهيتها ، ومن الطبيعي أن يأخذ القانون الإداري بذلك ، وأن يفسر غموض العقد بطرق وإجراءات تنفيذه ، وهذا ما يتضح من القضية التي طرحت على القضاء الإداري في مصر والتي تلخص وقائعها فيما يلي :

تعاقدت وزارة الشؤون البلدية والقروية مع أحد المقاولين على حفر بئر ارتوازي لتزويد أهالي بعض المناطق بالمياه العذبة الصالحة للشرب ولقد باشر المتعاقد في تنفيذ العمل ، لكنه فوجئ بطبقة صخرية ولما كانت شروط المناقصة غير واضحة ، ولم تبيّن تفاصيل التنفيذ ، لذلك فقد اضطرت المحكمة على تفسير العقد على ضوء باقي شروطه وموقف الإدارة من المتعاقد عندما بدأ بالتنفيذ .

ذلك أن هذا المتعاقد فوجئ بالطبقة الصخرية فتظلم للإدارة فدفعت له تكاليف الحفر وسمحت له بتغيير موقع البئر ، ولقد فوجئ للمرة الثانية بالطبقة الصخرية ، ولما تظلم للإدارة مرة ثانية أكدت الجهات الفنية بأن حفر البئر يحتاج إلى آلات حديثة ليست في حوزة المقاول ، وبذلك فقد أرست الإدارة العملية على غيره ، وصادرت التأمين وأصدرت قراراً بحجز الآلات ، ولما رفع الدعوى قضت المحكمة بأنه قد ظسهرت إرادة المصلحة ونيتها من أن موضوع العقد لم يكن ينصرف إلى الحفر في الصخر .

وترتيباً لما تقدم لم يكن يجوز للحكومة أن توقف المدعي عن العمل^١.
وقريباً من ذلك حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في ١١/٧/١٩٤٤
، إذ فسر العقد المطروح أمامه على ضوء الطريقة المطبقة من قبل
الطرفين^٢.

ونوه استطراداً بأن المتعاقد قد يلعب دوراً هامشياً في التنفيذ بالنسبة
لبعض العقود الإدارية مثل عقد القرض العام ، لكن هنالك عقوداً إدارية
أخرى تتحلى فيها كثافة حضور المتعاقد ودوره في معاونة الإدارة في
التنفيذ مثل عقد الحصر (حصر التبع والنيابك أو امتياز الماء والكهرباء) ،
وبذلك فهذه المشاركة الفعالة للمتعاقد في إدارة المرفق وتنفيذه تلقى
الضوء الساطع على تفسير الغموض في العقد.

وهذا ما أكدته الدكتور الخاني بأن آثار مفهوم التعاون في المرفق العام
على التزامات المتعاقد تبدو أكثر ما تكون في مجال تفسير التزامات
المتعاقد ، حيث تتحلى فكرة التعاون في المرفق العام ، وهي تستلزم -
باعتبار أن العقد الإداري أداة مباشرة أو غير مباشرة لهذا التعاون- أن
تكون الإدارة على حق إذا هي تتطلب من هذا المتعاقد أقصى قدر من
الجهد والمجهود على تنفيذ عقده ، إذ في تفسير الالتزامات يبدو القساضي
أحياناً أكثر قسوة منه في تنفيذ العقد المدني ، وهذه من الأفكار الموجهة
التي ما فتئ القضاء الإداري يرددها باطراد^٣.

^١ القضية رقم ٢٨٤ لسفاح قضائية السيد محيى عيسى العباري ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية.

^٢ المجموعة لعام ١٩٤٤ ص ١٩٨.

^٣ كتابه القانون الإداري مجلد ٤ ص ٣٤٥ وانظر الدكتور الطائري الأسس العامة للعقود الإدارية

وهذا ما أكدته الأستاذ عبد الهادي عباس على ضرورة تنفيذ العقد الإداري في إطار أقصى الجهد والعناية والتكامل والدقة التي لا نلاحظها في القانون المدني^١.

لكن أليس هذا الإلزام، وتلك التكاليف الملقاة على عاتق المتعاقد تحمل بقاعدة المساواة التي تحكم العقد الإداري.

والواقع أن القانون الإداري في جوهره هو ذلك الجهد الدؤوب والقاسي لتحقيق التوازن بين المصلحتين العامة والخاصة، وبالتالي فإذا ما اختل التوازن لصالح الإدارة، سرعان ما يهب القضاء الإداري لإعادة الخلل إلى اتساقه وتوازنه عن طريق فرض تكاليف أخرى موازية على الإدارة، وهذه التكاليف تأخذ على سبيل المثال المظاهر الآتية :

- ♦ خضوع العقد الإداري للتفسير المعقول وغير الظالم^٢.
- ♦ ضرورة أن تقدم الإدارة للمتعاقد يد العون والمساعدة لا أن تترصد أخطائه وتنصيده له الزلات، فهو شخص ليس غريباً عن الإدارة، بل هو مساعد ومعاون يسعى لتحقيق - إلى جانب مصلحته الشخصية - الصالح العام، وهذا الصالح لا يتحقق إلا من خلال آليات إجرائية وواقعية يعتبر المتعاقد حلقة هامة فيها، وبالتالي فقوته قوة للإدارة وعون لها وشرط هام في سير المرفق وانتظامه وإضطرابه.

^١ كتابه العقود الإدارية جزء ٢، طبع ١٩٩٣، ص ١٦٤ و ٢٤٩.

^٢ الخافي : القانون الإداري، طبع ٢٠١١ - عبد الهادي عباس : العقود الإدارية ص ١٤٤، حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في ١٩٥١/٢/٧.

وقد ينص القانون على ذلك ((إعطاء الملف والاستحقاقات في مواعيلها))، لكن القانون ينظم في هذه الحال مبدأ ويكشف عن وجوده^١.

♦ وعلى الإدارة ألا تتخذ موقفاً يتم عن منافستها للمتعاقدين ، اللهم إلا إذا قصت ظروف المرفق ذلك^٢.

وحقيقة الأمر أنه ليس من العدل و الإنصاف وحسن النية في المعاملات أن يترك المتعاقد فريسة لظروف سيئة لا دخل له فيها ، دون أي تعويض استناداً إلى النصوص الحرفية للعقد ، ولتحرد الحرص من الإدارة على تحقيق الوفر المالي^٣.

والخلاصة أن ضرورات سير المرفق باضطراب وانتظام تفسر جوهر القانون الإداري وتسري بكافة خصائصه وسماته المميزة له من روابط القانون الخاص ، واطهر ذلك حركيته^٤ ، وما يتفرع على ذلك من التوسعة أحياناً على الإدارة : *Dynamisme en plus* والتضييق والتقييد عليها أحياناً أخرى : *en less* ، وهذه الحركة تفسر نظرياته الكبرى التي نشأت للإحاطة بتنفيذ العقد ، مثل نظرية الأمر : *fait du prince* ونظرية الظروف الاستثنائية ، وأخيراً نظرية الافتراض ، أي افتراض قيام

^١ عبد الهادي عباس المرجع السابق ص ١٣-١٤ ، د. الخاني : القانون الإداري مجلد ٤ ص ٢١٥.

^٢ حكم مجلس الدولة المصري الصادر في ١٩٥٠/٤/٢٦ قضية المجموعة ص ٢٣١ وحكم مجلس الدولة المصري الصادر في ١٩٥٦/٣/١١ المتعلق بإنشاء مقصف ، بقاى المقصف المرحس به ، المجموعة السنة العاشرة ص ٢٣٩.

^٣ حكم محكمة القضاء الإداري في مصر الصادر في ١٩٥٧/٦/٣٠ سبق الإشارة إليه.

^٤ د. الخاني : القانون الإداري مجلد ٤ ص ٢٤٩ وما بعدها - الأستاذ عباس العقود الإدارية المرجع السابق المقدمة.

إرادة المتعاقد بقبوله عند إبرام العقد حق الإدارة في التعديل^١ وغير ذلك من الأمور التي منطقتها وأساسها و فحواها تحقيق العدالة ليس إلا، دون الابتسار والتعصب واللهات وراء هذا الافتراض لتغطية هذه المواقف. ومن مظاهر هذا التشدد تفسير قاعدة فرض الغرامة لصالح الإدارة، وافتران ذلك بقربة مفادها أن أي تأخير في تنفيذ العقد الإداري يؤثر في جعل حركة المرفق، و يبطئ سير دولاب العمل فيه^٢. ذلك أن قاعدة سير المرفق من أساسيات الحياة العامة، ولا يمكن التساهل في الإهمال أو البطء أو التعثر في التنفيذ، ومن هنا برزت فكرة حماية الإدارة لهذا المبدأ من طريق فرض الغرامات فرضاً ينسم بالصرامة والجدية، وهكذا تولدت القرائن لضمان التنفيذ، وظهرت أيضاً القرينة بخدوت الضرر على الإدارة جراء ذلك.

من جماع ما تقدم يصح الحديث عن منطقة العقد الإداري المتميزة بسماتها وقسماتها، وفي داخل هذه المنطقة يخل العقد الإداري حقلاً متميزاً تحكمه روابط القانون العام المستهدفة بمبادئ وأصول المرفق العام وضرورة سير الحياة الإدارية سراً منتظماً يكفل تحقيق الحاجات العامة، وهذا ما أكدته الجمعية العمومية لمجلس الدولة المصري في الفتوى الصادرة عنها بتاريخ ٢٢/١٠/١٩٥٦ برقم ٦٣٧، تقول هذه الفتوى : إن الإدارة تراعي في الشروط الجزائية المنصوص عنها في العقد ملاءمتها لطبيعة هذا العقد إضافة إلى موجبات السرعة في تنفيذه وضرورة إتمام هذا التنفيذ في وقت

^١ الطماوي : الأسس العامة للعقود الإدارية ص ٦٣ و ٦٤.

^٢ د. الطماوي : الأسس العامة للعقود الإدارية ص ٦٤٩ لقد عرض للعمل الآراء حول قطعية القرينة والعكس.

معين وطريقة معينة حتى تكفل انتظام سير المرفق العام ،هذا فضلاً عن أن المتعاقد مع الإدارة يقبل التعاقد مقدماً بجميع الشروط والظروف المحيطة بالعقد ، وينبغي على ذلك أنه في حالة التأخير في التنفيذ يكون الضرر مفترضاً وقائماً حتماً بمجرد حصول التأخير ،لما ينطوي عليه التراخي في تنفيذ هذه العقود في حد ذاته وبغض النظر عما عساه أن يقع من أضرار أخرى-من إحلال بالنظم والترتيبات التي تضعها الإدارة و تحرص على التزامها ومن تعويق ولو جزئي لحسن سير دولا ب الأعمال الحكومية وتتابع حلقاته وترابطها،وفي ذلك ولا ريب مساس في الصالح العام الذي ينبغي أن يكون دائماً محلاً للاعتبار بالعقود الإدارية .

وهذا ما أكدته محكمة القضاء الإداري في مصر في حكمها الصادر في ١٩٥٦/٤/١ الذي يقول:إن تنفيذ الالتزامات التعاقدية في عقود القانون الخاص التي تبرمها الإدارة لا يجري على هدي القواعد التي يتم على أساسها تنفيذ العقود الإدارية،ففي العقود الخاصة تطبق أحكام القانون الخاص ،والحال على خلافه في ميدان العقود الإدارية ،إذ يصبح المتعاقد إلى حد كبير بمثابة المتضامن مع الإدارة في الأخذ بناصر المرفق العام والحرص على استمرار حركته وإدارة نشاطه ،ولهذا الوضع أثره في تنفيذ التزام المدعي المتعهد بالتوريد إذ يتعين عليه أن يقوم بتنفيذ التزامه وفقاً لطائفة من القواعد والأصول التي هي أكثر شدة وأمعن دقة من تلك التي يجري تطبيقها في ظل عقود القانون الخاص ،والمصلحة العامة التي تهدف إلى انتظام سير المرفق العام تحرص على إتباع تفسير حاسم للالتزامات من تعهد بالتوريد ،وفي مقدمة تلك القواعد والأصول التي تحكم عقد التوريد الإداري أن المصلحة العامة لا تنتظم سير المرفق العام لا يصح أن تتأثر في

شيء بالمصلحة الخاصة التي تشغل بال المتعهد بالتوريد، فعليه وقد ارتضى أن يساهم بتصيب بنشاط هذا المرفق العام مضاعفة الدقة والحرص في تنفيذ ما تعهد به من التزامات^١.

هذا وتنوّه بأن التعاقد قد يضطر لإلحاز بعض الأعمال الضرورية لتنفيذ المشروع التعاقد عليه، كما أنه قد ينجر أعمالاً لا تسلمها الضرورة الملحة، لكنّ هذا التنفيذ يعود على الإدارة بفائدة لا شك فيها، ففي حال الأعمال الضرورية بحسب التعاقد على أساس السعر المتفق عليه، وقد تبين القضاء رأيّه هنا على أساس قيام إرادة ضمنية بذلك.

أما في حال الأعمال المفيدة فيحاسب التعاقد على أساس ما عاد على الإدارة من فائدة وفقاً للنية المفترضة للطرفين : Suppose إذ يفترض أن المتعاقدين قد رضيا مقدماً أن يكون التعاقد يشمل تنفيذ جميع الأعمال اللازمة للمشروع المتفق عليه^٢.

^١ مجموعة أحكام مجلس الدولة الثالثة العاشرة ص ٢٧٣.

^٢ أحكام مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ ١٩٢٢/٤/٥ المجموعة ص ٣٢٥.

البحث الثالث

دور العادة في تفسير العقد

نعود فنؤكد بأننا نعتبر العادة إحدى الآليات الذاتية لتفسير العقد في حين ستعامل مع العرف بصفته حقيقة موضوعية في تفسيره، أي بصفته قاعدة قانونية عامة وبمجردة، وتنطوي على قوة إلزام ذاتي خاص مستمدة من طبيعتها الموضوعية دون أن تنوجه إرادة الأفراد الصريحة أو الضمنية للأخذ بها، وهذا ما يتضح من المادة ١٤٩ مدني سوري، فقد استعانت صراحة بالعرف لتكملة العقد، والحال نفسه بالنسبة للمادة ١٥١ مدني سوري، فقد استعانت به أيضاً لتفسير العقد تفسيراً موضوعياً وبمجرداً، وبالمقابل فلا يمكن للعادة أن تفسر النية المشتركة للمتعاقدين أو عبارات العقد الغامضة إلا إذا توجهت إرادتهما للعمل بموجبها، وبالتالي فلا يمكن الاعتماد على عنصر خارجي عن النية المشتركة إلا من خلال هذه النية معبراً عنها بقبول العادة، وليس العرف^١.

هذا والحديث عن العادة يقودنا إلى تقريع هذا البحث إلى فرعين :
نتكلم في الأول على العادة في القانون الخاص على أن نتكلم في الفرع الثاني على العادة في القانون الإداري.

^١ بلدينا في ذلك د. أحمد توفيق محمد عبد الرحمن قواعد تفسير العقد ص ٨٢.

الفرع الأول

دور العادة في تفسير العقد في القانون الخاص

وسنفرع على هذا الفرع مطلبين :
الأول نتكلم فيه على شروط الأخذ بالعادة ،على أن نتكلم في الفرع الثاني
على أنواع العادات.

المطلب الأول

شروط الأخذ بالعادة في القانون الخاص

سنخصص لهذا المطلب بدين نتكلم في الأول على وجود غموض في
عبارة العقد على أن نتكلم في البند الثاني على ضرورة قيام الموافقة
الصريحة أو الضمنية على العادة.

البند الأول: وجود غموض في عبارة العقد :

يشترط لإعمال حكم العادة من أجل تفسير شروط العقد ألا يشتمل
العقد على شروط تعارض مع حكم العادة^١ هنا فضلاً عن أنه لا يجوز
إثبات عكس الشروط المكتوبة إلا بالكتابة.

وتمعنى أوضح فلا محل للعادة في تفسير العقد إلا إذا كان هنالك غموض
في التعبير عن النية المشتركة.

^١ Larombière, t.2, art, 1160, P 120

انظر نقض مني مصري : ١٩٤٠/٣/٢٨٠ مجموعة القواعد القانونية ملحق رقم ٩٩ ص ٨٤٧ مقرة

وانظر د. السعيد الوحيدي ج ١ فقرة ٣٩٧.

ذلك لأنه مادام لم يتوفر في العادة الركن المعنوي فهي مجرد واقع مادي لا تتمتع بأي قوة أو قيمة قانونية تفرض ذاتها على العقد أو غيره ، وقولها القانونية مستمدة من انصراف إرادة المتعاقدين للأخذ بها .

بقي سؤال حدير بالطرح وهو هل يمكن الحديث عن الغموض على الرغم من استخدام العبارات الواضحة ؟

يرى الأستاذ Callatay أنه يمكن الرجوع إلى العادة رغم وضوح عبارة العقد ، ذلك أن سلطة القاضي في التفسير تنشأ عند وجود شك ، وقد يتحقق ذلك نتيجة التعارض بين عبارات العقد الواضحة والعناصر الخارجة عنه^١ .

ويتهيأ صاحب هذا الرأي للقول بإمكان تطبيق العادة باعتبارها تعبير عن النية المشتركة للمتعاقدين على الرغم من وضوح عبارة العقد ، وسنده في ذلك أحكام القضاء الفرنسي^٢ .

وهذا الرأي غير مقبول للأسباب الآتية :

١ . تعارضه مع النصوص التشريعية ومع القضاء المضطرب كما سبق توضيحه بالنسبة لعبارة العقد الواضحة .

٢ . لا يجوز الاعتماد على عنصر خارجي لإثبات النية المستمدة من عبارات العقد الواضحة ، فذلك يخالف الدليل الكتابي .

٣ . على عكس ما نقول : Callatay فالقضاء الفرنسي لا يجيز تطبيق العادة إلا عند وجود الغموض في عبارات العقد .

^١ - Callatay, These, No. 6, p. 12 -

^٢ - Callatay, These, No. 58, P. 124 -

أما بالنسبة للحكم القضائي الذي استند إليه الأستاذ: Callatay، والذي طبق حكم العادة، فالحقيقة أن القضاء واجه نصاً غامضاً في العقد، والمسألة التي طرحت تتعلق بعقد تأمين ورد فيه شرط يقضي بأن السفينة المحملة بالبضائع يجب أن يتواجد عليها شخص ما على الأقل ليلاً ونهاراً، ولم يرد تحديد هذين الشخصين، لذلك استعانت محكمة الموضوع بالعادة المتبعة التي تسمح للبحارة باصطحاب زوجاتهم وأولادهم، ولقد طبقت حكمها باعتبار أن المتعاقدين يوافقان عليه، واستخلصت المحكمة أنه يكفي أن يترك المؤمن له زوجته وابنته التي تبلغ الثامنة عشرة، حيث أن الغرض الذي يقصده المتعاقدان هو ترك شخصين على المركب قادرين على المشاركة في الأعمال المختلفة دون اشتراط أن يكون من الرجال، ولقد أبدت محكمة النقض ذلك^١.

وعلى هدي ما تقدم فالقضاء المصري يشترط غموض العبارة من أجل تطبيق العادة^٢. ومع ذلك فقد أصدرت الدائرة المدنية لمحكمة النقض المصرية حكماً قضت فيه بأن النص المطلق الوارد في العقد يقيد بالعرف الجاري، إذ لا يجوز التقيد بالألفاظ اللغوية في تفسير المصطلحات، والعبارة كما قصده المتعاقدان مع ملاحظة ما تقتضيه نوع المشاركة والعرف الجاري^٣.

ويرى الدكتور أحمد شوقي تعليقاً على حكم محكمة النقض - أن عدم تقيد القاضي بالمعنى الحرفي لألفاظ العقد بفرض عليه أن يأخذ بالاعتبار

^١ - Cass. com, 2, dec, 1947, gaz. pal, 1948, L.36-

^٢ - نقض مدني ١٩٤٠/٣/٢٨ مجموعة عمر مدنية جزء ٣ رقم ٤٧ ص ١٤١ مجموعة القواعد القانونية ج ٢

رقم ٩٩

^٣ - المجموعة الرسمية س ٣٣ رقم ١٨٤ ص ٣٥٨ مجموعة عمر ج ١ رقم ٤٢.

حكم العادة باعتبارها تمثل النية المشتركة للمتعاقدين، بحيث يكون للعادة القدرة على تخصيص النص المطلق الوارد بالعقد^١. ويتابع الدكتور القول : لا يجب الأخذ بالمفهوم الظاهر لهذا الحكم : إذ أن القاعدة التي استقرت عليها محكمة النقض المصرية تفضي بأن يكون تخصيص العبارة العامة الواردة في العقد مستمداً من عناصره الداخلية، وإلا اعتبر التفسير مسخاً للعقد^٢، وبذلك فدور العادة في تفسير العقد لا يظهر إلا في حال الغموض، وبالتالي فإن محكمة النقض الفرنسية لجأت في هذا الحكم إلى العادة بسبب وجود غموض في العقد، ولا يمكن إجماله على طريق العناصر الداخلية، إذ إن المادة الأولى من عقد المفاوضة يعطي المفاوض الحق في التعويض عن الخسائر التي تلحقه التعليمات المتناقضة أو غيرها إذا أخطر المنشئ عنها حال حدوثها، وقد تم الأخطار بالفعل بمجرد اطلاعه على التصميم الخاطئ، بينما تحرم مقدمة الاتفاق المفاوض من التعويض، وهذا التعارض في النصوص يولد غموضاً يغلب بالاستناد إلى العادة الجارية^٣.

البند الثاني: الموافقة الصريحة أو الضمنية على حكم العادة

لا يمكن بالطبع الأخذ بالعادة إلا إذا ثبت علم المتعاقدين بها وقت التعاقد وموافقتهم ضمناً على ذلك^٤.

^١ د. أحمد طوقى عبد الرحمن ص ٨٦.

^٢ المرجع السابق ص ٨٦.

^٣ المرجع السابق ص ٨٦.

^٤ Carbanriere, T, 2, P. 117-

هذا واعتبار العادة بمثابة الاتفاق الضمني يؤدي إلى تغليبها على حكم القواعد القانونية المكتملة، إذ من المعلوم أن هذه القواعد هي التي يتم تطبيقها في حال عدم استبعادها من المتعاقدين. والتمسك بحكم العادة يقتضي إثباتها بكافة طرق الإثبات باعتبارها واقعة مادية^١.

كما ويجب إثبات الموافقة الضمنية على حكمها، ويتم ذلك بجميع الطرق كالشهادة والقرائن، لأن الأمر هنا لا يتعلق بإثبات حكم يخالف أو يجاوز الدليل الكتابي طالما أن العقد لا يتضمن شرطاً يخالف حكم العادة، ومن ثم فإن غموضه يرفع عنه أي معنى محدد، ويترتب على ذلك أن حكم العادة لا يتصور تعارضه مع الشرط الغامض، بل هو على العكس يؤكد المعنى الذي يشتمل عليه العقد المكتوب متوافقاً مع النية المشتركة^٢.

وقد تنضج موافقة المتعاقدين الضمنية على حكم العادة من القرائن المختلفة، ومن ذلك القرائن المهنية التي يحترفها المتعاقدان^٣. ذلك أنه باتحاد هذه المهنة وتعلق العقد بعمل من أعمالها قد يفيد علم المتعاقدين وموافقتهما ضمناً على اتباع حكم العادة الخاصة بتلك المهنة^٤. وعلى العكس لا يفترض موافقة المتعاقدين على حكم عادة تتعلق بمهنة لا يحترفها كلا الطرفين^٥.

^١ كتابا الموسوم بعنوان نحو نظرية عامة للمعروف الإداري، دمشق مطبعة عكرومة ١٩٨٤ ص ١١٥.

^٢ د. أحمد شوقي محمد عبد الرحمن ص ٨٧.

^٣ Laromliere, T.2, P.117.

^٤ Orléans, 17 Avril, 1959, Gaz. pal. 1959, 2, 125.

^٥ V. Paris, 4 Janvier, 1934, D. II, 105.

المطلب الثاني

أنواع العادات المعبرة عن النية المشتركة

هذه العادات هي :

العادات المكانية - العادات الخاصة بطرفي العقد.

البند الأول: العادات المكانية

يجب أن تكون العادة سائدة في المكان الذي أبرم فيه العقد، أو الذي ينفذ فيه، وقد أشارت المادة ٣٥٩ مدني فرنسي إلى العادة السائدة وقت إبرام العقد، لكن الفقه يجمع على حوزة استناد القاضي إلى عادات المكان الذي نفذ فيه إذا وجد أن هذه العادات هي التي تتوافق مع النية المشتركة، وعلى القاضي أن يقدر وفقاً للظروف المختلفة نوع العادات المكانية التي وافق عليها المتعاقدان ضمناً^١.

البند الثاني: العادة الخاصة بطرفي العقد

وذلك بالاستناد إلى عقودهم السابقة، أما الاتفاقات اللاحقة فليس لها أهمية في تفسير العقد السابق عليها^٢.

وعلى ذلك يمكن إعطاء الشرط الغامض المعنى الذي يتوافق مع المعنى الذي صرح به الاتفاقات السابقة على إبرام العقد، ويشترط أن تكون العقود السابقة قد تمت بين طرفي العقد المراد تفسيره^٣.

أما إذا صدرت الاتفاقات السابقة عن أحد الأطراف فيمكن أن يحتاج في مواجهته بالمعنى المستمد من هذه العقود^٤.

^١ - Orleans, 17 Avril, 1959, gaz. pal.

^٢ - Alexandrie mixte, 24 Mars, 1910.

^٣ - Laurent, T. 16, No. 503.

^٤ - Demrent, T. 25, No. 10, P. 9.

وتطبيقاً لقاعدة عدم حوز اصطناع الشخص الدليل لنفسه، فلا يجوز للمتعاقد الذي كان طرفاً في عقود سابقة أن يحتج في مواجهة المتعاقد الآخر بأحكام هذه العقود السابقة التي لم يكن طرفاً فيها^١. وفي حال التعارض بين العادات المكتوبة والعادات الخاصة يجوز للقاضي أن يقدر أن هذه الأخيرة هي المنفقة مع النية المشتركة^٢.

الفرع الثاني

العادة الإدارية ودورها في تفسير العقد الإداري

في هذا الصدد نسجل الملاحظات التالية :

- (١) نقصد بالعقد الإداري : *contrat administration* العقد الذي تظهر فيه السلطة الإدارية بصفتها سلطة عامة تمارس أساليب القانون العام في إبرام عقد يتصل بتنظيم المرفق العام أو تسييره. أما إذا كان عقد إدارة : *acte de administration* ، وليس عقداً إدارياً فهو يخضع لكافة أحكام القانون المدني سواء فيما يتعلق بتفسيره أم انعقاده أم آثاره ، وغير ذلك من الأحكام.
- (٢) لا يشترط في العادة الإدارية أن يكون منشؤها محمولاً على شروط اتفاقية متكررة ، بل العكس فعلى صعيد الإدارة يمكن أن تنشأ عادة من تكرار قرارات إدارية ، وهو الأمر الذي حدا (جيني) لتسميتها بالعادة الإدارية^٣ ؛ وبالطبع يجب هنا أيضاً انصراف إرادة المتعاقدين صراحة أو ضمناً للأخذ بالعادة حتى يمكن اعتبارها أداة للتفسير.

^١ - Req. 8 janvier, 1894. S. 1895, I, 174.

^٢ - د. أحمد شوقي عبد الرحمن : قواعد تفسير العقد ص ٨٩.

^٣ - كتابه : *Méthodes d'interprétation et sources en droit privé positif*, Paris, 1954, T. 1.

٣) واستناداً إلى العنصر الاتفاقي الذي يمنح العادة القوة الملزمة - حيث تكون مجرد واقعة مادية - فهذه القاعدة تسودها مبدأ حسن النية ويعمل بها في حدود النظام العام والآداب العامة ويستبعد ما يخالفها من قواعد قانونية مقررّة، وباختصار فهي جزء من اتفاق الطرفين وتكون ملزمة لهما كما لزم محتويات العقد وفقاً للمبدأ القائل : العقد شريعة المتعاقدين^١.

وفي هذا الإطار هنالك نقطة حديرة بالاهتمام هي أن العادة الاتفاقية الإدارية تقترب من العرف في ركنها المادي ، كما تقترب من عادات الحياة العامة لجهة عدم تحقق الركن المعنوي، فهي إذن تقوم على قاعدة تنظيمية إدارية تخلقت وتكررت واضطردت وصعدت في سلم التدرج مقترنة جداً من النظام الموضوعي^٢.

وفي الواقع فالعادة تبدأ بحمل فردي عليه واقع خاص ، ويدور في الإطار الضيق للإرادة الذاتية، بحيث يتأثر بكثير من المؤثرات لكن بعض هذه العناصر تأخذ مع الزمن مظهراً أكثر ثباتاً وهنا يلد الشرط الجاري : *Clause de style*، حيث يتم التصرف ويفرغ في فوالب ، وشيئاً فشيئاً يتسلخ هذا التعامل من الإرادة الفردية ليصبح قاعدة موضوعية^٣.

والحياة الإدارية ثرة وممتلئة بهذه الشروط الحارية التي تسمى في سورية كرامة الشروط أو دفاتر الشروط أو العقود السودجية^٤.

^١ الفريد في الموضوع تراجع كتابها نحو نظرية عامة في العرف الإداري المرجع السابق ص ١٤٧.

^٢ سبق المرجع السابق ص ٤١٩ وانظر كتابنا العرف الإداري ص ١٧٥.

^٣ د. عبد الممنع الشراوي : المدخل للعلوم القانونية - بيروت دار النهضة العربية ١٩٦٩ ص ٢١.

^٤ سبق المرجع السابق ص ٤١٢ وانظر كتابنا العرف الإداري ص ٦٧.

^٥ د. الطماوي : الأسس العامة للعقود الإدارية ص ٣٧٤ وما بعدها - د. عبد الإله الحلبي : القانون الإداري المجلد الرابع ص ٤٠ - د. سوار النظرية العامة للالتزام ص ٣٢٦.

تبقى النقطة الهامة الجديرة بالاهتمام، وهي إن هذه الشروط الجارية بنوعين عليها أن ترسم حدود النظام العام والآداب العامة موهين بأن معظم القواعد التنظيمية الإدارية هي من النظام العام^١.

٤) هذا الاقتراب الموضوعي بين العادة والعرف حدا بعض الفقهاء للقول بأن العادة تقيم قرينة على وجود اتفاق بين المتعاقدين للأخذ بها، وتفترض على المتعاقد - انطلاقاً من مبدأ حسن النية - أن يعلم الطرف الآخر بأنه لا يريد الخضوع لها.

وإذا كان التمسك بهذا الرأي في مجال القانون الخاص فهذا التمسك من باب أولى على صعيد القانون الإداري لأن العادة الاتفاقية هي ظاهرة ابتنائية تنشأ من صميم الحياة الإدارية، وتفترض علم الإدارة بها وتمسكها بأحكامها. مع كل هذه المعررات، فقد رفضنا هذا الرأي، وقلنا إن العادة الاتفاقية لا تقيم حتى مجرد قرينة بسيطة إلا إذا انتهت الإرادة للأخذ بها صراحة أو ضمناً^٢. بيد أنه يجب أن لا تغفل وساحة الرأي القائل بالتمييز بين اعتياد الإدارة على عادة خاصة بها، وبين عادة أخرى خارج الإدارة، فهذه العادة الأخيرة لا يمكن أن تفسر إرادة الإدارة إلا بالتوجه الصريح للأخذ بحكمها، أما العادة الأولى فمن الممكن أن تعبر عن الإرادة الضمنية للإدارة (طالما أنها اعتادت عليها في موضوع معين أو في منطقة معينة أو ضمن ظروف محددة، أو لم تقم باستبعاد حكمها، أو لم تقم بتنظيم المسألة التي تحكم هذه العادة^٣).

وطبيعة الحال فإذا نشأت العادة في كنف الإدارة، وتحقق فيها شرط الركسن المعنوي الذي هو قبول الإدارة و المتعاملين معها للعادة، فهذا تصبح تلك العادة

^١ د. عدنان القوتلي: الوحد بالحقوق المدنية دمشق دار الفكر طبعه ٧ ١٩٦٣ ص ٣٧٤.

^٢ كتابا العرف الإداري ص ١٧٦.

^٣ هذا الرأي الأخير للدكتور عدنان خليل جمعة، انظر كتابا العرف الإداري ص ١٧٦.

ملزمة للإدارة، وهذا ما أكدته حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في ١٩٥٤/٧/٢، حيث استعان بتفسير العقد على ضوء العرف الإداري الذي نشأ بالإدارة^١. ولقد كان للفقهاء في سورية دور واضح في إلقاء الضوء على هذه الناحية، فقد درسها الدكتور سوار تحت جهاز مفاهيمي أطلق عليه اسم (مستلزمات العقد في الأنظمة الخاصة)، عدد فيه الأنظمة الإدارية الخاصة ببعض النشاطات للمهية والشركات المؤممة، حيث تستطيع الدولة أن تحدد بذاتها مستلزمات العقود التي تبرمها مع الأفراد (عقود العمل المشتركة والعقود النموذجية) ولقد حفظ الدكتور سوار، واستلزم موافقة المتعاقدين على هذه العقود صراحة أو ضمناً^٢.

٥) افترضنا سابقاً أن العرف أو العادة ينشأان بين حبات الإدارة، ولكن ما هو الشأن بالنسبة للأعراف أو العادات التي تنشأ في الحياة العامة؟ بالنسبة للعرف، فالأصل أنه يصدر عن إرادة الإدارة إضافة إلى قبول المخاطبين به، والمتأثرين بأحكامه (أصحاب المصلحة)، وفي هذه الحال يمكن الحديث عن التزام الإدارة أي عن نشوء عرف إداري.

لكن السؤال المطروح هو ما الشأن بالنسبة للعرف التجاري الذي ينشأ في الحياة التجارية، ويوسع من رضاء التجارة خارج نطاق الإدارة وقبولها.

في الحقيقة يمكن الأخذ بهذه الأعراف والتي هي أعراف القانون الخاص - إذا كانت لا تتعارض مع مبادئ القانون الإداري وأحكامه وأصوله العامة، وهذا ما أكدته إجماع الفقهاء الإداريين^٣ واضطراء القضاء الإداري، وبالأخص في عقود التوريد، وفيما يتعلق بتجارة الصوف^٤.

^١ حكم مجلس الدولة الفرنسي: ١٩٥٤/٧/٢، مجلة القانون العام سنة ١٩٥٥ ص ٢٢٧.

^٢ كتابه النظرية العامة للالتزام ص ٣٢٢.

^٣ الطنطاوي: الأسس العامة للعلوم الإدارية ص ٢٢٨ - عبد الإله اعلي قانون الإداري، مجلة الرابع ص ٢٢٢.

^٤ مجلس الدولة الفرنسي: ١٩٢٧/٧/٨ قضية Lacamus الحكومة ص ٧٦٥.

المباحث الثاني

التفسير الموضوعي

تمهيد :

ونقصد بالتفسير الموضوعي : Objective مجموعة القواعد العامة: Generale

والمجردة : abstraite التي يلجأ إليها ويستعان بها في تفسير

إرادة الأفراد، ويقوم بهذه المهمة على صعيد القانون المدني مجموعة القواعد المكتنة

Complementary أو المفسرة : Interpretative :

فهذه القواعد يلجأ إليها عندما يغفل المتعاقدان عن تنظيم أمورهم فيلجأون إلى هذه القواعد التي يفرض ألها استدركت فأكملت هذا النقص .

والقانون الإداري - كما هو معروف - يسب في محله وتثنائه إلى القضاء الإداري ، لذلك فهذه القضاء ، وفي حال سكوت المتعاقدين - يعتمد إلى إنشاء وانتداع الأحكام ذات المبدأ : acte de principe التي تقوم بهذا التفسير ، والمثال الحي على ذلك يتجلى في الإرادة المفترضة التي سبق الإشارة إليها والتدليل على أحكامها .

وبين ذلك أنه - حيل دينامية العقد الإداري و حركيته ، ولحل الجدلية القائمة بين هذه الحركية وبين استقرار النية المشتركة - لم يكن أمام القاضي الإداري إلا افتراض قيام إرادة مفترضة من قبل المتعاقد تسمح للإدارة بتعديل العقد ومواحهة تغير الظروف ، وغير ذلك .

وحقيقة الأمر أن التفسير الذاتي يفترض وجود وسائل وأساليب خاصة ومحددة من أجل الكشف عن النية المشتركة للعقد ، كل عقد على حدته ، وتختلف هذه الوسائل من عقد إلى آخر حسب الحافات والظروف المحيطة

Circonstances: وعلى خلاف ذلك فالتفسير الموضوعي يضعنا في مواجهة

معايير موضوعية تحيط بالعقد ، لكنها في النهاية تصلح لتفسير أي عقد ، وهذا ما أكدته المادة ١٥١ مدي سوري بقولها :

إذا كان هالك محل لتفسير العقد، فيجب البحث عن البية المشتركة للتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين.

إذن فهذه المعايير الموضوعية هي : طبيعة التعامل - الأمانة والثقة - العرف الجاري . ونشر استطرادا إلى أن النص الآنف الذكر عرض هذه المعايير على سبيل المثال لا الحصر ، وبذلك يمكن الاستعانة بوسائل وأساليب أخرى لا سيما فكرة الصالح العام التي تلعب دورا هاما في تفسير العقد الإداري وإضائة روحه وتحديد توجهاته العامة .

ومن جهة أخرى فقد قمنا بتقسيم الكتاب انطلاقا من وضوح العبارة أو غموضها ، لكن واقع الحال يطرح حالة ثالثة هي كون العبارة ليست صريحة وليست غامضة ، بل يعنورها الشك ، وبالتالي يصعب تفسيرها باللجوء إلى الافتراضين السابقين ، وهنا -وسبب انعدام المادة الثانية أمام القاضي - يتعين على القانون أن يسعف القاضي بالمعايير والأحكام لمواجهة تلك الحال . ولقد أتى القانون المدني على ذكر القاعدتين الآتيتين من أجل هذه الغاية وهما :

حال الشك لمصلحة المدين ، ثم حال الشك في عقود الإذعان.

وهاتان الحالتان تدخلان في نطاق التفسير الموضوعي للعقد ، وبذلك نتحدد عناصر التفسير الموضوعي في الأمور الآتية :

الصالح العام - طبيعة التعامل - الأمانة والثقة - العرف الجاري بالمعاملات قاعدة الشك لمصلحة المدين - تفسير عقود الإذعان .

وفيما يلي بحث هذه العناصر :

البحث الأول

الصالح العام

يتردد هذا المفهوم بغزارة في ادبيات القانون الإداري، وهو أمر طبيعي لأن أساس القانون الإداري ومعياره يكمن في الصالح العام^١.

وحسبنا التعرّيج على بعض الأسانيد الشمولة على هذا المعيار

❖ فتوى الجمعية العمومية لمجلس الدولة المصري رقم ٦٣٧ تساريخ ١٩٥٦/١٠/٢٣، وقد جاء فيه: إن العقود الإدارية تختلف في طبيعتها عن العقود المدنية، ذلك لأنها تعقد من قبل شخص من أشخاص القانون العام وشخص من أشخاص القانون الخاص بقصد تحقيق مصالح عامة، ومركز التعاقد فيها غير متكافئ، إذ يجب أن يراعى فيها تغليب الصالح العام على الصالح الخاص^٢.

❖ حكم محكمة القضاء الإداري في مصر الصادر في ١٩٥٦/٩/٩، وحكمها الصادر ١٩٥٦/٩/١٦، وقد أكد هذان الحكمين ضرورة تغليب المصلحة العامة على مصلحة الأفراد^٣.

وهذا هو عين حكم هذه المحكمة الصادر ١٩٥٧/٦/٣٠ الذي رجحت فيه إعمال قواعد التفسير لصالح المصلحة العامة، قالت هذه المحكمة: أما حيثما تتعارض مصلحة أحد الطرفين وبعبارة أدق المصلحة الشخصية للمتعاقد مع

^١ يجب التمييز بين أساس القانون الإداري الذي هو الجواب على السؤال لماذا ونحن المعيار الذي هو جواب السؤال من؟.

^٢ لورد هذه الفتوى الدكتور الطمناوي: الأسس العامة للعقود الإدارية ص ٤٤.

^٣ القضية رقم ٨٧٠ سنة ١٦٠٩ لسنة ١٠ قضائية وحكمها الصادر ١٩٥٧/٦/٣٠

القضية رقم ٩٨٣ سنة ٧ قضائية وسكك المحكمة الإدارية العليا في مصر الصادر في ١٩٥٧/٤/٢٠ السنة الثانية ص ٩٣٧.

الإدارة مع المصلحة العامة ، فإنه ينبغي أن يكون التفسير إلى جانب المصلحة العامة ، أي ضمان حسن سير المرفق العام بانتظام^١ .

ويمكن القول بيقين إن مجلس الدولة المصري في حكمه الصادر ١٩٥٧/٦/٣٠ وضع الدستور الذي يستهدي به في تفسير كل ما يتصل بالعقود الإدارية ، ولهذا كان لزاماً أن نعرض على فكرة الصالح العام كضوء كاشف في تفسير العقد الإداري ، ونحن نجتزئ بعض فقرات الحكم الآنف الذكر المتضمن:

وأن يكون مناط التفسير الكشف عن النية المشتركة للمتعاقدين على أن يراعى في هذه الحال ما تتميز به العقود الإدارية من العقود المدنية من خصائص وطبيعة تجعل له سلطاناً قانونياً يختلف كل الاختلاف عن النظام الذي تخضع له العقود المدنية ، وعلى رأس هذا النظام الخاص ، فالعقود الإدارية تبرز قاعدة أساسية جوهرية تسود قاعدة تفسير العقود الإدارية ، هي أن هذه العقود تقوم أولاً وقبل كل شيء على فكرة المصلحة العامة وضمنان حسن سير المرافق العامة ، فإذا ما دعت الحال إلى الكشف عن النية المشتركة للمتعاقدين ، فيجب أن يتجه السراي الأول إلى أن هذه النية ليست إلا تحقيق المصلحة العامة ، وحسن سير المرفق.

وما رددناه حتى الآن يدخل في إطار البديهيات القانونية ، لكن المهم هو تحديد المقصود من الصالح العام بصفته فكرة فنية قانونية صياغية ، ثم إبعاد - عن طريق الضبط والتحديد - هذه الفكرة عن مهمات السياسة التي تعطيها مدلولاً سياسياً ضامياً لرجاء.

وحقيقة الأمر أن القانون الإداري ولد في أحضان السلطة^٢ والسياسة لذلك كان لابد من بذل جهد كبير لزرعه من برائن السلطة ، وخرسيته على مزيد من الضبط

^١ سبق الإشارة إلى هذا الحكم .

^٢ درثوت بنوي مبادئ القانون الإداري القاهرة دار النهضة العربية ١٩٦٦ ص ٥٣ وما بعدها .

والتحديد ،وقد ابتدأت الخطوة الأولى في ذلك بحجر معيار أعمال السلطة *acte d'autorité* الذي كان يعتبر الأوامر الإدارية معيار انطباق القانون الإداري .

المهم في كل ذلك أن فكرة السلطة العامة التي اعتبرت في مرحلة من المراحل أساساً للقانون الإداري هذه الفكرة لم تعد نظرية إيديولوجية تقوم على اعتبارات سياسية ،بل أصبحت فكرة قانونية تعتمد على عناصر فنية و تقنية .

والخلاصة : أن معيار السلطة العامة في صورته الجديدة التي رسمها العميد فيدل لا يقوم على تلك الفكرة النظرية الوهمية أو التصورية التي سادت زمناً طويلاً في الفقه الإداري ،والتي كانت تعد السلطة العامة مجرد تعبير عن الإرادة العليا للحكام ،ونظراً إلى هذه الإرادة باعتبارها - في جوهر طبيعتها - تختلف عن إرادة الأفراد وتسمو عليهم ، وإثماً يقوم معيار السلطة العامة على أساس أن السلطة ليست إلا مجموعة من الاختصاصات غير المألوفة في القانون العام ،والسلطة العامة ليست تعبيراً عن إرادة عليا للحكام ،وإثماً هي مجرد ممارسة لأساليب معينة أو اختصاصات لا يملكها الأفراد العاديون تتبعه لكون الحكام يعملون باسم المجموع ولصالحهم ،وهذا ما عبر عنه فيدل بقوله ¹

((La puissance publique, ce n'est pas seulement en fasceau de competnces)) وليلاحظ القارئ أننا استعملنا عبارة ((أساليب ووسائل)) ،وهذه الأساليب منح لرجل الإدارة لتحقيق الصالح العام ، ولم نستعمل كلمة امتيازات ،لأن هذه الأساليب تنطوي في ذاتها وفي بعض الأحيان على أعباء وتكاليف تفرض على الإدارة من أجل تحقيق الصالح العام الذي يكمن جوهره في سير المرفق العام .

¹ كتابه الأسس الدستورية للقانون الإداري ،مقال منشور في مجلة مجلس الدولة الفرنسي (دراسات ورسائل) سنة ١٩٥٤ ص ٤٢.

واستناداً إلى ما تقدم فإذا كان هنالك غموض في تفسير شرط عقدي، وكان هذا الشرط يتعلق بالبند المالي الصرف، فهذا البند لا يتصل بالصالح العام، ذلك الصالح الذي يقتصر على سائر المرفق العام.

ذلك أن الشرط المالي، هو هذا الشرط التعاقدي الأصيل في العقد الإداري لذلك فالإدارة لا تستطيع أن تمسه في التعديل، وأساس ذلك حصانة ذلك الشرط وجوده، *intangibilite* فهو يمثل جوهر العملية التعاقدية^١، وبذلك ترجع في تفسير العقد إلى قواعد التفسير العامة في القانون المدني التي تعامل المتعاقدين على قدم المساواة دون أن تمنح الإدارة أي حق امتياز في هذا المجال.

وفي إطار ما تقدم فإن مبدأ التفسير لصالح الخزنة، ولصالح نظرية الاعتمادات المالية بالنسبة للقرار الإداري، هاتان النظريتان كانتا موضع نقد شديد، -على الأقل بالنسبة للنظرية الثانية- ونحن نضع تحفظات كثيرة على تلك النظريتين بأفاههما المتعددة^٢ ونشجب - في أضيق الحدود وفي إطار العقد الإداري - هاتين النظريتين، ونرى أن تعامل الإدارة فيما يتعلق بالشرط المالي بدقة وعلى قدم المساواة مع الأفراد لا تنفاه مبررات تطبيق نظريات القانون الإداري في هذا المجال^٣.

وهناك ملاحظة هامة هي أن المعركة التي دارت رحاها حول نظرية التفسير لصالح الخزنة أو لصالح نظرية الاعتماد المالي، هذه المعركة نشبت في إطار النص القانوني، وليس في إطار العقد الإداري، وهو الأمر الذي يتيح للنص أن يثبت روحاً معينة لصالح الخزنة، لكن هذا النص لا يتدخل في إطار العقد ليفسر إرادة

^١ د. الطماوي الأسس العامة للعقود الإدارية ص ٥٦٩، ص ٥٧١.

^٢ تلك النظريتين تطبقان متعددة خارج العقد الإداري.

^٣ للتريد والإسهاب في ذلك يراجع الدكتور محصور، مذاهب المحكمة الإدارية العليا في الرقابة والتفسير والابتداع، القاهرة مطبعة العائلية ج ١ ١٩٥٧ ص ١٤٩.

على حساب إرادة أخرى ، وبذلك يمكننا التأكيد أن الشرط المالي على صعيد القانون الإداري لا يخضع تفسيراً وروحاً إلا لقاعدة المساواة .

البحث الثاني

مبدأ حسن النية

ولقد سما هذا البحث بعنوان "مبدأ حسن النية" قاصدين بالمبدأ قاعدة القواعد، أي تلك القاعدة الكبرى التي يمكن أن يفرع عليها تطبيقات كثيرة في صيغة قاعدة.

ومن هذا المنظور فحسن النية يتغلغل في جميع فروع القانون ، ويشكل نسيجاً عاماً في بنية النظام القانوني .

وليس عجباً فالقانون يتفعل - كما هو معلوم - في الأخلاق لا سيما في الدستور الخلقى الأعظم ((الناموس الأدبي)) للجماعة أو للمحس البشري ، وحسن النية هو بذلك قاعدة خلقية تسربت إلى النظام القانوني ، وهذا ما أكدته الفقه ريبير في كتابه الدائع الصبت الموسوم بعنوان القوى الخالقة للقانون ، حول الدور السارز للقاعدة الخلفية في نطاق الالتزامات لا سيما في إبرام العقود وتنفيذها ، وفي قمع الغش والتعسف برد الضرر ، ورد ما أئرى به الشخص وغير ذلك^١.

ولقد ميزنا في مقدمة هذا الكتاب بين دوافع التعاقد وحسن النية ، وقلنا إن الدوافع عوامل تقسية عميقة الجذور في النفس البشرية ، لكنها لا تدخل في علم القانون ، بل إن القانون يتطلق من لحظة انشاق الإرادة وتكونها ، وفي هذه المرحلة يفترض أن المتعاقدين - وبعيداً عن العمق النفسي - أقاما العقد على لبة حسنة .

^١ كتابه Les forces ératrices du droit, 1955, paris, librerie générale de droit

وانظر د. محمد عصفور : الضبط الإداري ص ١٣ حرسوار : النظرية العامة للالتزام ص ٣١٦

ولقد استعمل القانون المدني السوري تعبير ((ما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة)) وبالطبع فالمقصود بالأمانة ذلك الواجب على المتعاقد ((الذي عليه أن يأخذ التعبر طبقاً لما تقتضيه الأمانة في التعامل فلا يستغل ما وقع من خطأ أو قصور في التعبر في تحقيق فائدة لا حق له فيها مادام قد فهمه على حقيقته^١)) وبالمقابل فالثقة حق للمتعاقد ، فله أن يركن إلى التعبر الذي وجه إليه بحسب معناه الظاهر .

- ما هو شأن حسن النية على صعيد قانون الإداري ؟
كما قلنا سابقاً فهذا المبدأ يسود كافة مجالات القانون وفروعه ، وهنالك قاعدة مستقرة في فقه القانون أن الغش يفسد كل شيء^٢ *Fraus, Corrupti* .

لكن الملاحظ أن حسن النية نادراً ما يجد تطبيقاً له مرتكياً من قبل الإدارة ، بل معظم تلك السقطات ترتكب من قبل الأفراد ، وهو الأمر الذي نحدد لذلك تطبيقات متعددة على صعيد القرار الإداري^٣ .

ذلك لأن من المفروض أن تكون الإدارة العقل المطلق أو المبدأ الخلقى حسب تعبير هيجل ، فهي بعيدة عن اللدد والخصومة والنزوات الشخصية العارضة والطارئة ، ومن المفروض بقراراتها وأعمالها القانونية أن تنبع من ظروف المرفق بمنأى عن أي باعث شخصي ، وهو ما عبرت عنه محكمة القضاء الإداري في مصر في حكمها الرائع الذي أرست فيه أدب الخصومة الإدارية المنظمين : إن الحكومة في مخاطبتها للأفراد ، أو في مخاطمة الأفراد لها يجب أن تكون مثلاً يحتذى في معالجة الدعاوى والجواب عليها والتزام الحدود المشروعة للدفاع ،

^١ د. سوار : النظرية العامة للائتمان ص ٣١٦ حـ. السنيوري : التوجيه في شرح القانون المدني ١٩٦٩

القاهرة دار النهضة العربية ص ٢٣٣ .

^٢ النظرية العامة للقرارات الإدارية القاهرة دار الفكر العربي ١٩٦٩ ط ٣ ص ٧٠٣ .

^٣ المراجع السابق ص ٧٠٤ .

فترفع عن إنكار الحقائق الثابتة أو إخفائها ، فتبادر إلى ذكر الوقائع الصحيحة الماثلة في الأوراق التي بين يديها ، وتباعد بينها وبين العنت الذي يرهق خصمها بغير مقتضى ، وهي إذ يطلب منها التزام الحدود ، فذلك لأنها خصم لا يغري العدوان على حقوق الناس ويعاون ، القضاء في الوصول إلى الحل أبأ كان جانبه خصوصاً عندما يكون زمام الحقيقة في يدها بما هو موجود لديها من أوراق تقصر الوسائل المحددة لخصمها عن تبيان ما فيها والوصول إلى مضمونها ، ومن هنا يختلف حسابها عن حساب الأفراد عندما يقفون بعضهم البعض موقف اللدد في الخصومة أو التماهي في الإنكار أو التغالي فيه أو العنت أو إساءة استعمال حق الدفاع^١.

ولقد ذكرنا سابقاً أن حسن النية هو المدخل الذي يحول دون وفسوخ رجل الإدارة في التعسف ، وبذلك فالأغلب أن لا يواجه رجل الإدارة بالانحراف في استعمال سلطته.

ومع ذلك فالإدارة لا تعفي من شرط حسن النية ، ومن خضوعها لهذا المبدأ أو لضرورة أن تأسس وتحكم به سواء لدى تنفيذ العقد أو في فهمها و تعاملها مع لغة العقد.

وهذا ما أكدته محكمة القضاء الإداري في مصر في حكمها الصادر في ١٩٥٧/٦/٣٠ ، قالت هذه المحكمة : فإذا ما دعت الحاجة للكشف عن النية المشتركة فيجب أن يتجه الرأي الأول إلى هذه النية التي ليست إلا تحقيق المصلحة وحسن سير المرفق ، ومن هنا وضعت العلاقة بين طرفي العقد على

^١ الطعان رقم ١١٤٢ ورقم ١٢٣٠ سنة ٥ قضائية جلسة ١٩٥٦/١١/٧ بمجموعة المبادئ القانونية لمحكمة

القضاء الإداري سنة ٩ ص ١٠

أحسن وجه ، وما ينبغي أن يتوافق في الطرفين من أمانة وثقة واحترام للعهد المقطوع بوفاء الالتزامات التي يقرضها العقد^١ .

وهناك تطبيقات عدة لمبدأ حسن النية تم فيها نشر روافد هذا المبدأ :

- فالإدارة لا تستطيع أن تقوم بأي عمل تتعارض مع صفتها كمتعاقدة ، أو تعرض المتعاقد فيها لأعباء ومناعب في تنفيذ التزاماته العقدية^٢ .
- حكم مجلس الدولة الفرنسي بمسؤولية جهة الإدارة المتعاقدة التي لحقت إلى نزاع ملكية بعض الأراضي مما ترتب عليه المساس بحقوق المتعاقد معها^٣ .
- حكم مجلس الدولة الفرنسي بمسؤولية الوزير الذي رفض منح ترخيص بالبيع استنادا إلى سلطات خاصة يستمدّها من القوانين ، إذ ترتب على ذلك ضرر المتعاقد ، وكان العقد يميز له أن يلحقا إلى هذا البيع^٤ .
- حكم المجلس بمسؤولية الدولة إذ أنشأت حديقة عامة ، وترتب على ذلك الخد من حق الصيد الممنوح لشركة من الشركات^٥ ، وهذا هو رأي الفقه في مصر^٦ .

^١ القضية رقم ٩٨٣ لسنة ٧ قضائية.

^٢ د. الطحاوي الأسس العامة للعقود الإدارية ص ٥٦٠.

^٣ حكمه الصادر في ١٤/٣/١٩٤١ ، قضية Roda المجموعة ص ١٤٤

^٤ حكمه الصادر في ٢٧/٦/١٩٢٨ ، قضية Cie générale des îles Kerguelen المجموعة ص ١٣٦.

^٥ حكمه الصادر في ٢٢/١٠/١٩٣٧ ، قضية Cie générale de îles Kerguelen المجموعة ص ٨٣٩

^٦ د. الطحاوي الأسس العامة للعقود الإدارية ص ٤٢٩.

اليحث الثالث

طبيعة التعامل

ويراد بذلك ماهية العقد ونوعيته التي يتحلى فيها الغرض منه، ونعتقد أن ذلك يعتبر ضرباً ومظهراً من مظاهر القانون الطبيعي، ذلك المصدر الكبير لإنجاز القانون وهو ما عبر عنه مونتسكيو بقوله :

((القانون هو النسب الدقيقة الصادرة عن طبائع الأشياء))

وهو المعنى نفسه الذي عرض له ابن خلدون بأنه النسب المركوزة في الأشياء، ولعل رائعة جيني^١ في صياغة القاعدة القانونية ذهبت إلى الأعماق واعتبرت طبائع الأشياء هي المصدر الثر لصياغة القانون.

ذلك أن طبيعة العقد هي المناخ الأعظم والروح الكبرى التي تقصر في النهاية كل ما يتعلق به لأن هذه الطبيعة هي مناط العقد وجوهره ومبتغاه ومرتعاه، هذا فضلاً عن أن هذا المبدأ يفرض نفسه على الإدارة، ويمسك بتلابيبها بصورة أكثر توطئاً أو توطئاً وموضوعية ونجراً، وبالتالي فالإدارة شخص مجرد عن الحوى والسرورات الخاصة فهو رهين تحقيق الغدق ولا يعمل أو يتصرف إلا من أجل ذلك .

على هذا الأساس فإذا تخارج أحد الورثة عن نصيبه في الميراث، فمفسر ذلك على أنه نزول عن جميع حقوقه في الثروة حتى لو كان يحل بعض هذه الحقوق، هذا فضلاً عن أن التخارج لا يتناول حقوقاً موروثة من تركه أخرى^٢.

^١ Geny : méthodes d'interprétation ,op.cie

^٢ درمستور : النظرية العامة للالتزام ص ٣١٦ .

وإذا اشترط المعير في عارية الاستعمال أن يرد المستعير الشيء أو مثله، فلا يفسر ذلك على أن المتعاقدين أرادا عارية الاستهلاك، بل قصد المعير أن يلتزم المستعير في حال هلاك الشيء أن يرد مثله لا أن يدفع تعويضاً^١.

وطبيعة التعامل تفرض نفسها على مسلك القضاء الإداري، وهذا ما يتضح من حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في ١١/٦/١٩٤٤، حيث تضمن أن الالتزامات لا تقتصر على ما ورد في العقد بل تنسحب إلى كل ما تقتضي به العدالة أو العرف أو القانون حسب طبيعة العقد^٢.

ولقد أتيح للقضاء المصري أن يدلي بدلوه في هذا الموضوع، كما يتضح من حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في ٣٠/٦/١٩٥٧ الذي يفتري بعض فقراته، تقول المحكمة:

((من العوامل التي يستهدي بها القاضي للكشف عن هذه النية المشتركة ما يرجع إلى طبيعة التعامل، حيث يختار القاضي المعنى الذي تفتضيه طبيعة العقد، إذ للمعقول أن المتعاقدين قصدا أن يتركا العقد محكوماً بالقواعد التي تفتضيها طبيعة العقد ما لم يصرحا بخلاف ذلك^٣.

^١ د. السنهوري: الوجر في شرح القانون المدني، ص ٢٣٣.

^٢ قضية: Rrziabaut، المجموعة ص ١٨٩، وفي ١٩٥٤/٦/٢ قضية: Galopin مجلة القانون العام سنة ١٩٥٠، ص ٢٢٧، وانظر المادة ١١٣٥ القانون المدني الفرنسي التي تضمنت العبارة ذاتها التي احتلتها مجلس الدولة الفرنسي.

^٣ القضية رقم ٩٨٣ لسنة ٧ قضائية.

البحث الرابع

العرف

وتجدر الملاحظة إلى أننا اعتبرنا العرف مصدراً موضوعياً لتفسير العقد، في حين أدرجنا العادة في إطار النية المشتركة ومنطقتها، وبالتالي فقد اعتبرنا العادة إحدى آليات التفسير الذاتي للنية المشتركة .
وبيان ذلك أن العرف مصدر أساسي من مصادر القانون، فهو يستمد قوته من ذاته، ويفرض نفسه على كافة الوقائع والأشخاص الذين يقعون في دائرته، ولا حاجة له بأية إحالة خاصة من المتعاقدين للأخذ بأحكامه خلافاً للعادة التي هي مجرد واقعة مادية ولا تملي قوتها على المتعاقدين إلا بعد الأخذ بها وبحدود هذا الأخذ .

وما سبق قوله ينطبق على العرف الخاص وعلى أعراف الإدارة^١، كما ينطبق على الأعراف الإدارية، وإن كان لنا توضيح الأعراف الأخيرة بأنها تلك الأعراف التي لا تنطبق إلا في حدود نطاق تكوينها ونموها والاحتصاص بها، بمعنى أن العرف الإداري لا ينطبق إلا في حدود السلطة الإدارية التي ساهمت في إنشائه، إذ قد يكون ناشئاً في كنف سلطة أخرى مستقلة عن السلطة المتعاقدة، اللهم إلا إذا كان عرفاً إدارياً في جهة إدارية عامة أو في وزارة محددة^٢ .

^١ نقصد بعرف الإدارة ذلك العرف الخاضع للقانون المدني

^٢ نراجع ذلك مفصلاً كتابنا : نحو نظرية عامة للعرف الإداري السابق الإشارة إليه .

البحث الخامس

قاعدة الشك لمصلحة المدين ودورها في

تفسير العقد

إذا كانت عبارة العقد غامضة ويتراوح معناها بين وجود متعددة، ولم يستطع القاضي ترجيح أحد الاحتمالات رغم استعانة بعوامل التفسير المختلفة، فهنا يواجه حال الشك، فكيف يتم ذلك؟ هنا انبرى القانون لدعم القاضي بقواعد موضوعية تخرج الخال من هذه العقبة والخائق، فأوجب تفسير الشك لمصلحة المدين، وقد سبق أن عرضنا لهذه القاعدة المتطلفة من طابع الأشياء التي تفترض أن المدين يلتزم بالأقل.

لكن ما المقصود بالمدين؟ الإجابة عن ذلك واضح في عقد التبرع مثلاً، إذ أن المتبرع هو المدين، أما في العقود الأخرى فهي في الأعم الأغلب تتجسّد مركزاً قانونياً : situation يلتقي الالتزام والعبء على كل طرف، بمعنى أن هذا المركز يمنع حقاً ويفرض واجباً في الآن ذاته على كل طرف، فكيف إذن نحدد المقصود من المدين، وبالتالي كيف نطبق قاعدة الشك لمصلحة المدين؟

هنا نفترض قواعد التفسير الآتية :

الفروع الأولى

المدين هو مدين في الالتزام والشرط معاً

مثال ذلك أن يكون ثمة شرط جزائي (تعويض اتفاقي في العقد) ونحوه الشك حول معرفة ما إذا كان هذا الشرط مستحقاً في حالة التأخر في التنفيذ أم أنه لا يستحق إلا في حال عدم التنفيذ، ففي هذه الحال يجب أن يفسر الشرط على أنه لا يستحق إلا عند عدم التنفيذ^١، ومثال ذلك أيضاً أن تشترط عمولة عند عمّام

^١ دسوار المرجع السابق ص ٣٢٠.

كل صفقة دون أن يذكر وقت الدفع، فيفسر هذا على أن الدفع عند تنفيذ الصفقة لا عند عقدها^١.

وإذا كان الشرط يتضمن فرض التزام على أحد المتعاقدين، أو يشدد من مسؤوليته بسبب عدم التنفيذ، مما يزيد على ما تقتضي به القواعد العامة، فالشك يفسر لمصلحة هذا المتعاقد، وهو المدين بالتزام، لأنه هو الذي يقع عليه عبء الشرط (شرط يشدد من مسؤولية المؤجر في الضمان فيفسر في مصلحته) وهو مدين في الشرط، إذ يقع عليه عبؤه، وهو أيضاً المدين في الالتزام بالضمان^٢.

الفرع الثاني

المدين هو المدين في الشرط فقط

((دائن في الالتزام))

إذا كان الشرط محل التفسير يعني أحد المتعاقدين من التزام تفرضه القواعد العامة، أو يخفف من مسؤوليته، أو يسر عليه التنفيذ، فالشك هنا لمصلحة المتعاقد الذي يضار من هذا الشك، وهو الدائن بالتزام، لكنه المدين في الشرط محل التفسير (شرط يخفف مسؤولية المؤجر، ولو أنه هو الدائن بالتزام بالضمان، فيفسر هذا الشرط لمصلحة المستأجر) وبوجه عام يتعين البحث في كل فئة من العقود الملزمة للجانبين عن الطرف الذي يملئ شروطه على الآخر (البائع في عقد البيع والمؤجر في عقد الإيجار)، ويمكن تسوية هذه المزية بأن الدائن بعد محطاً إذا لم يحرص على إبراز بنود العقد، ذلك لأنه هو الذي يملئ في العادة تلك البنود، كما يمكن تسوية ذلك بالاستناد

^١ د. سوار المرجع السابق ص ٣٢٠.

^٢ د. سوار المرجع السابق ص ٣٢٠.

إلى القواعد الكلية إذ أن الأصل في الشخص براءة الذمة ، والالتزام شاغل طارئ لها ، فإذا قام الشك حول مدى التزام المدين ، ففسر ذلك الشك بتضييق الحدود ، أخيراً يمكن تسوية ذلك بالاستناد إلى قواعد الإثبات ، إذ الأصل أن العبء في ذلك يقع على المدعي ، وبالتالي فإذا كانت عبارة العقد التي تتضمن فرض التزامات غامضة ، كان معنى ذلك أن الدائن عجز عن إثبات المدى الذي يدعيه^١

الفرع الثالث

قاعدة الشك لمصلحة المدين على صعيد

العقد الإداري

ذكرنا سابقاً أن مجلس الدولة الفرنسي التزم بتطبيق القواعد المدنية المتعلقة بتفسير العقد ، لكن هذا لا يعني التزامه حرفياً بذلك التطبيق فهو لا يتواءم في حجره تلك القواعد كلما تطلبت مقتضيات الصالح العام ذلك ، وهكذا فهو لم يلتزم بنص المادة ١١٦٢ التي تنضي بأنه في حالة الشك يفسر الالتزام لصالح المدين ، على اعتبار أن اتصال العقد بالمرفق العام لا يسمح بإعمال تلك القاعدة على إطلاقها لأنه لا يمكن التضحية بالصالح العام إطلاقاً^٢.

وكما دللنا سابقاً فقواعد القانون الإداري في معظمها من القانون العام ، لكن هذا الأمر لا يسري على إطلاقه ، وإنما في حدود تعلقه بمقتضيات المرفق العام ، أما الجانب المالي التعاقدي الصرف ، فلا يتعلق بالنظام العام ، لذلك فإن عدم تطبيق قاعدة تفسير الشك لمصلحة المدين على صعيد القانون الإداري ، هذا

^١ د. السهوري : الوسيط ج ١ فقرة ٣٩٨.

^٢ د. الطماوي : الأسس العامة للعقود الإدارية ص ٤١٣.

الأمر لا يسري في نظرنا على الشرط التعاقدى المالى الصرف لعدم اتصاله بالنظام العام .

البحث السادس

التفسير في حال عقد الإذعان

نصت المادة ٢/١٥٢ من القانون المدنى ما يلى :

لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان صاراً بمصلحة الطرف المدعى .

هكذا ذهبت المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى المصرى إلى أن اتعاد تفسير الشك في عقود الإذعان إلى غير مصلحة المدعى له بعد بمثابة حراء له لأنه لم تعرض على إيضاح تعبيره ، وهو القادر على ذلك ، إذ يتوافر لديه من المسائل ما يمكنه من أن يفرض على المتعاقد المدعى شروطاً يبتدئ بها ، فإذا لم يفعل ذلك أخذ بخطته أو تقصيره ، وحمل تبعته لأنه يعتبر مسؤولاً في ذلك الغموض^١ .

فالمدعى له في ظل هذا الرأي بعد مسؤولاً عما يظهر من غموض في الشروط التى عليها على الطرف الآخر الضعيف ، لأنه هو صانعها ، وعليه يقع وزر مد فيها من غموض كان باستطاعته أن يتحاشاه .

وذهب فريق آخر إلى أن أساس هذا التفسير ليس مسؤولية المشترط عمن إخلاله بواجب يقدر ما هو حماية الطرف الضعيف المستند به ، وهو الطرف المدعى ، وأساس التفسير إذاً هو العدالة ، وليس المسؤولية^٢ .

^١ مجموعة الأعمال التحضيرية ج ٢ ص ٥٠ .

^٢ د. سوار النظرية العامة ج ٢ ص ٥٠ .

ما هو أساس هذه النظرية في القانون الإداري ؟ ... وهل يمكن الانطلاق من أساليب القانون العام للكلام على ظاهرة إذعان لصالح التعاقد مع الإدارة ؟.

وحقيقة الأمر أن تلك الأساليب هي وسائل فنية معطاة لكل جهة إدارة من أجل تحقيق الصالح العام ، فهي بالتالي ذات طبيعة موضوعية نابعة من ظروف المرفق و حركته وحياته ، هذا فضلاً عن أن هذه التوسعة لصالح الإدارة قد يقابلها تضيق عليها لصالح الأفراد .

فالإدارة مثلاً لا تستطيع التعاقد إلا بشروط وإجراءات ، كأن تلجأ إلى طريق المناقصة ، كما أنها لا تستطيع استخدام أحد إلا بوسيلة الإعلان عن المسابقة ، وغير ذلك من حالات التضيق .

هذه الأسباب مجتمعة لا يمكن الانطلاق من أساليب القانون العام للحدوث عن إذعان حاق بالتعاقد لا سيما أن الإدارة كثيراً ما تعاقد على ضوء النهار ، وتضع شروط عقودها جهاً في كراسات عامة ، وتطبقها على جميع المتعاقدين بصورة موضوعية مجردة عن الهوى و اللدد والخصومة ، كما سبق توضيحه في الأدب المفروض أن يسود في حياة الإدارة .

ولقد أتيح للقضاء الإداري في مصر الفرصة للحدوث عن استبعاد تطبيق نظرية الإذعان المدنية على روابط القانون الإداري ، وذلك في حكم مطوّل يخترئ منه قدر الإمكان ما تعلق بالإذعان تقول هذه المحكمة :

((من أجل ذلك فإنه عند تنفيذ تفسير العقد الإداري يجب أن يكون مفهوماً أنه ليس لفكرة الإذعان نفس المعنى المعروف به في القانون الخاص ، ذلك أن القانون المدني عندما تعرض لفكرة الإذعان في العقود المدنية قصد إلى التخفيف مما يلزم هذا الضرب من التعاقد من شدة و حرج بالنسبة للعقود

المدعى، فأقام لصالحه استثناءين من أحكام القواعد العامة للتفسير: الاستثناء الأول:

ما نصت عليه المادة ١٤٩ من أنه إذا تم العقد عن طريق الإذعان وكان قد تضمن شروطاً تعسفية جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفى المدعى منها، وذلك وفقاً لما تقتضيه العدالة، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك، وفي هذه الصورة خرج الشارع على الأصل المقرر في قواعد التفسير من أن الحاجة إلى التفسير لا تعرض متى كانت عبارة العقد الواضحة، وفي هذه الحالة تطبق شروط التعاقد كما أقرت خرج الشارع على هذا الأصل فيما يتعلق بما يدرج في عقود الإذعان من الشروط الخائفة فقرر الالتجاء إلى التفسير بشأنها ولو كانت واضحة العبارة يَكُنَّ السياق، وجعل مهمة القاضي أن يثبت في هذه الحالة ما إذا كان العاقد المدعى قد تنبه إلى هذه الشروط فإذا استوثق من تنبه هذا العاقد إليها تخم عليه إمضاء حكمها رعاية لاستقرار المعاملات.

أما إذا تبين أن للتعاقد المدعى لم تنبه إلى الشروط الخائفة فعليه أن يستعدها وينزل على أحكام القواعد العامة، وفي هذا النطاق الضيق يطبق هذا الاستثناء فلا يبلغ الأمر حد استبعاد الشرط الخائف يدعى أن المدعى أكرهه على قبوله متى تنبه إليه هذا العاقد وارتضاء لأنه لا يجوز أن يختلط الإذعان بالإكراه بل أن التوحيد بينهما أمر يتو به ما ينبغي للتعامل من أسباب الاستقرار.

والاستثناء الثاني: ما نصت عليه المادة ١٥١ من أن الشك يفسر في مصلحة المدين، ومع ذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضاراً بمصلحة الطرف المدعى ...

فالقاعدة الأساسية في القانون الخاص أنه إذا عرض ما يدعى إلى تفسير العقد ، وبقي الشك يكتنف إرادة المتعاقدين المشتركة رغم إعمال أحكام التفسير المقررة في القانون المدني ، فإن هذا الشك يفسر في مصلحة المدين دون الدائن ، ومرد هذه القاعدة أن الأصل في الذمة البراءة ، وعلى الدائن أن يقيم الدليل على وجود دينه باعتبار أنه يدعي ما يخالف هذا الأصل فإذا بقي شك لم يوفق الدائن إلى إزالته فمن حق المدين أن يفيد منه ، وبذلك يفسر الشك في مصلحة المدين عند غموض عبارة التعاقد غموضاً لا يتيح زواله ، فاستثنى الشارع من حكم هذا الأصل عقود الإذعان وقضى أن يفسر الشك فيها لمصلحة المتعاقد المذعن دائماً كان أم مدنياً ، لافتراض أن التعاقد الآخر ، وهو أقوى التعاقدين يتوافر له من الوسائل ما يمكنه أن يعرض على المذعن عند التعاقد شروطاً واضحة بيّنة ، فإذا لم يفعل ذلك أخذ بنظره أو نقصيره وحمل تبعته لأنه يعتبر مسبباً في هذا الغموض ... وظاهر مما تقدم أن فكرة الإذعان عند رجال القانون المدني إذ تستند في إحدى صورها إلى وجود شروط حائرة في العقد ، فهذه الفكرة لا تتسق مع طبيعة العقود الإدارية وبما تتميز به من شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص ، كما أن هذه الفكرة إذ تستند في صورة أخرى إلى حماية الطرف الأضعف فإنها تقصد الشخص الذي تضطره الظروف إلى القبول بدون مناقشة الإيجاب الذي يعرض عليه وهو مالا ينطبق على القبول الذي لا يصدر ممن يريد التعاقد مع جهة الإدارة إذ لا يمكن التسليم بأنه يوجد في ظروف تضطره إلى هذا القبول ، كما أن جهة الإدارة وهي تعرض شروطاً على من يرغب بالتعاقد معها فإنما تعرضها لتكون موضع الدراسة والتقدير ثم القبول المطلق أو القبول المشروط أو الرفض ... ومن ثم فإنه لا يجوز أن تتحمل وحدها تبعه غموضها ... وعلى هدى ما تقدم يكون لفكرة الإذعان في العقود الإدارية معنى يختلف

تماماً عنها في العقود المدنية ، وهو معنى خاص يقوم على أن العقود الإدارية - من حيث الشكل - تأخذ شكل عقود الإذعان عندما تنفرد جهة الإدارة بوضع شروطها سلفاً وبدون أن يناقشها عند وضعها المتعاقد المنتظر وعلى أن الإذعان فيها لا يعني إلا تدعيم مركز الجهة الإدارية المتعاقدة وإلزام المتعاقد معها بأن يقبل خضوعه لقانونها ، وهذا بالبداية مشروط باحترام قاعدة حسن النية التي تلزم بها الجهة الإدارية كما يلتزم بها المتعاقد معها وأن الشروط التي تنفرد بوضعها الجهة الإدارية ليست إلا مرادفاً لاعتبار أن العقد طبيعة إدارية))

البحث الختامي

الرقابة القانونية على تفسير العقد وتكييفه وتكملته

يعتبر التكييف عن التفسير بأن التفسير وسيلة لمعرفة مراد المتعاقدين ، في حين أن التكييف يهدف لمعرفة طبيعة العقد والقواعد التي تطبق عليه ، ومن ثم يكون أساس التفسير هو الواقع ، في حين أن أساس التكييف هو القانون ؛ ومع ذلك يجب التمييز في إطار الرقابة بين التفسير الذاتي والتفسير الموضوعي.

١. رقابة محكمة القانون على التفسير الذاتي

قلنا إن التفسير الذاتي يهدف إلى البحث عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين ، وهذا الأمر من متعلقات الواقع ، ولا يخضع لرقابة محكمة القانون ، ومع ذلك فالرقابة الأخيرة تبسط على مسائل التفسير الذاتي في الحالات الآتية :

^١ الفعية رقم ٩٨٣ لسنة ٧ فصالية تاريخ ١٩٥٧/٦/٣٠.

١) إذا كانت عبارة العقد واضحة، لكن القاضي انحرف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين دون أن يسبب عدوله عن المعنى الظاهر إلى خلافه، ففي هذه الحال يكون حكمه باطلاً لبخله من التعليل، وقد سبق الإشارة إلى ذلك .

٢) إذا أخذ قاضي الموضوع بالمعنى الخفي للألفاظ لا بالنية المشتركة للمتعاقدين، فهو يعد مخالفاً لنص المادة ٢/١٥١ من قانون سوري، ومن ثم يتخضع حكمه لرقابة محكمة النقض^١ .

٣) تراقب محكمة القانون قاضي الموضوع في تكييفه للعقد، إذ أن ذلك من

مسائل القانون: Quastio juris

وتوضيح ذلك أن التكييف هو تحديد الماهية القانونية للعقد، وبذلك ليست العبرة بالوصف الذي يخلعه المتعاقدان على العقد إذ قد يطلقان وصفاً غير صحيح إما عن جهل أو عن عمد، فهنا لا يتقيد القاضي بالتسمية التي أطلقاها على العقد، بل ينيرى إلى الوصف العقد بما يتفق مع كنهه وماهيته .
وغني عن البيان أن المحكمة تحكم بما يترتب على الوصف الحقيقي الذي تحدده، وليس على الوصف الذي تحدده الطرفان^٢ .

وهذا ما أكدته حكم المحكمة الإدارية العليا في سورية الصادر في ١٩٦٥/٧/٢ المتضمن بأنه إذا أخطأت الإدارة وأخطأ المواطن في التكييف القانوني للواقعة فالقضاء الإداري يراقب صحة التكييف القانوني وبذلك فإن تراخيص الإدارة في ممارسة النشاط الفردي لا تستجمع خصائص العقود^٣ .

^١ دستور النظرية العامة للإلزام ص ٣٢٩ .

^٢ حكم محكمة النقض السورية الصادر في ١٩٧٢/٤/٢٥ برقم ٤١٢، محامون عدد ٥، لعام ١٩٧٢ .

ص ١٢٤ .

^٣ الحكم رقم ٤ محامون عدد ٨ و ٩ لعام ١٩٦٥ .

(٤) و لمحكمة القانون الرقابة على قاضي الموضوع عند مسخه لشروط العقد ، أو إذا أغفل عن احترام النصوص الصريحة القاطعة فيه ، وهذه الرقابة هي رقابة على أسباب الحكم من ناحية عدم كفايتها ، والبطالان هنا لعدم التسبب أو بسبب قصورها^١ .

(٥) ذكرنا سابقاً التمييز بين الإرادة الظاهرة والإرادة الباطنة والنتائج المترتبة على الأخذ بإحدهما دون الأخرى.

وهذه النتائج بلا شك تنعكس على دائرة التفسير ، بمعنى أن الأخذ بالإرادة الباطنة يعني الأخذ بظاهرة نفسية صرفة ، فهذا يكون الرأي الأعلى لقاضي الموضوع ، بخلاف الأخذ بالإرادة الظاهرة ، فهذا نكون حيال ظاهرة اجتماعية ، أي حيال مسألة قانونية^٢ .

(٦) نرى محكمة القضاء الإداري في مصر أن قواعد التفسير المقررة في القانون المدني ليست من النظام العام^٣ .

وعلى هذا الأساس فإذا كانت قواعد التفسير في القانون المدني ليست من النظام العام تبعاً لطبيعة النص الذي تنول تفسيره ، فالأمر على خلافه بالنسبة للنصوص الإدارية التي هي في معظمها قواعد أمرية كما سبق توضيحه .

٢. رقابة محكمة النقض على التفسير الموضوعي للعقد

يخضع التفسير الموضوعي لرقابة محكمة القانون إذا جاء هذا التفسير مخالفاً للقانون أو مخطئاً في تطبيق قواعد التفسير .

ويترتب على الفارق بين التفسير الذاتي والتفسير الموضوعي النتائج الآتية :

^١ حكم محكمة النقض السورية رقم ٩٥٤ تاريخ ١٦/١١/١٩٧٤ محامون عدد ١٢ العام ٧٤ ص ٣١٨ .

^٢ د. السهوري الوحي في شرح القانون المدني ص ٥٤ .

^٣ حكمها الصادر في ٣٠/٦/١٩٥٧ القضية رقم ٩٨٣ لسنة ٧ قضائية ، وانظر د. الطماوي الأسس العامة للعمود الإدارية ص ٤١٧ فقد عرض لهذا الحكم وتبناه .

(١) يلزم القانون القاضي في التفسير الذاتي بطريقة معينة ، ولا يعملي عليه نتيجة ما .

أما في التفسير الموضوعي فلا يلزم القانون القاضي بطريقة التفسير بقدر ما يعملي عليه نتيجة معينة أو معنى معيناً للعقد ، كأن يلزمه بتفسير الشك لمصلحة المدعى ، أو بتفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان لمصلحة الطرف المدعى ، وهنا جاز لنا القول إن القانون - وليس القاضي - هو الذي يفسر العقد على نحو مباشر ، ويمنع على القاضي أن يعطي للعقد معنى مغايراً للمعنى الذي سببه القانون وإلا يعد مخالفاً للقانون .

فإذا كان ثمة عبارة غامضة في عقود الإذعان تحمل عدة معانٍ ، فليس للقاضي أن يختار معنى يخالف الذي يتصور لمصلحة الطرف المدعى وإلا يعد مخالفاً للقانون .

والخلاصة أن رقابة محكمة القانون تقتصر في التفسير لا ماله ، أما في التفسير الموضوعي فتناول هذه الرقابة مآل التفسير الذي ينساب مباشرة من تطبيق القاعدة الموضوعية^١ .

(٢) يقوم حكم التفسير الذاتي على عنصرين : عنصر يتصل بالقانون (تطبيق القاعدة ٢/١٥١ مدي سوري) وآخر يتصل بالوقائع (البحث عن الإرادة المشتركة) .

أما التفسير الموضوعي فيقوم على عنصر واحد هو تطبيق المادة الواجبة التطبيق (المادة ١٥٢ بشقيها) .

أما العنصر الثاني وهو البحث عن الإرادة المشتركة فلا وجود له

^١ د. سوار : المرجع السابق ص ٣٣٠ .

٣. رقابة محكمة القانون على تكملة العقد

فما إن تكملة العقد يقوم بها القاضي مستعيناً في ذلك بالقواعد المفسرة أو المكملة لإرادة المتعاقدين وبالتالي فقيام القاضي بذلك إنما يتصل بمسألة قانونية^١. أما لجوء القاضي إلى تكملة العقد استناداً إلى قواعد العدالة فهذا الأمر يتصل بمسألة واقعية^٢.

وفي نظرنا إن العدل هو مبدأ أعلى للقانون نقول مبدأ أعلى غير مصاغ في قواعد تطبيقه متعددة، ومن هنا اعتبر إزال حكم العدل في مدلوله العام مسألة واقعية.

^١ د. سوار: المرجع السابق ص ٣٣٠.

^٢ د. جعفري: النظرية العامة للإلتزام ج ١ ص ٢٩٨.

الفهرس

الموضوع	الصفحة
فصل تمهيدى	
البحث الأول	
استجلاء الإرادة المشتركة هو موضوع تفسير العقد	٥
البحث الثانى	
التمييز بين تفسير القانون وتطبيقه	١٠
البحث الثالث	
مقدمة: مظاهر التعبير عن الإرادة	١٣
الفرع الأول: التعبير الصريح والتعبير الضمنى	١٤
الفرع الثانى: الإرادة الباطنة والإرادة الظاهرة	١٦
الفرع الثالث: الإرادة المفترضة	١٩
البحث الرابع	
نظرية مسح العقد	٢٢
البحث الخامس	
بعض القواعد فى تفسير العقد	٢٥
البحث السادس	
مذاهب التفسير	
الفرع الأول: مذهب مفهوم المخالفة	٣١
الفرع الثانى: التصريح بذكر شيء لا يقتضى نفي سواه	٣٢
الفرع الثالث: مذهب السلوك اللاحق	٣٢
الفرع الرابع: مذهب التفسير الواسع ومذهب التفسير الضيق	٣٣

البحث السابع

- ٣٥ تطلق العقد وتكملته
- ٣٩ الباب الأول: التفسير الذاتي للعقد
- الفصل الأول: الطرق الداخلية لتفسير العقد
- البحث الأول: تفسير الشرط ووضح المعنى
- ٤٠ الفرع الأول: مدى أهمية الشرط الواضح في تفسير العقد
- ٤٩ المطلب الأول: استبعاد الغلط في صياغة العبارة الواضحة للشرط التعاقدى
- ٥٠ المطلب الثاني: دور المكان في تحديد المعنى العادى للفظ
- ٥١ المطلب الثالث: الوقت الذي يعتد به في تحديد المعنى العادى للفظ
- ٥١ الفرع الثاني: شروط تطبيق المعنى الواضح المستمد من الشرط التعاقدى
- ٥٢ الفرع الثالث: تحديد المعنى المستمد من الشرط الواضح 'وسائل التحديد'
- ٥٤ المطلب الأول: غلط مشترك في عيب من عيوب الإدارة
- ٥٥ المطلب الثاني: غلط مشترك في صياغة الشرط الوارد في العقد
- ٥٦ المطلب الثالث: الرقابة القضائية على الغلط المشترك لصياغة الشرط التعاقدى
- ٥٨ الفرع الرابع: توافق المعنى الواضح مع الغرض المقصود من العقد
- الفرع الخامس: الرقابة القضائية على توافق العبارة الواضحة مع غرض العقد
- ٦٢ البحث الثاني: تفسير الشرط الغامض
- ٦٤ الفرع الأول: تحديد معنى معين لعبارة تحتل أكثر من معنى
- ٦٥ المطلب الأول: الاستعانة بالنصوص المختلفة في تفسير معنى العبارة الغامضة
- ٦٧ المطلب الثاني: الاستعانة بموضوع العقد في تحديد معنى معين لعبارة للعقد
- ٦٩ الفرع الثاني: تخصيص العبارة الغامضة
- ٧٢ الفرع الثالث: تفسير الشرط العقدي المقتصر على تخصيص حال معين
- ٧٥ الفرع الرابع: تفسير الشرط الغامض بناءً على غرض العقد
- ٧٦ البحث الثالث: مدى الأهمية الخاصة لبعض شروط العقد
- ٧٧ الفرع الأول: أهمية الشرط المألوف في العقد

- ٧٨ المطلب الأول: تعارض الشرط المألوف مع النية المشتركة للمتعاقدتين المستمدة من العناصر الداخلية للعقد
- البند الأول: العقد المتضمن مخالفة للشرط المألوف
- البند الثاني: تعارض الشرط المألوف مع شرط آخر يعكس قصد الحفظي للمتعاقدتين
- ٨٠ المطلب الثاني: تعارض الشرط المألوف مع النية المشتركة
- ٨١ المطلب الثالث: تعارض الشرط المألوف مع نص قانوني أمر
- ٨١ البند الأول: بطلان الشرط المألوف
- ٨٤ البند الثاني: تأثير بطلان الشرط المألوف على العقد
- ٨٥ الفرع الثاني: شرط العقد التي تعطيه وصفا قانونيا معينا
- ٨٨ الفرع الثالث: أهمية الشروط المطبوعة والمكتوبة
- ٨٩ المطلب الأول: عدم التعارض بين الشروط المطبوعة والمكتوبة باليد
- ٩٢ المطلب الثاني: التعارض بين الشروط المطبوعة والشروط المكتوبة يدويا
- ٩٣ الفصل الثاني: الطرق الخارجية المعتمدة في تفسير عبارات العقد
- ٩٣ البحث الأول: دور الشهادة في التعرف على النية المشتركة للمتعاقدتين
- ٩٤ الفرع الأول: الاتبات بالشهادة لتفسير التصرفات القانونية الثابتة بالكتابة
- ٩٤ المطلب الأول: شمول عبارات العقد
- ٩٥ المطلب الثاني: الشهادة بصفتها طريقا احتياطيا لتفسير العقد المكتوب
- البند الأول: تقدير قاضي الموضوع لعبارة العقد الواضحة
- البند الثاني: تقدير قاض الموضوع للعبارة الغامضة
- ١٠١ الفرع الثاني: مدى جواز الاتبات بالشهادة لتفسير مضمون الإقرار القضائي
- ١٠٢ المطلب الأول: سلطة القاضي في استبعاد بعض الوقائع
- ١٠٤ المطلب الثاني: سلطة القاضي في تفسير مضمون التصرف القانوني الثابت بالإقرار القضائي
- البند الأول: تعلق الإقرار بالترام معين مستمد من تصرف قانوني
- البند الثاني: تعلق الإقرار بالتصرف القانوني ذاته
- ١٠٧ البحث الثاني: دور تنفيذ العقد في تفسيره

	الفرع الأول: حالة موضوع العقد
	الفرع الثاني: حالة غموض العقد
١٠٩	المطلب الأول: شروط الأخذ بطريقة التنفيذ من أجل تفسير العقد
١١٠	المطلب الثاني: دور تنفيذ العقد في تفسيره في مجال العقد الإداري
١١٧	البحث الثالث: دور العادة في تفسير العقد
١١٨	الفرع الأول: دور العادة في تفسير العقد في القانون الخاص
	المطلب الأول: شروط الأخذ بالعادة في القانون الخاص
١١٨	البند الأول: وجود غموض في عبارة العقد
١٢١	البند الثاني: الموافقة الصريحة أو الضمنية على حكم العادة
١٢٣	المطلب الثاني: أنواع العادات المعبرة عن النية المشتركة
	البند الأول: العادات المكانية
	البند الثاني: العادة الخاصة بطرفي العقد
١٢٤	الفرع الثاني: العادة الإدارية ودورها في تفسير العقد الإداري
١٢٨	الباب الثاني: التفسير الموضوعي
١٣٠	البحث الأول: الصالح العام
٣٤	البحث الثاني: مبدأ حسن النية
١٣٨	البحث الثالث: طبيعة التعامل
١٤٠	البحث الرابع: العرف
١٤١	البحث الخامس: قاعدة الشك لمصلحة المدين ودورها في تفسير العقد
	الفرع الأول: المدين هو مدين في الالتزام والشرط معا
	الفرع الثاني: المدين هو المدين في الشرط فقط (دائن في الالتزام)
	الفرع الثالث: قاعدة الشك لمصلحة المدين على صعيد العقد الإداري
١٤٤	البحث السادس: التفسير في حال عقد الإذعان
١٤٨	البحث الختامي: الرقابة القانونية على تفسير العقد وتكييفه وتكامله